



刑法总论 · 第一周知识点总结

马工程《刑法学（第二版）》上册 | 第1-6章

本周覆盖章节

- 第一章 刑法概说 概念 / 性质 / 任务 / 体系 / 解释
- 第二章 刑法基本原则 罪刑法定 / 适用平等 / 罪责刑相适应
- 第三章 刑法效力范围 空间效力 + 时间效力
- 第四章 犯罪概念与犯罪构成 犯罪三特征 / 犯罪构成四要件体系
- 第五章 犯罪客体 概念 / 分类 / 与犯罪对象的区别
- 第六章 犯罪客观方面 危害行为 / 危害结果 / 刑法上的因果关系

2026年6月1日 — 6月6日 · 第一周复习总结 · 100%基于课本原文

目 录

刑法总论 · 第一周知识点总结

- (五)
- (六)
- (一)
- (二)
- (三)
- (一)
- (二)
- (三)
- (四)
- (五)
- (一)
- (二)
- (三)
- (一)
- (二)
- (一)
- (二)
- (三)
- (一)
- (二)
- (一)
- (二)
- (三)
- (四) 刑法修正案及后续完善

第一章 刑法概说

- (一)
- (二)
- (三)
- (四)
- (五)
- (六)
- (四)
- (一)
- (二)
- (三)
- (一)
- (二)

- (三)
- (一)
- (二)
- (三)
- (一)
- (二)
- (三)
- (四)
- (五)
- (一)
- (二)

第二章 严法

- (一)
- (二)
- (一) 自公布之日起生效
- (二)
- (一)
- (二)
- (一)
- (二)
- (三)
- (一)
- (二)
- (三)
- (一)
- (二)
- (三)
- (一)
- (二)
- (三)
- (一)
- (二)
- (三)
- (一)
- (二)
- (三)
- (一)
- (二)
- (一)
- (二)
- (四)
- (一)
- (二)

- (三)
- (四)
- (二)
- (三)
- (二)
- (一)
- (二)
- (三)
- (四)
- (一)
- (二)
- (三)
- (四)
- (五)
- (六)
- (一)
- (二)
- (三)
- (四)
- (五)

马工程《刑法学（第二版）》上册 | 2026年6月1日—6日 | 内容基于课本原文

36 绪论、对象的广度和研究内容的深度，努力建构、完善总体国家安全的刑法保护体系。

在对象层面，刑法学研究要立足客观现实中科学技术与社会文化的变迁，时刻关注重点领域和新兴领域可能的犯罪与风险，例如经济、重大基础设施、金融、网络、数据、生物、资源核、太空

、海洋等安全保障问题，不断扩充和丰富国家安全的刑法保护、回应人民对于安全的新需求。在内容层面，应当秉持系统观念，以普遍联系、对立统一的观点看待各领域犯罪与刑事风险的研究：一方面，应关注不同领域、不同类型犯罪之间相互转化所引发的社会治理风险，如由侵财犯罪引发的人身安全犯罪乃至危害公共安全犯罪、个体犯罪被舆论催化扩散形成的集体犯罪等，并将国家安全体系的健全、

国家安全能力的增强、公共安全治理水平的提高、社会治理体系的完善纳入刑法学研究领域，寻求相关犯罪治理手段的联动协同、综合治理；另一方面，应当充分认识不同社会领域在国家整体安全体系中的不同作用，科学分析研判对相关犯罪惩治的手段和强度，严格刑法适用的力度，做到分类施策、宽严相济，使刑法学研究和犯罪治理能够更好助力国家全局安全与稳定。

（五）

刑法学研究要始终坚持服务保障经济社会高质量发展

习近平强调，“我国正处于实现中华民族伟大复兴^⑨的关键时期，经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段”；“立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，推动高质量发展，是当前和今后一个时期全党全国必须抓紧抓好的工作”^⑩。党的二十大报告指出，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。发展是党执政兴国的第一要务。

没有坚实的物质技术基础，就不可能全面建成社会主义现代化强国。刑法学研究不仅要聚焦刑法条文，更要体察国家大局，要善于从党和国家大局、经济社会发展大势、百年未有之大变局中，深刻领悟刑法学研究的时代使命，紧扣“高质量发展”这一关键词，找准研究重点，提升研究质效，以自身的高质量研究与发展，服务保障经济社会高质量发展。当前，要着重围绕“十四五”时期经济社会发展重点领域的刑事治理问题深入开展研究，为国家重大发展战略提供刑事风险防治的思路与对策，服务保障党和国家中心大局。

比如，对于科技创新，习近平指出，“我们必须更强调自主创新。……全面加强对科技创新的部署，集合优势资源，有力有序推进创新攻关的“揭榜挂帅”体制机制，加强创新链和产业链对接”^⑩

刑法学研究要紧扣改革创新，加强现代化产业体系、科技创新、数字经济的刑法保护研究，充分认识科技^⑩ 习近平：

《论把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局》，中央文献出版社 2021 年版，第 408、534 页。

第二节 习近平法治思想习近平法治思想引领新时代

创新的规律和特点，秉持刑法的谦抑审慎善意，正确界定罪与非罪，为司法实践保护科技创新、促进数字经济发展提供刑法理论支撑。对于乡村振兴，党的二十大报告指出：“全面建设社会主义现代化国家，最艰巨最繁重的任务仍然在农村。

坚持农业农村优先发展，坚持城乡融合发展，畅通城乡要素流动。”对于深化农村土地制度改革过程中出现的矛盾、农村金融服务体系的风险、农民财产权益的保障以及粮食安全等问题，刑法学研究者应不断提供切实可行的刑事治理方案。

对于营商环境，习近平指出，“法治是最好的营商环境”^⑧。对一些民营企业历史上曾经有过的一些不规范行为，要以发展的眼光看问题，按照罪刑法定、疑罪从无的原则处理，让企业家卸下思想包袱，轻装前进”^⑨。

刑法学研究要以高水平社会主义市场经济体制建设保障为引领，善于从不同的侧面、不同的案例入手，研究刑事领域法治化营商环境的需求，强化知识产权保护、企业刑事合规、《刑法修正案（十一）》涉企条款适用等问题研究。对于高水平对外开放，习近平指出：“中国将继续提高对外开放水平，建设更高水平开放型经济新体制，持续打造市场化、法治化、国际化营商环境。热忱欢迎大家在中国投资兴业，加强经贸合作，共享发展机遇。^⑩坚持统筹推进国内法治和涉外法治，是习近平法治思想的重要内容，是在维护国家主权与根本利益基础上积极参与全球治理，将中国智慧贡献于人类文明，推动构建人类命运共同体规则体系的重大战略判断。新时期的刑法学研究也应着眼于反制裁、反干涉、反“长臂管辖”机制的构建与健全，推动涉外法治工作战略布局研究，协调推进国内治理和国际治理，更好维护国家主权、安全、发展利益。面对突如其来的疫情，习近平特别强调，疫情防控越是到了最吃劲的时候，越要坚持依法防控，在法治轨道上统筹推进各项防控工作。执法司法机关依法惩治妨害疫情防控的违法犯罪、依法化解涉疫矛盾纠纷、全力服务疫情时期经济发展和民生保障。对此，刑法学研究也不能缺位，要及时总结提炼应急刑事法治的经验与成果，服务保障疫情防控和经济社会发展。

（六）

刑法学研究要始终坚持促进社会治理

全面依法治国是国家治理的一场深刻革命，坚持在法治轨道上推进国家治理^{CD}。《习近平主持召开中央全面依法治国委员会第二次会议强调完善法治建设规划提高立法工作质量效率为推进改革发展稳定工作营造良好法治环境》，《人民日报》2019 年 2 月 26 日，第 1 版。

38 , 统论体系和治理能力现代化,是推进中国式现代化建设,提升国家治理体系和治理能力现代化水平的关键环节和根本保障。习近平指出,要“完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制,打造共建共治共享的社会治理格局“从“要推动更多法治力量向引导和疏导端用力,完善预防性法律制度,坚持和发展新时代“枫桥经验”,完善社会矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制”□。党的二十大报告从健全共建共治共享的社会治理制度、完善基层治理平台、健全城乡社区治理体系、推进市域社会治理现代化、强化社会治安整体防控、建设社会治理共同体等方面对完善社会治理体系作了详尽部署。

刑法学的基本使命在于为社会治理的重要方面一犯罪治理提供理论支撑。在现代社会,犯罪治理是极其浩大⑨杂的社会工程,刑法也只是犯罪治理诸多工具手段中的一种,而且现代社会的犯罪治理还面临着多种价值的调适与平衡问题。因此,刑法学研究不能仅停留于对定罪与量刑的研究、满足于正义的“不迟到”,而要从法治建设的大视野、社会治理的大格局中观察刑法现象及其运行状态,推进刑法学研究与宪法学、民法学、行政法学等不同部门法领域以及社会学、经济学等相关领域的跨学科研究,构建刑事治理与其他社会治理方式互补联动的社会治理格局,推动多层次多领域依法治理,切实提升社会治理法治化水平,实现犯罪问题及其社会风险的源头治理和提前治理,预防犯罪发生,维护社会和谐稳定。

首先,要强化刑事理念研究。

形势决定任务,理念决定行动,刑法学研究要着眼时代变迁,强化对刑事司法实践的理念引领。

一段时期以来,河南兰草案、内蒙玉米案等案件的一审判决,看似于法有据却引发公众质疑,不利于促进社会治理,最终均被改判无罪,这其中就与长期以来刑法学研究偏重法条解读、

理念指引不足的研究范式存在一定关系。最高人民检察院通过对 1999—2019 年 20

年间我国刑事犯罪情况的研究,发现犯罪结构发生了重大变化,严重暴力犯罪比例大幅下降⑨

从而提出“少捕慎诉慎押”检察理念。2021 年又进一步推动“少捕慎诉慎押”理念上升为党和国家的刑事司法政策,指导全国刑事司法办案,最大限度减少社会对立面,促进了社会治理,维护了社会和谐稳定,意义十分重大。

其次,要强化案例研究。

“一个案例胜过一打文件”,要树立案例研究意识,聚焦破CD 《习近平谈治国理政》第三卷,外文出版社 2020 年版,第 353 页。

@ 张军在 2020 年 5 月 25 日向第十三届全国人民代表大会第三次会议作的《最高人民检察院工作报告》中指出,1999 年至 2019 年,检察机关起诉严重暴力犯罪从 16.2 万人降至 6 万人,年均下降 4.8%;被判处三年以上有期徒刑以上刑罚的占比从 45.4%降至 21.3%。中华人民共和国最高人民检察院网站,2022 年 5 月 22 日访问。

第四节 刑法学的研究与学习方法 I 39

解疑难^⑨杂法律适用问题，着力解决困扰司法实践的真问题、新问题；注重透过案例研究深入剖析一个领域的社会治理问题，思考犯罪、刑罚与社会治理之间的关系，提出促进社会治理的新观点、新理论。杭州女子取快递被造谣案，促进了诽谤罪公诉的具体应用；于欢案、昆山案，激活了“沉睡的”正当防卫制度；天津大妈气枪案，引发了社会对枪支认定及枪支犯罪定罪量刑标准的深刻反思。这些有重大社会影响、重大研究价值的案件，需要刑法学研究关注和跟进。最高人民法院、最高人民检察院发布的刑事指导性案例、典型案例，各省级法院、检察院评出的刑事精品案例、优秀案例，都是实践中实现“政治效果、社会效果和法律效果有机统一”的优质案例，是刑法学研究促进社会治理的鲜活素材。

最后，要强化刑事政策研究。刑事政策是党和国家对犯罪治理历史经验的科学总结，是立法的先导、法律的灵魂、司法的指引。要研究运用好党的刑事政策，充分发挥刑事政策指导司法实践的特色优势，通过司法机关推进犯罪治理的社会协同和公众参与，实现犯罪风险的源头性管控和相关领域的社会治理。同时，要善于梳理分析一个阶段的刑事司法实践，总结提炼具有一般规律性、普遍指导性的刑事司法经验，推动刑事政策不断健全完善；更要善于加强对刑事政策的实践观测，适时推动条件成熟的刑事政策转化为刑事立法，为国家治理体系和治理能力现代化贡献刑法学理论支撑，不断形成走向世界的中国刑事治理方案。

第四节 刑法学的研究与学习方法

研究刑法学的根本方法坚持以马克思主义为指导，是当代中国哲学社会科学必须坚持的根本原则。

在刑法学研究中，必须坚持马克思主义的指导地位，把辩证唯物主义和历史唯物主义作为刑法学研究的根本方法。在具体运用这一根本方法研究刑法学时，应当注意以下几点内容：

（一）

强调理论联系实际

理论联系实际，是马克思主义“活的灵魂”和最重要的理论品质。毛泽东在《整顿党的作风》一文中指出，“真正的理论在世界上只有一种，就是从客观实际抽出来又在客观实际中得到了证明的理论”。^⑩ 习近平也明确提出，要“坚持理论联系实际的马克思主义学风”，“反对主观主义、教条主义、形式主义，防叩”。^⑪ 《毛泽东选集》第三卷，人民出版社 1991 年版，第 817 页。

40 绪论、止空对空、两张皮”。^⑫ “我们党的历史反^⑬证明，什么时候理论联系实际坚持得好，党和人民事业就能够不断取得胜利；反之，党和人民事业就会受到损失，甚至出现严重曲折。”^⑭ 2017 年 5 月 3 日，习近平考察中国政法大学时进一步强调，“法学学科是实践性很强的

学科，法学教育要处理好知识教学和实践教学的关系。

要打破高校和社会之间的体制壁垒，将实际工作部门的优质实践教学资源引进高校，加强法学教育、法学研究工作者和法治实际工作者之间的交流”^⑥。党的二十大报告进一步指出：“十八大以来，国内外形势新变化和实践中新要求，迫切需要我们从理论和实践的结合上深入回答关系党和国家事业发展、党治国理政的一系列重大时代课题。”刑法既是理论法学，也是实践法学。丰富多彩的刑事法治实践，是刑法学不断发展的源泉和动力；同时，刑法学理论的创新发展也是刑事法治进步的推进器。研究刑法学过程中，必须注重理论与实践相结合。

首先，要立足中国国情研究刑法学。

我们研究刑法学，根本目的是要解决中国的问题，服务中国的发展，维护中国人民的利益。因此，刑法学的研究必须从中国的实际情况出发，坚持解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实，深入调查研究，充分了解中国的国情、社情、民情，着眼解决新时代改革开放和社会主义现代化建设中的实际问题，作出符合中国实际和时代要求的正确回答，得出符合客观规律的科学认识，形成与时俱进的理论成果，更好指导中国法治实践。当代中国最大的客观实际是：“我国社会主要矛盾的变化，没有改变我们对我国社会主义所处历史阶段的判断，我国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段的基本国情没有变，我国是世界最大发展中国家的国际地位没有变。”^⑦我们要牢牢把握社会主义初级阶段这个基本国情，牢牢立足社会主义初级阶段这个最大实际，这是我们认识当下、规划未来、制定政策、推进事业的基点。我们在刑事立法和刑事司法实践中，既要顺应世界范围内刑事法律发展的大趋势，也必须考虑当前我国经济、社会、文化等各方面的现实状况。例如，在犯罪概念的规定、刑罚体系与种类的设置、某些具体罪名的增设与否问题上，都不能脱离现阶段国情，盲目向西方国家看齐。如我国现行刑法采用的“定性加定量”的犯罪概念，将情叩 习近平：《在全国党校工作会议上的讲话（2015年12月11日）》，人民出版社2016年版，第16页。

第191节 今习

节显著轻微、危害不大的行为排除在犯罪之外，限缩刑法的打击范围，这符合我国的治国传统、法律文化和现实国情。再如，我国目前的死刑政策是“保留死刑、严格限制死刑适用、逐步减少死刑罪名”，这也是符合我国当前国情的。

其次，要坚持理论研究与应用研究并重。一方面，要强化基础理论研究。刑法学的基础理论问题，如犯罪的本质问题、刑事责任的基础问题、刑罚权的正当根据问题等，具有很强的哲理性、思辨性，对其认识的深度和广度直接影响着刑事立法的合理性，也潜移默化地影响着司法者的价值趋向、司法理念，最终会影响办案的质量和效果。

所以，必须强化刑法学基础理论研究，不断夯实刑法学的理论根基。

另一方面，要强化刑事应用研究。刑法学以刑法为研究对象，必须关注现行的刑事立法与刑事司法实践，突出刑法学研究的服务意识与应用价值。如紧跟国家社会治理步伐，研究黑恶势力的治理策略；充分关注新兴技术，研究人工智能的犯罪惩治；顺应时代发展潮流，研究金融犯罪的风险防范；回应社会关注度高、影响广泛的典型案例，对正当防卫、抢夺方向盘、高空抛物诸多领域的刑法应对开展研究等，努力解决实践中的问题。

再次，要坚持问题导向。

问题是理论创新的起点和动力，坚持问题导向是马克思主义的鲜明特点。进入新时代，我国政治、经济、文化、社会生活等各方面发生了深刻变化，尤其是信息技术突飞猛进，人类步入了信息社会、网络时代、数字时代，犯罪的形态、手段等发生了颠覆性变化，刑法学面临诸多新情况、新问题，如虚拟财产的保护问题、个人信息和数据权利的保护问题、人工智能引发的刑事责任问题等。刑法学研究必须强调问题意识，要面向社会问题、面向司法实践，研究真问题，真研究问题，以问题导向推进刑法学发展，以实践效果检验刑法理论的准确性和可行性。

最后，要善于总结提升。强调理论联系实际，就要坚持从实践中来，到实践中去。对我国刑事立法和刑事司法实践中好的做法和有效的经验，应当进行适当的理论概括，努力从中提炼出具有中国特色的理论命题，以丰富和发展刑法学研究，并有效地指导立法和司法实践。对于实践中存在的问题与不足，也应当理性、客观地进行检讨和反思，并寻求改进的方案，以促进立法完善与司法进步。

（二）

推动刑事一体化与学科融合发展

马克思主义唯物辩证法是关于自然、人类社会和思维的运动和发展的普遍规律的科学。系统观念是马克思主义唯物辩证法的基本思维方法，也是我国经济社会发展必须遵循的原则之一。中国特色社会主义法治体系日臻成熟，新时代刑法学研究要强调系统观念，跳出刑法看刑法，用普遍联系的观点，在整个法治体系乃至经济社会发展全局中思考问题、贡献智慧。

首先，要促进刑法学同其他刑事法学科的交流互动。早在 20 世纪 80 年代⁴² 绪论未，储槐植教授就提出了“刑事一体化”命题，主张“贯通学科联系，淡化学科界限，关注现实问题”。“刑事一体化”思想是深化刑法学研究的可行路径，刑法学研究应当打破学科隔阂，加强与犯罪学、监狱学、刑事诉讼法学、刑事政策学等诸刑事法学科之间的交流与融会，同时关注刑事实践中的刑事立法、刑事审判、刑事执行等各个环节的衔接与互动，从而推动刑法学向纵深发展，促进刑事法律的良性运作。比如认罪认罚从宽制度，就是将刑事实体法与程序法融合规定的典型例证，单纯从刑法或者刑事诉讼法的角度去认识分析这项制度，恐怕都难以深刻把握它的重要意义、实质内涵，只有统筹兼顾、融会贯通，才能更好地彰显制度优势、释放治理效能。

其次，要促进刑法学同相关法学学科的交流互动。习近平在中央政治局集体学习贯彻民法典时就强调“坚决防止以刑事案件名义插手民事纠纷、经济纠纷”^{CD}，这充分说明了刑法学研究要讲求联通、贯通、融通：既要与国家治理格局相连，实现自治、法治、德治相得益彰；又要与国家法律体系相连，实现各尽其能、多能互补。我国已有学者提出“立体刑法学”观点，主张刑法学研究要前瞻后望（前瞻犯罪学，后望行刑学）、左看右盼（左看刑事诉讼法，右盼民法等部门法）、上下兼顾（上对宪法和国际公约，下对治安处罚和其他行政处罚）、内外结合（对内加强对刑法的解释，对外重视刑法的运作环境），这也是深化刑法学研究的可行路径。同时，要注重从中国刑法史和刑事制度史中汲取智慧，深入研究德法并重、天理国法人情共治、无讼止息等在我国古代法制实践中的成败得失，择善而用，构建中国刑法学自主知识体系，并从把握中国刑法的普遍原理与发展规律的高度，根据中国的历史与现实创造符合本国国情的刑法制度与理论，从而实现中国刑法制度与理论的守正创新。

再次，要注意引进其他社会科学的研究方法。不同学科的研究方法可以相互借鉴，当代社会科学在经历了长期的专业化分工之后，已大踏步地向交叉、综合和整体化的方向发展，刑法学作为社会科学，其理论上的突破也寄希望于多学科、多视角、综合性的研究进路。同时，刑法不是孤立存在的社会现象，其与政治、经济、伦理、文化等社会现象存在着相互影响的关系，从这些不同关系着手研究刑法现象，可以拓展刑法学研究的视域。近年来，我国不断有学者从哲学、政治学、伦理学、社会学、^⑩理学、文化学等角度探讨刑法问题，这是值得肯定的研究路径。

叩 习近平：《充分认识颁布实施民法典重大意义依法更好保障人民合法权益》，《求是》2020年第12期。

⑩ 刘仁文等：《立体刑法学》，中国社会科学出版社2018年版。

第四节 刑法学的研究与学习方法

最后，在一定范围内还可以引进现代自然科学的研究方法。自然科学、社会科学的互相渗透甚至融合是一个大的趋势，尤其在方法论方面。作为刑法学研究者，有必要了解现代自然科学的最新发展，尤其要密切关注其方法论的发展，只有这样，才能跟上时代步伐，推动刑法学研究的深入发展。例如，现代自然科学方法论中的控制论、系统论、信息论、模糊论、协同论等都可被引进刑法学研究中；再如，近年来随着信息技术与通信技术的融合发展，大数据、云计算、物流网、移动支付、人工智能等问题，都对传统刑法制度与刑法理论带来了影响乃至冲击，也为刑法学的创新发展带来了机遇，值得关注。

（三）

注重用历史的、发展的观点观察刑法现象

辩证唯物主义和历史唯物主义认为，一切事物都是不断地运动、变化和发展的，事物的发展是普遍的、联系的，不能用孤立的、片面的、静止的眼光观察事物。由此出发，在刑法学研究中，要学会运用历史的、发展的观点，即观察某一刑法现象，要结合当时特定的历史条件与客观环境，不能简单套用现在的情势和标准加以评判。如刑法中原有的一些制度或者罪名，现在因不合时宜而被废止，但不能否定其曾经的合理性和积极作用。此外，要看到事物的可变性，注意考察其演变情况与发展趋势，这样才能保持刑事立法与司法的适应性，满足社会对公平正义的需求。对于一些比较原则或抽象的刑法条文，应当结合立法当时的历史背景，努力探求立法原意。不能探明立法原意或立法原意明显有悖于公平正义要求的，应当与时俱进地作出合理解释，促进情理法的统一；对于刑法中一些因为时过境迁而明显不合理的规定，不存在合理解释的空间的，应当在认真调研论证的基础上，及时启动修法程序进行修改，从而使刑事立法跟上时代发展的步伐。

研究刑法学的具体方法刑法学的研究方法是多元的，除上述根本方法之外，还有一些具体的研究方法。主要有以下几种：

（一）

规范分析方法

规范分析方法，是指通过语义分析、逻辑分析等手段，对刑法规范的含义进行阐明的研究方法。

规范分析方法是最古老也是最基本的刑法学研究方法。

我国封建社会中的法学也被称为律学，主要就是对法条进行注疏。

在西方，中世纪一度盛行注释法学派，其侧重运用规范分析的方法研究法律。

改革开放初期，我国刑法学主要采用规范分析方法，以单纯地注释法条为主，理论含量不高。进入21世纪以后，刑法学领域的规范分析方法同思辨研究方法、比较研究方法、关系分析研究方法等结合，并吸收借鉴了现代西方的刑法学及诠释学等理论，理论品位不断提升，形成了更具学术影响力的刑法解释学。

44 绪论

（二）

比较研究方法

比较研究方法，是指对世界各国的刑法和不同时期的本国刑法进行比较，从而区别异同、鉴别优劣、辨明是非的一种研究方法。

比较研究方法对于探求刑法发展规律，促进一国刑事法治的发展具有重要作用。

回顾我国刑法发展历史，从清末修律、民国政府制定刑法、新中国成立之初移植苏联法律，一直到改革开放后的历次刑事立法活动，都在一定程度上借鉴了国外有益的立法经验，对此，比较研

究方法功不可没。在运用比较研究方法时须注意，无论是纵向的古今比较还是横向的中外比较，都必须结合当今中国的实际情况，取其精华，去其糟粕，决不能盲目照搬照抄。

（三）

法社会学研究方法

法社会学研究方法，是指运用包括社会学、人类学、经济学等多学科理论资源，经验性地研究法律现象的一种法学研究方法。这一方法关注刑法同其他社会现象的关系，重视对刑法现象的经验研究，即对刑法的运行过程、适用效果等问题进行观察与思考。法社会学研究方法的应用拓展了刑法学的研究视野，使之从静态的规范视角转向动态的运作视角，对于促进刑法机制的完善、提高刑法运行的效益具有积极意义。

（四）

思辨研究方法 with 实证研究方法

所谓思辨研究方法，是指从概念与观念出发，通过抽象推理、逻辑演绎来认识、揭示事物的属性。所谓实证研究方法，是从对现象的观察出发，通过对实际材料的收集、整理、分析，以经验事实为依据，探寻事物的发展规律。这两种研究方法各有所长，但也存在一定局限。实证研究方法可以弥补思辨研究方法过于空泛的不足，思辨研究方法也能克服实证研究方法难以揭示事物本质的缺陷。

（五）

定性研究方法 with 定量研究方法

所谓定性研究方法，是指从质的方面分析事物，确定事物的性质，揭示其内部的规律性。定性研究方法是思辨研究的主要路径。所谓定量研究方法，是指从量的方面分析事物，揭示其榄的规律性，以检验和证实定性分析的结论。定量研究方法是实证研究方法的重要表现。从定性研究方法发展到定量研究方法，是学科成熟发达的重要标志。

以上所列的各种具体研究方法，都具有自身的特色和优势，当然，也都存在不足与局限。各种研究方法是存在高下之分的，研究者应当根据研究的实际需要分别采用，那种过分推崇某一种方法而忽视甚至贬低其他方法的做法是欠妥的。

从总体上看，当代刑法学的发展趋势是倡导研究方法的多元化。

综合采用各种研究方法，有利于推进刑法学的理论创新和深入发展。在此需要特别指出，以往我国刑法研究中，往往注重思辨研究方法、定性研究方法，忽视实证研究方法、定量研究方

第四节 学习

法。为了使刑法的制定与适用更为科学，须高度重视实证研究方法与定量研究方法。例如，各种刑罚方法的实际适用率及适用效果、各种量刑情节对刑罚适用的具体影响等，都需要通过实证研究和定量研究总结经验，发现和解决问题。当然，在加强实证研究与定量研究的同时，不应矫枉过正，而应当使思辨研究与实证研究、定性研究与定量研究有机结合起来，使之扬长避短，形成良性互补关系。

学好刑法学应处理好的几个关系对于刑法学的初学者而言，在掌握上述刑法学研究的各种方法之前，有必要了解一些入门的学习方法。主要应当处理好三个方面的关系。

（一）

处理好总论和分论的关系

我国刑法分为总则和分则两大部分，总则是对犯罪和刑罚一般内容的规定，分则是对具体犯罪及其法定刑的规定。与此相应，刑法学可分为总论和分论两大板块，总论主要研究犯罪、刑事责任与刑罚的基本原理，分论主要对个罪的认定与处理进行研究。刑法学总论与分论的关系，如同刑法总则与分则的关系，是一般与特殊、抽象与具体的关系，二者相互依存，密不可分。

刑法学的基础理论集中在刑法学总论当中。因此，学好刑法学，首先要学好刑法学总论，了解和掌握刑法总则的主要规定，同时要把握刑法学的基本范畴、基本关系与基础理论。尤其要学好犯罪构成理论，这是刑法学理论的精华所在。

犯罪构成理论实际上是一种认定犯罪的思维方法，掌握犯罪构成理论，对于理解和把握刑法分则规定的具体罪名，准确区分罪与非罪、此罪与彼罪，具有非常重要的作用。

刑法学分论研究具体犯罪的规定。刑法学总论是以分论为依托的，仅仅掌握犯罪和刑罚的一般规定与基本原理，而不深入了解刑法对于具体犯罪的规定，仍然无法解决司法实践中的问题。事实上，现实生活中不存在抽象的、一般的犯罪，我们面临的总是具体的、个别的犯罪，如故意杀人、盗窃、抢劫、贪污等。

因此，必须同时学好刑法学分论，掌握具体犯罪的构成特征与处罚规则。当然，随着刑事立法的发展，刑法分则规定越来越多，不可能也没有必要牢固掌握每个具体罪名，我们可以有针对性地掌握刑法分则中的重点罪名，其他罪名则可以举一反三，触类旁通。

（二）

处理好法条和法理的关系

学习刑法学，特别要强调对法条的学习。

法条是刑法规范的基本存在形式，也是学习刑法学的起点。

精研刑法中的重要条文，是学好刑法学的前提和基础。

而对于刑法法条的学习，不能拘泥于对刑法条文字面意义的理解，要善于透过具体的法律条文，深入探究背后隐含的立法背景与理论依据，即立法者为什么要作46
绪论这样的规定，这就上升到了法理的层面。

了解法条背后的法理，能够帮助我们更准确地理解和适用刑法。

探讨刑法条文法理，不仅要解决刑法的实然问题，还要解决其应然问题，即根据司法实践发现的问题，对现行的刑法规定进行反思，分析哪些规定是妥当的、哪些规定是不妥当的，以便将来改进，从而推动刑法的完善和刑事司法的进步。

（三）

处理好规范和案例的关系

从广义上讲，刑法规范不仅包括立法机关制定的法律条文、法律解释，还包括有关刑法适用的司法解释。在我国，存在大量的由最高人民法院、最高人民检察院制定的刑法司法解释，对司法机关具有法律约束力。学习刑法学必然要掌握刑法规范，但仅掌握刑法规范而不结合具体案例来学习，是难以有效掌握刑法知识的。刑法学是实践性、应用性很强的学科，学好刑法学有必要关注犯罪状况与司法实践动态，多研习一些刑法案例尤其是最高人民法院、最高人民检察院发布的指导性案例、典型案例，这也是理论联系实际的一种路径，对于提升学习效果、培养分析实际问题的能力大有裨益。

刑法规范表现为一套抽象的行为规则与裁判规则，而刑事案件都是具体的、丰富多样的。面对形形色色、千差万别的具体案件，抽象的刑法规范必然会面临一些适用上的疑问和困惑，这就是所谓的疑难案例。面对这些疑难案例，要善于在梳理和归纳案件事实的同时，灵活运用刑法学理论对相关刑法规范进行分析、解释，进而在符合法治精神的前提下得出最合理的处理结论。

1. 如何理解刑法学及其研究对象？

1. 西方刑法学派之争给我们什么启示？

1. 如何理解刑法学的地位和作用？

1. 如何以习近平法治思想引领新时代中国特色社会主义刑法学发展？

1. 研究刑法学的方法有哪些？

1. 如何学好刑法学？

第一章 刑法概说

第一节 刑法的概念、性质与渊源

刑法的概念刑法是规定犯罪、刑事责任和刑罚的法律。具体来说，刑法是掌握政权的阶级即统治阶级，为了维护本阶级政治上的统治和经济上的利益，根据自己的意志，以国家名义制定、

颁布的规定犯罪、刑事责任和刑罚的法律。

刑法有广义和狭义之分。 广义刑法是指一切规定犯罪、刑事责任和刑罚的法律规范的总和。它主要包括刑法典、单行刑法与附属刑法。

狭义刑法是指系统规定犯罪、刑事责任和刑罚的刑法典，它仅是广义刑法的内容之一。 我国1979 年颁布、 1997 年修订并经多次修正的 《刑法》 就是我国现行的刑法典。

刑法的性质刑法的性质有两层含义：一是刑法的阶级性质；二是刑法的法律性质。

（一）

刑法的阶级性质

1. 刑法的产生和发展是一个历史的范畴。 刑法和其他法律一样，不是自古就有的，也不会永远存在下去，它属于历史的范畴，是在原始社会末期，随着私有制、阶级和国家的产生而产生的，它也必将随着阶级、国家的消亡而消亡。

1. 刑法是统治阶级根据自己的意志和利益制定的，是统治阶级对被统治阶级实行专政的工具。 掌握了国家政权的统治阶级，为了维护本阶级的经济利益和政治统治，以国家的名义制定法律，将那些严重破坏统治秩序的行为规定为犯罪，并用刑罚的手段予以惩罚。

由于掌握政权的统治阶级不同，他们的意志和利益不相同，不同刑法的阶级属性自然也不相同。刑法的阶级内容主要是通过刑法的具体规定表现出来的。 刑法的基本内容是犯罪、刑事责任和刑罚，也就是通过对犯罪人追究刑事责任和适用刑罚来为统治阶级服务。

1. 刑法的阶级性质是由国家的阶级本质决定的。 一切剥削阶级国家的刑法，包括奴隶制国家刑法、封建制国家刑法和资本主义国家刑法，尽管因国家类型不同和朝代更替，其内容和形式有所差异，但它们都是以生产资料私有制为基础，反映剥削阶级意志并为剥削阶级利益服务的，它们都是镇压人民的工具，这就是剥削阶级国家刑法的共同阶级本质。 当然，剥削阶级国家刑法为了剥削阶级的整体利益，同样处罚剥削阶级内部的某些犯罪人，也规定了一些所谓保护全体人民等飞；气法棚说利益的条款，体现了刑法的社会性，但这并不能掩盖剥削阶级国家刑法的阶级性。 与剥削阶级国家刑法不同，我国刑法是社会主义类型的刑法，建立在以生产资料公有制为主体、多种所有制经济共同发展的经济基础之上，反映工人阶级和广大人民群众意志，保卫社会主义的政治、经济制度，保护广大公民当前及长远的利益。 我国刑法是保护人民、打击敌人、惩罚犯罪、保障人权、服务国家建设的有力武器，是人民民主专政的重要工具。这一切都反映了我国刑法的社会主义本质。

（二）

刑法的法律性质

刑法的法律性质是指刑法作为法律体系的重要组成部分区别于其他法律的特有属性。

具体而言，刑法与其他部门法如民法、经济法等相比，有四个显著的特点：

1. 刑法所规定内容的特定性。 刑法是规定犯罪、刑事责任、刑罚的法律规范，解决的主要是如何认定犯罪、是否追究刑事责任以及如何追究刑事责任等问题。

刑事诉
讼法尽管与刑法之间有着类似“植物外形和植物本身的联系，动物外形和动物血肉的联系”^⑨但它是规定公检法机关在当事人和其他诉讼参与人的参加下开展刑事诉讼活动的法律规范。 其他部门法虽然也涉及违法及法律后果问题，但所指的主要是一般违法行为，法律后果也主要是承担一定的民事、经济或行政责任。

1. 刑法所保护社会关系范围的广泛性。 刑法保护的是所有受到犯罪侵害的

社会关系，这些社会关系涉及社会生活的各个方面，既涉及经济基础，也涉及上层建筑。 也就是说，任何社会关系的任何方面受到严重的侵害，只要符合法定的条件，就都受到刑法的保护。 民法、经济法等部门法保护和调整的只能是某种特定的社会关系。 比如，民法调整的只能是平等主体的自然人、法人和非法人组织之间的人身关系和财产关系；经济法调整的只能是一定的经济关系。必须指出，所有这些部门法保护和调整的社会关系，也都同时借助刑法的保护和调整。例如，一般违法性质的走私、假冒注册商标、逃税、抗税以及盗伐、滥伐林木，分别属于违反海关法、商标法、税收征收管理法、森林法的行为，由海关、市场监督管理部门、税务部门、林业部门来处理，但如数量大、情节严重，则分别构成相应的走私罪、假冒注册商标罪、逃税罪、抗税罪、盗伐林木罪、滥伐林木罪，应由司法机关依照刑法的有关规定论处。 又如，侵犯婚姻家庭关系的违法行为，凡不履行结婚登记手续，或者不支付赡养费、抚养费的，属于违反婚姻法的一般违法行为，由婚姻法调整；如果有配偶而重婚，或者明知他人有配偶而与之结CD
《马克思恩格斯全集》第一卷，人民出版社 1995 年版，第 287 页。

1. 刑法强制方法的严厉性。 任何法律都有强制性，任何侵犯法律所保护的

社会关系的行为人，都必须承担相应的法律后果，受到国家强制力的干预。 例如，违反民法的，要承担民事责任；违反治安管理处罚法的，要受到治安管理处罚；等等。但是，所有这些强制，都不及刑法对犯罪分子适用刑罚的强制方法严厉。 因为刑罚不仅可以剥夺犯罪分子的政治权利、财产权利，限制或有期、无期剥夺犯罪分子的人身自由权利，而且在最严重的情况下还可以剥夺犯罪分子的生命权利。

如此严厉的强制性，是任何其他法律所没有，也不可能具有的。

1. 刑法的谦抑性。 刑法对于犯罪之防治并非万能的，刑法本身亦有其恶害

性，因此，刑法应具有谦抑性。所谓刑法的谦抑性，就是刑法不应将一切违法行为都当作处罚对象，仅应以具有刑罚处罚必要性之危害行为为处罚对象。

其主要表现在刑法的不完整性、补充性与宽容性。所谓刑法的不完整性，是指刑法并未将所有危害社会的行为都规定为犯罪，而只是将其中严重危害社会的行为规定为犯罪。刑法对社会的规制，不必及于社会生活的每一个领域，应仅限于维持社会秩序所必要并在最小限度之内。刑法的补充性，是指能够以其他手段实现法益保护目的的，应优先考虑适用其他手段而非直接适用刑法加以调整。

正如拉德布鲁赫所说：“社会政策是最好的刑事政策。”少因为刑法的强制方法主要是刑罚，而刑罚如双刃之剑，用之不得其当，则国家与个人两受其害。所以，应当限制而不是扩张刑罚的适用，使刑法成为保护法益的最后手段。刑法的宽容性，是指即使在社会上有现实犯罪行为发生，如果欠缺处罚的必要性，或即使处罚也达不到预防与惩罚犯罪的目的，就应侧重于宽容精神，而对刑罚加以节制。

因为刑法具有以上特点，所以刑法的法律性质不同于其他法律，它是直接用来同犯罪作斗争的法律。其规定是否完备、适用是否正确，往往是衡量一个国家法制是否健全、法治状况达到何种程度的重要标志。

刑法的渊源一般认为，当代我国法律的渊源有宪法、法律、行政法规、地方性法规等。

（一）

刑法典

刑法典，即专门、全面、系统地规定犯罪、刑事责任及刑罚的法律文件。

这是刑法的主要表现形式。我国现行的刑法典是 1979 年颁布、1997 年修订的《中华人民共和国刑法》。之后，全国人民代表大会常务委员会先后通过 11 个刑法修正案，对修订后的刑法典又进行了必要的修正。当人们说“《刑法》第XX条”或“根据《刑法》有关规定”等时，其中的“刑法”都是指刑法典。

（二）

单行刑法

单行刑法，即专门规定某种犯罪、刑事责任及刑罚的法律文件。

这是刑法典的重要补充形式。我国自 1979 年《刑法》颁布以来，至 1997 年《刑法》修订之前，全国人大常委会通过了 23 个单行刑法，如《惩治军人违反职责罪暂行条例》《关于惩治走私罪的补充规定》《关于禁毒的决定》等。这些单行刑法要么针对旧刑法典（即 1979 年《刑法》，下同）的漏洞增加了规定，要么针对旧刑法典的不完善作了补充规定，要么针对旧刑法典的缺陷修改了原有规定。但随着新刑法典（即

1997 年《刑法》，下同）的颁布与施行，《惩治军人违反职责罪暂行条例》等 15
个单行刑法被废止，《关于禁毒的决定》等 8
个单行刑法有关刑事责任的规定失去效力，有关行政处罚与行政措施的规定则继续有效。
这是因为上述 23 个单行刑法的内容基本上都已被纳入新刑法典。在 1997
年修订《刑法》之后，1998 年 12 月 29 日全国人大常委会通过的《关于惩治骗购外汇、逃汇和
非法买卖外汇犯罪的决定》也是单行刑法，它对 1997 年《刑法》的相关内容及时进行了补充。

（三）

附属刑法

附属刑法，即民法、行政法、经济法等非刑事法律文件中有关具体犯罪、刑事责任及刑罚的法律规范。这是刑法的辅助形式。我国大多数民事、行政、经济等法律文件中的法律责任部分，均设有与刑法典和单行刑法相呼应或对其起补充作用的刑法规范。如《商标法》第 67 条规定，未经商标注册人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，构成犯罪的，除赔偿被侵权人的损失外，依法追究刑事责任。伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识，构成犯罪的，除赔偿被侵权人的损失外，依法追究刑事责任。

销售明知是假冒注册商标的商品，构成犯罪的，除赔偿被侵权人的损失外，依法追究刑事责任。但实际上，与国外的附属刑法不同，我国目前的附属刑法只是重申刑法典的内容，而没有对刑法典进行补充，没有独立的实际意义。因此也有观点认为，我国并无严格意义上的附属刑法。

此外，自治区或辖有民族自治地方的省的人民代表大会根据当地民族的政！⁵¹

第二节 刑法的指导思想、根据与任务

，治、经济、文化的特点和刑法典的基本原则可以制定对刑法的变通或补充规定，这类规定也可谓刑法的渊源。但这类规定只在特定地域有法律效力。

第二节 刑法的指导思想、根据与任务

刑法的指导思想刑法的指导思想是掌握了国家政权的统治阶级用以指导刑事立法和司法活动的思想理论体系。不仅不同类型国家的刑法指导思想由于统治阶级赖以生存的物质生活条件不同而根本不同，即使同一类型国家的刑法指导思想也由于其所处的历史时期的政治经济文化等条件的不同而有所区别。我国是工人阶级领导的人民民主专政的社会主义国家，我国刑法是社会主义刑法，是社会主义革命、改革和建设的有机组成部分，我国刑法的立法、司法与理论研究必须以马克思列宁主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系^⑩为指导，深入贯彻习近平法治思想，坚持人民至上、坚持自信自立、坚持守正创新、坚持问题导向、坚持系统观念、坚持胸怀天下，把理论和实际紧密结合起来，研究和解决新的历史条件下出现的新情况新问题，丰富和发展我

国的刑事立法、司法实践和刑法科学，不断适应实践和时代要求，不断完善中国特色刑法学理论体系，在法治固根本、稳预期、利长远的保障作用中发挥好刑法的重要作用。

刑法的根据我国《刑法》第1条规定：“为了惩罚犯罪，保护人民，根据宪法，结合我国同犯罪作斗争的具体经验及实际情况，制定本法。”这一规定明确了我国刑法的制定根据，包括法律根据和实践根据两个方面的内容。

⑩ 党的十七大提出了“中国特色社会主义理论体系”科学命题。党的十八大明确：“中国特色社会主义理论体系，就是包括邓小平理论、‘三个代表’重要思想、科学发展观在内的科学理论体系，是对马克思列宁主义、毛泽东思想的坚持和发展。”党的十九大报告及经十九大修正后的《中国共产党章程》均列明，习近平新时代中国特色社会主义思想是中国特色社会主义理论体系的重要组成部分。

党的二十大及经二十大修正后的《中国共产党章程》对习近平新时代中国特色社会主义思想的定位进行了完善。《中国共产党章程》明确规定，习近平新时代中国特色社会主义思想是对马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观的继承和发展，是当代中国马克思主义、二十一世纪马克思主义，是中华文化和中国精神的时代精华，是党和人民实践经验和集体智慧的结晶，是中国特色社会主义理论体系的重要组成部分，是全党全国人民为实现中华民族伟大复兴而奋斗的行动指南，必须长期坚持并不断发展。

刑法概说

（一）

法律根据

刑法的法律根据是《宪法》。《宪法》作为刑法制定的法律根据体现在诸多方面。

1. 宪法序言或条文中全局性、方向性和根本性的规定。例如，关于坚持人民民主专政、坚持社会主义道路、坚持改革开放以及逐步实现工业、农业、国防和科学技术的现代化的原则性规定，对刑法的立法有着重要的指导作用。

1. 宪法条文中保护性、义务性或禁止性的规定。例如，关于社会主义制度是中华人民共和国的根本制度，禁止任何组织或个人破坏社会主义制度的规定，等等。宪法规范是规定刑法分则各章有关犯罪的直接根据。

宪法规范是基础规范，一般是高度概括的原则条款。

刑法分则有关犯罪的条文，是宪法规定的延伸、补充和具体化。刑法正是以其特殊的功能保护宪法规定的国家的根本制度、根本任务、基本国策和公民的基本权利。

因此，刑法在国家的法律体系中占有重要的地位，是国家的基本法律。

1. 刑法的制定不能违背宪法的规定，否则就是违宪，或者全部无效，或者同宪法相抵触的部分无效。

（二）

实践根据

1. 我国在同犯罪作斗争中积累的非常丰富的经验。 这些经验表现为我国同

犯罪作斗争的基本方针、政策、策略，即社会治安综合治理的方针，惩罚与宽大相结合的刑事政策，区别对待、打击少数、争取教育多数、孤立分化瓦解犯罪分子的策略。 同时还表现为同各种犯罪作斗争的具体方针政策，例如：“四禁并举，堵源截流，严格执法，标本兼治”的禁毒方针；“一要坚决，二要慎重，务必搞准”的打击经济犯罪的政策；等等。

这些方针、政策和策略，都是制定刑法的实践依据。

此外，我国在同犯罪作斗争中还有许多具体的经验。 既有关于自首、立功、共犯、正当防卫、累犯、减刑、假释等刑法总则方面处理各种问题的经验，也有关于各种犯罪的罪名、特征、情节轻重、处理原则等刑法分则方面打击各种具体犯罪的经验。

这些具体的经验都是制定刑法各个具体条文的重要根据。

1. 我国的实际情况。 主要包括两个方面：

（1）社会主义初级阶段的中国国情。 党的十九大报告指出，中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。 必须认识到，我国社会主要矛盾的变化，没有改变我们对我国社会主义所处历史阶段的判断，我国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段的基本国情没有变，我国是世界最大发展中国家的国际地位没有变。 我们要在继续推动发展的基础上，着力解决好发展不平衡不充分问题，大力提升发展质量和效益，更好满足人民在经济、政治、文化、 社会、生态等方面日益增长的需要，更好推动人的全面发展、社会全面进步，为把我国建设成为富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国而奋斗。

（2）

我国的治安情况，特别是犯罪情况。

制定刑法必须从我国社会治安和犯罪的实际情况出发。 这里所讲的社会治安和犯罪的实际情况，不是一时一地的情况，而是一定时期内全国的社会治安和犯罪方面的总体情况。 我国现行的刑事政策是宽严相济，要求我们从社会治安形势和犯罪情况出发，在治安形势严峻、犯罪活动猖獗的时候，要强调从严的方面；反之，则要强调从宽的方面，这是我国同犯罪数十年斗争经验的总结。 当前，贪污、贿赂犯罪虽然在很大程度上得到控制，但是随着技术的进步和经济的发展，相关

犯罪的手段与模式也日趋⑨杂和隐蔽；黑社会性质的有组织犯罪在被广泛打击之后，逐渐脱离了传统暴力化的模式，开始依托互联网等途径实施犯罪行为；恐怖组织犯罪受到国际冲突的催化以及境外恐怖组织的支持，对国家安全造成严重威胁；故意杀人、爆炸、抢劫等暴力犯罪仍然时有发生，社会危害性严重。因此，对以上犯罪可以强调从严，但对其他犯罪，则可以强调从宽。比如，2020年5月25日，最高人民检察院检察长在十三届全国人大三次会议上所作的《最高人民检察院工作报告》显示：“新中国成立70年来，中国共产党领导人民创造了经济快速发展奇迹，更保持社会长期稳定。1999年至2019年，检察机关起诉严重暴力犯罪从16.2万人降至6万人，年均下降4.8%；被判处三年以上有期徒刑以上刑罚的占比从45.4%降至21.3%。”这一结构性变化推动了少捕慎诉慎押刑事司法政策的出台。再如，我国《刑法》明文规定，在共同犯罪中，对组织、领导犯罪集团的首要分子，要按照集团所犯全部罪行处罚，对其他主犯也要按照其所参与的或组织、指挥的全部犯罪处罚；对累犯以及因故意杀人、强奸、抢劫、绑架、放火、爆炸、投放危险物质或者有组织性暴力犯罪被判10年以上有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，不得假释；等等。这些都是根据社会治安形势和犯罪的实际情况作出的具体规定。

刑法的任务我国《刑法》第1条规定：“为了惩罚犯罪，保护人民，根据宪法，结合我国同犯罪作斗争的具体经验及实际情况，制定本法。”从这条规定可以看出，我国刑法的任务包括惩罚和保护两个方面：惩罚犯罪是手段，保护人民是目的。

《刑法》第2条规定：“中华人民共和国刑法的任务，是用刑罚同一切犯罪行为作斗争，以保卫国家安全，保卫人民民主专政的政权和社会主义制度，保护国有：第一章刑法概说财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，维护社会秩序、经济秩序，保障社会主义建设事业的顺利进行。”该条阐明了刑法任务的具体内容，归纳起来，主要包括以下四个方面：1. 保卫国家安全，保卫人民民主专政的政权和社会主义制度。人民民主专政的政权和社会主义制度，是我国人民根本利益的集中体现。我们必须运用刑法武器同各种危害国家安全和企图推翻人民民主专政的政权、破坏社会主义制度的犯罪分子作坚决的斗争，维护国家安全，捍卫和巩固人民民主专政的政权和社会主义制度。我国《刑法》

在分则第一章规定了危害国家安全罪，对各种危害国家安全的犯罪行为规定了较为严厉的刑罚。

1. 保护社会主义经济基础。保护社会主义经济基础主要表现在两个方面：

(1) 保护公共财产和公民私人所有的合法财产； (2) 保护正常的社会主义经济秩序。经济基础是与一定社会历史阶段的生产力水平相适应的生产关系的总和。

其主要内容是生产资料所有制形式以及与生产资料所有制形式相联系的生产、分配、流通的形式。我国现阶段的生产资料所有制形式是以生产资料公有制为主，多种所有制并存，并在此基础上实行社会主义市场经济；相应地，我国刑法对经济基础的保护也就是对以公有制为主的多种所有制和社会主义市场经济的保护。

所以，《刑法》分则专章规定了“破坏社会主义市场经济秩序罪”和“侵犯财产罪”，从而使社会主义经济基础获得了较为有力的保障。国有财产和劳动群众集体所有的财产是社会主义的公共财产，它是巩固人民民主专政和进行社会主义现代化建设的物质基础，是提高广大人民生活水平并走向共同富裕的物质保证。因此，保护社会主义公共财产不受侵犯，是关系坚持社会主义道路、保卫社会主义成果的重大问题。

公民私人所有的合法财产是公民生产、工作、生活不可缺少的物质条件，也必须予以保护。近年来发展起来的城乡劳动者个体经济和私营经济，以及随着对外开放而产生的中外合资经营企业、中外合作经营企业和外商独资企业，都是社会主义经济必要的和有益的补充，对于它们的合法权利和利益，都应予以重视和保护。

1. 保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。我国刑法坚决保护公民享有的人权。公民的人身权利、民主权利和其他权利，都属于人权的基本内容。

人身权利，是指与人身有关的各项权利，如生命权、健康权、名誉权、人身自由权等。只有人身权利不受侵犯，才能行使民主权利和其他权利。

所以，侵犯公民人身权利的犯罪是侵犯公民个人权利犯罪中最严重的犯罪。我国刑法对严重侵犯公民人身权利的犯罪，如故意杀人、强奸、绑架等都规定有严厉的刑罚，直至适用死刑。

民主权利，是指公民依法参加国家管理和社会政治生活的权利。我国《刑法》在分则第四章明确规定了“破坏选举罪”“非法剥夺公民宗教信仰自由罪”“侵犯少数民族风俗习惯罪”和“侵犯通信自由罪”等罪名及相应的刑事责任，体现了对公民民主权利的切实保护。其他权利，是指公民人身权利、民主权利以外的权利，如婚姻自主权，年老、年幼、患病的家庭成员享有的受赡养、抚养、扶养的权利等，对严重侵犯公民其他权利的行为，刑法也要予以追究。

1. 维护社会秩序、经济秩序。没有正常的社会秩序、经济秩序，社会主义

现代化建设就无法正常进行，国家的管理活动也无法正常实施，公民的一切权利也就失去了必要的保障。因此，《刑法》分则规定了“危害公共安全罪”“妨害社会管理秩序罪”和“渎职罪”等各类犯罪，以维护社会秩序和经济秩序，保障社会主义现代化建设事业的顺利进行。

第三节 刑法的沿革与发展

中华人民共和国刑法的创制我国刑法的创制，经历了一个长期而曲折的过程。

早在中华人民共和国成立之初，国家就在明令废除以“六法全书”为代表的国民党政府全部法律后，根据革命和建设的需要，制定了一系列单行刑法。^⑩例如，1950年的《关于严禁鸦片烟毒的通令》《禁止珍贵文物图书出口暂行办法》；1951年的《妨害国家货币治罪暂行条例》《惩治反革命条例》《保守国家机密暂行条例》；1952年的《惩治贪污条例》《管制反革命分子暂行办法》；等等。这些单行刑法在同反革命和贪污、贩运毒品、伪造国家货币等犯罪的斗争中起了重要的作用。在颁布实施单行刑法的同时，我国开始了刑法典的起草工作。

刑法典最初的起草准备工作，是由当时的中央人民政府法制委员会主持进行的。自1950年至1954年9月，法制委员会写出了两个稿本：一是《中华人民共和国刑法大纲草案》（共157条）；二是《中华人民共和国刑法指导原则草案（初稿）》（共76条）。

刑法典的正式起草工作，是由全国人大常委会办公厅法律室于1954年10月组织起草班子开始的。1956年，中国共产党第八次全国代表大会召开，党中央^⑩中华人民共和国刑法的立法实践最早可以追溯到中华人民共和国成立之前的革命根据地时期的有关刑事立法，但限于篇幅，本书只介绍中华人民共和国成立之后的刑事立法情况。

56 i 第一一豆 开运喂说十分重视法制建设。在此背景下，刑法典的起草工作加紧进行，至1957年6月28日，已经写出22稿。但是，随着1957年反右派斗争的开始和法律虚无主义思潮的抬头，刑法草案没有公布，且在此后的三四年时间里，刑法起草工作完全停止。1962年5月，全国人大常委会办公厅法律室在有关部门的协同下，对刑法草案第22稿进行了全面修改。经过多次重大修改和征求意见，到1963年10月9日写出第33稿。但因随后开始的“文化大革命”等政治运动的冲击，最终没能公布。^⑩1976

年“文化大革命”结束。随着党和国家对法制工作的重视，1978年10月，由中央政法小组牵头组成刑法草案修订班子，对刑法草案第33稿进行修订，并先后写出两个稿本。其间，1978年12月中共中央召开了具有重大历史意义的十一届三中全会，明确指出为了保障人民民主，必须加强社会主义法制，使民主制度化、法律化，使这种制度和法律具有稳定性、连续性和极大的权威，做到有法可依，有法必依，执法必严，违法必究。□

+一届三中全会的精神，有力地推动了刑法的起草工作，并起到了重要的指导作用。1979年2月下旬，全国人大常委会法制委员会宣告成立，并从3月下旬开始，抓紧进行包括刑法起草在内的有关立法工作，又先后拟出了刑法草案的3个稿本。其中，第二个稿本于1979年5月29日获得中共中央政治局原则通过，接着又在全国

人大常委会法制委员会和五届全国人大常委会第八次会议上进行审议，之后提交五届全国人大二次会议进行审议。

1979 年 7 月 1 日，《中华人民共和国刑法》在第五届全国人民代表大会第二次会议上获得一致通过，同年 7 月 6 日正式公布，1980 年 1 月 1 日起施行。至此，我国第一部系统的刑法典正式诞生。这是我国刑法规范基本具备的标志，我国刑事法制也从此步入了一个新的阶段。

中华人民共和国刑法的完善

(一)

刑法的局部修改

我国 1979 年《刑法》公布施行以后，为适应国家改革开放中的新情况、新问题和惩治、防范犯罪的实际需要，国家立法机关又不断对之进行修改和补充，CD 高铭暄：《中华人民共和国刑法的孕育诞生和发展完善》，北京大学出版社 2012 年版，第 1—2 页。

~ 1978 年 12 月 13 日，邓小平在中共中央工作会议闭幕会上讲话时指出：“现在的问题是法律很不完备，……应该集中力量制定刑法、民法、诉讼法和其他各种必要的法律，……经过一定的民主程序讨论通过，并且加强检察机关和司法机关，做到有法可依，有法必依，执法必严，违法必究。”《邓小平文选》第二卷，人民出版社 1994 年版，第 146—147 页。

第一分编 刑法总则

57 使之逐步完善。

对刑法典的修改和补充，主要采用单行刑法和附属刑法的方式来实现。1981—1995 年间，全国人大常委会陆续通过了 23 部单行刑法：1981 年 6 月 10 日《惩治军人违反职责罪暂行条例》；1981 年 6 月 10 日《关于处理逃跑或者重新犯罪的劳改犯和劳教人员的决定》；1982 年 3 月 8 日《关于严惩严重破坏经济的罪犯的决定》；1983 年 9 月 2 日《关于严惩严重危害社会治安的犯罪分子的决定》；1988 年 1 月 21 日《关于惩治走私罪的补充规定》；1988 年 1 月 21 日《关于惩治贪污罪贿赂罪的补充规定》；1988 年 9 月 5 日《关于惩治泄露国家秘密犯罪的补充规定》；1988 年 11 月 8 日《关于惩治捕杀国家重点保护的珍贵、濒危野生动物犯罪的补充规定》；1990 年 6 月 28 日《关于惩治侮辱中华人民共和国国旗国徽罪的决定》；1990 年 12 月 28 日《关于禁毒的决定》；1990 年 12 月 28 日《关于惩治走私、制作、贩卖、传播淫秽物品的犯罪分子的决定》；1991 年 6 月 29 日

《关于惩治盗掘古文化遗址古墓葬犯罪的补充规定》；1991年9月4日《关于严禁卖淫嫖娼的决定》；1991年9月4日《关于严惩拐卖、绑架妇女、儿童的犯罪分子的决定》；1992年9月4日《关于惩治偷税、抗税犯罪的补充规定》；1992年12月28日《关于惩治劫持航空器犯罪分子的决定》；1993年2月22日《关于惩治假冒注册商标犯罪的补充规定》；1993年7月2日《关于惩治生产、销售伪劣商品犯罪的决定》；1994年3月5日《关于严惩组织、运送他人偷越国（边）境犯罪的补充规定》；1994年7月5日《关于惩治侵犯著作权的犯罪的决定》；1995年2月28日《关于惩治违反公司法的犯罪的决定》；1995年6月30日《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》；1995年10月30日《关于惩治虚开、伪造和非法出售增值税专用发票犯罪的决定》。

此外，全国人大常委会于1980—1997年间在107部非刑事法律中设置了大量的附属刑法，如1982年《文物保护法》第31条，1984年《兵役法》第61条第2款，1984年《森林法》第

34、35、36条，1985年《计量法》第28、29、30条，1988年《野生动物保护法》第32条，1989年《进出口商品检验法》第26、27条，1989年《传染病防治法》第37、38、39条，1989年《集会游行示威法》第29条，1990年《军事设施保护法》第34条，1990年《铁路法》第60条，1991年《进出境动植物检疫法》第42、43条，1991年《烟草专卖法》第39条，1993年《产品质量法》第37、38、40、42、47、48、49条，1994年《对外贸易法》第38—41条，等等。

上述单行刑法、附属刑法对1979年《刑法》作了一系列的补充和修改，发展了我国的刑事立法，对司法实践起到了一定的指导和规范作用。但是，在刑法典之外存在如此众多的单行刑法和附属刑法，缺乏一个体系上的归纳，显得凌乱不堪，而且有的单行刑法出台以后，刑法典原有条文规定是否废除也不甚明确⁵⁸。第58条刑法理论说（如1979年《刑法》第155条贪污罪条文，在1988年《关于惩治贪污罪贿赂罪的补充规定》颁行后实际上被废除了；1979年《刑法》第141条拐卖人口罪罪名在1991年《关于严惩拐卖、绑架妇女、儿童的犯罪分子的决定》颁行后，仍然存在），以致司法文书中对有的犯罪，既引用刑法典条文，又引用单行刑法的相应条文（如贪污罪、受贿罪、走私罪等），很不规范。再者，1979年《刑法》颁行以来的实践检验和理论研究证明，基于种种原因，我国1979年《刑法》在体系格

局、内容、立法技术诸方面，都存在一些缺陷；单行刑法和附属刑法虽然在某种程度上克服了一些不足，弥补了一些缺陷，但这两种立法方式本身的性质决定了它们不可能从根本上解决刑事立法不完善的问题。因此，司法实务部门和刑法学界一致要求全面修改《刑法》

，即通过全面修改，制定出一部新的系统而完整的刑法典。

（二）

刑法的全面修订

刑法的全面修订工作自 1982 年决定研究修改刑法始，至 1997 年 3 月公布修订的《中华人民共和国刑法》结束，历经 15 年。特别是在修改后的《刑事诉讼法》于 1996 年 3 月 17 日通过后，国家立法机关立即将主要精力投入刑法典的全面修改工作中。从 1996 年 4 月下旬起多次召开规模不同的刑法修改研讨会，并集中时间邀请一些专家学者与立法机关同志一起认真推敲具体的修改问题。在此基础上，全国人大常委会法工委于 1996 年 8 月 31 日推出了《刑法总则修改稿》和《刑法分则修改草案》。经进一步修改，全国人大法律委员会和全国人大常委会法工委又于 1996 年 10 月 10 日编印了《中华人民共和国刑法（修订草案）》（征求意见稿），并将之发往全国各地立法机关、司法机关、法律院校、研究机构等征询意见，后又在北京召开大型的刑法修改座谈会，广泛征求意见。根据这些意见，形成了提交八届全国人大常委会第二十三次会议审议的《中华人民共和国刑法（修订草案）》。1996 年 12 月 24 日至 30 日，八届全国人大常委会第二十三次会议在北京召开，刑法典全面系统的修改自此进入立法审议阶段。1997 年 2 月 19 日至 23 日召开的八届全国人大常委会第二十四次会议，再次审议了刑法修订草案。

1997 年 3 月 1 日至 14 日，八届全国人大五次会议在北京召开，审议与通过刑法修订草案成为这次代表大会最重要的议程之一。1997 年 3 月 14 日，八届全国人大五次会议通过了《中华人民共和国刑法（修订草案）》。同日，以中华人民共和国国家主席令第 83 号予以公布。至此，一部统一的、比较完备的、具有重大改革和多方面显著进步的《中华人民共和国刑法》正式诞生。1997 年《刑法》由总则、分则和附则三个部分组成，分 15 章，计 452 条。根据该法第 452 条第 1 款的规定和第 83 号国家主席令，1997 年《刑法》自 1997 年 10 月 1 日起施行。

第四十九条 刑法的修改体现了以下特点：（1）基本上实现了刑法的统一性与完备性；（2）较好地贯彻了刑事法治原则，加强了刑法的保障功能；（3）立法的过程及内容体现了立足本国国情与适当借鉴国外先进经验相结合的原则。但是，如同其他任何法律一样，刑法的修改不是一劳永逸的，它总是随着社会的变迁与发展而需要不断向前迈进

。

（三）

刑法的适时修正

随着我国经济的飞速发展和法治建设的日益完善，现行《刑法》部分条文已不再适应社会发展的要求，需要通过全国人大常委会予以修正、补充，加以完善。

1997 年《刑法》生效后，短短 20 余年时间，国家立法机关通过 1 个单行刑法和 11 个刑法修正案对其进行了修正。分别是：1998 年的《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》、1999 年的《刑法修正案》、2001 年的《刑法修正案（二）》和《刑法修正案（三）》、2002 年的《刑法修正案

（四）刑法修正案及后续完善

2009 年的《刑法修正案（七）》、2011 年的《刑法修正案（八）》、2015 年的《刑法修正案（九）》、2017 年的《刑法修正案（十）》、2020 年的《刑法修正案（十一）》。此外，全国人民代表大会常务委员会 2009 年 8 月 27 日通过的《关于修改部分法律的决定》对刑法两个条文中的有关词语作了修改。

刑法修正案作为对《刑法》条文的具体修正，通过之后即纳入刑法典成为其组成部分，有利于维护刑法典的统一性和完备性。

第四节 刑法的体系与解释

刑法的体系刑法的体系是指刑法的组成和结构。我国刑法的体系，从总体上分为总则、分则和附则三个部分。其中总则、分则各为一编，各编之下，根据法律规范的性质和内容，有次序地划分为章、节、条、款、项几个层次。附则部分仅 1 个条文，即《刑法》第 452 条。该条的内容，一是规定修订后的《刑法》开始施行的日期；二是规定修订后的《刑法》与以往单行刑法的关系，宣布在修订刑法生效后某些单行刑法的废止以及某些单行刑法中有关刑事责任内容的失效。

如上所述，我国刑法的体系就是通过总则、分则、附则，以编、章、节、条、款、项把刑法涉及的内容有机地结合在一起的。具体分述如下：

第一章 刑法概说

（一）

编

我国刑法首先把各种刑法规范科学而系统地列入总则编和分则编之中，并使两者有机结合起来。刑法总则是关于刑法的指导思想、任务和适用范围，以及犯罪和刑罚的一般原理、原则的规范体系，这些规范是定罪量刑所必须遵守的共同规则。

刑法分则是关于具体犯罪和具体法定刑的规范体系，这些规范是解决具体定罪量刑问题的标准。总则与分则的关系是一般与特殊、抽象与具体的关系。总则指导分则，分则是总则某些原理、原则的具体体现，二者相辅相成。只有把总则和分则紧密地结合起来，才能正确地认定犯罪、确定刑事责任和适用刑罚。

(二)

章

编下是章，章是总则和分则两编之下的单位。

总则和分则各自独立设章。

刑法典第一编“总则”设

5

章，即刑法的任务、基本原则和适用范围，犯罪，刑罚，刑罚的具体运用，其他规定。

第二编“分则”设 10 章，即危害国家安全罪，危害公共安全罪，破坏社会主义市场经济秩序罪，侵犯公民人身权利、民主权利罪，侵犯财产罪，妨害社会管理秩序罪，危害国防利益罪，贪污贿赂罪，渎职罪，军人违反职责罪。各章按一定顺序排列，形成一个有机整体。

(三)

节

章下是节。节是刑法总则和分则的某些章根据需要而设的单位，反映某章内部的有机联系。总则部分，除第一章和第五章外，其余各章下均设若干节；分则部分，大多数章下不设节，仅第三章“破坏社会主义市场经济秩序罪”和第六章“妨害社会管理秩序罪”因涉及的具体犯罪众多、内容庞杂而分设了若干节。

(四)

条

节下是条，条是表达刑法规范的基本单位。

刑法规范通常都是以条文形式出现的，因而条是刑法规范的基本构成元素。

配置在各编、章、节中的刑法条文，全部用统一的顺序号码进行编号。

刑法条文采用统一编号，既可以达到系统化的目的，又可以保证查阅方便、引用准确。

刑法中有的条文在同一款中只表达一个意思，有的条文在同一款里包含两个或两个以上意思。后者例如，《刑法》第 56 条第 1 款规定：“对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政

治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。”该款包含两个意思，用分号隔开。又如，《刑法》第 79 条规定：“对于犯罪分子的减刑，由执行机关向中级以上人民法院提出减刑建议书。人民法院应当组成合议庭进行审理，对确有悔改或者立功事实的，裁定予以减刑。非经法定程序不得减刑。”该条包含三个意思，用句号隔开。一个条文的同一款中包含两个或两个以上意思的，学理上称之为前段、后段，或者前段、中段、后段。在具有这种结构的条款第四句 刑法的体系与解释当中，用“但是”这个连接词表示转折关系的，从“但是”开始的这段文字，学理上称之为“但书”。

我国刑法条文中“但书”所表示的意义大致有以下两种情况：（1）“但书”是前段的例外。例如，《刑法》第 246 条在规定侮辱罪、诽谤罪“告诉的才处理”的同时，又通过“但书”指出严重危害社会秩序和国家利益的除外。

（2）“但书”是对前段的限制。例如，《刑法》第 20 条第 2 款规定：“正当防卫明显超过必要限度造成重大损害的，应当负刑事责任，但是应当减轻或者免除处罚。”在这里，“但书”对防卫过当人负刑事责任作了限制性规定。

（五）

款

条下是款，款是设于某些条之下的单位。有些条文表达的内容比较简单，没有必要设款；但有些条文表达的内容比较丰富，有若干层意思，需要分为若干款。对条下的款，某些国家的刑法以顺序号码或字母来表示，我国刑法则采用另起一行的办法表示。例如，《刑法》第 25 条首先规定：“共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。”接着另起一行：“二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。”前一部分为第 1 款，后一部分为第 2 款。

（六）

项

条与款之下还有项，项是某些条或款之下设立的单位。有些国家的刑法只有条、款，而无项的规定。我国刑法的某些条或款中保留了项的规定，并对之采取了基数号码进行编号。例如，《刑法》第 263 条规定：“……有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：（一）入户抢劫的；（二）在公共交通工具上抢劫的；（三）抢劫银行或者其他金融机构的；

（四）

多次抢劫或者抢劫数额巨大的；（五）抢劫致人重伤、死亡的；（六）冒充

军警人员抢劫的；

（七）持枪抢劫的；

（八）抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。”此条是在条下面设项。又如，《刑法》第91条关于公共财产的规定分两款，第1款下又列了3项，则是在款下面设项。

刑法的解释刑法的解释，是指对刑法规范含义的阐明。

刑法规范之所以需要解释，主要是因为：（1）刑法条文具有一定的抽象性，而现实生活是千姿百态、千变万化的，为了使抽象的法条适用于具体的案件，就需要对刑法规范进行解释；（2）刑法条文具有一定的稳定性，而现实生活具有多变性，为了使司法活动能够跟上客观情况的变化，可以在条文内容许可的情况下，对某些条文赋予新的含义；（3）

刑法条文是用具体文字表述的，可能存在含糊之处，甚至存在缺陷，需要明确。

因此，刑法的解释对正确理解和运用刑法具有重要的意义。

62：第11云概况刑法的解释，可以从不同方面进行分类：

（一）

立法解释、司法解释与学理解释

以解释的主体为依据，可将刑法解释分为立法解释、司法解释^⑩与学理解释。

1. 立法解释。立法解释是由立法机关对刑法的含义所作的解释。具体而言，

立法解释是指全国人大及其常委会对刑法规范本身需要明确的界限，或者为解决最高人民法院和最高人民检察院作出的有关刑事司法解释的原则性分歧而进行的解释。刑法的立法解释对于弥补刑法规范中的漏洞，使刑法规范有效适用于^⑨杂多变的犯罪活动，维护刑法规范的稳定性，具有重要作用。

刑法的立法解释包括以下三种情况：（1）

在刑法中用条文对有关刑法术语所作的解释。

例如，

《刑法》第

93

条规定：“本法所称国家工作人员，是指国家机关中从事公务的人员。国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员和国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业

事业单位、

社会团体从事公务的人员，以及其他依照法律从事公务的人员，以国家工作人员论。”

《刑法》总则第五章“其他规定”还分别对《刑法》中的“公共财产”“公民私人所有的财产”“司法工作人员”“重伤”“违反国家规定”“首要分子”“告诉才处理”“以上、以下、以内”等术语作了解释。《刑法》分则中也有立法解释的内容。例如，《刑法》第357条第1款规定：“本法所称的毒品，是指鸦片、海洛因、甲基苯丙胺（冰毒）、吗啡、

大麻、可卡因以及国家规定管制的其他能够使人形成瘾癖的麻醉药品和精神药品。”(2)

国家立法机关在法律的起草说明或者修订说明中所作的解释。 例如，1997 年 3 月，时任全国人大常委会副委员长王汉斌在《关于《中华人民共和国刑法（修订草案）》的说明》中，对罪刑相当原则作了如下解释：“罪刑相当，就是罪重的量刑要重，罪轻的量刑要轻，各个法律条文之间对犯罪量刑要统一平衡，不能罪重的量刑比罪轻的轻，也不能罪轻的量刑比罪重的重。”(3) 刑法在施行中发生歧义时，全国人大常委会所作的解释。 依照《宪法》第 67 条第 4 项的规定，解释法律是全国人大常委会的职权之一。 例如，全国人中 有观点认为，最高人民法院、最高人民检察院发布的指导性案例也具有司法解释的性质。 以最高人民法院 2010 年 11 月 26 日 发布的《最高人民法院关于案例指导工作的规定》为标志，案例指导从性质上来看， 成为解释法律的一种形式。 2014 年党的十八届 四中全会通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》要求：“加强和规范司法解释和案例指导，统一法律适用标准。” 2015 年 5 月 13 日《（ 最高人民法院案例指导工作的规定） 实施细则》颁布，同年 12 月 30 日《最高人民法院关于案例指导工作的规定》颁布。

第 93 条第 2 款、第 228 条、第 294 条第 1 款、第 312 条、第 313 条、第 341 条、第 342 条、第 384 条第 1 款、第 410 条等的解释。

1. 司法解释。 司法解释是由司法机关对刑法的含义所作的解释。 有权进行

司法解释的司法机关是最高人民法院和最高人民检察院。 1981 年 6 月 10 日五届全国人大常委会第十九次会议通过的《关于加强法律解释工作的决议》第 2 条规定：“凡属于法院审判工作中具体应用法律、法令的问题，由最高人民法院进行解释。凡属于检察院检察工作中具体应用法律、法令的问题，由最高人民检察院进行解释。 最高人民法院和最高人民检察院的解释如果有原则性的分歧，报请全国人民代表大会常务委员会解释或决定。” 1979 年《刑法》 颁行尤其是 1997 年《刑法》 修订以来，最高人民法院和最高人民检察院分别就审判工作和检察工作中具体应用刑法的问题作过不少解释。

例如，关于自首、未成年人犯罪、盗窃、抢夺、抢劫的司法解释等。 而且，最高人民法院和最高人民检察院还就某些犯罪案件如何具体应用法律问题，多次联合作出过司法解释。

1. 学理解释。 学理解释是由专家、学者从学理上对刑法含义所作的解释，如

刑法教科书、专著、论文、案例分析中对刑法规范的含义所作的解释。

立法解释和司法解释属于有权解释，有法律约束力。

学理解释在法律上没有约束力，属于无权解释。 但是，正确的学理解释有助于人们理解刑法规范的含义，对于提高公民的法律意识和法学水平，促进刑法科学的发展，具有重要的作用，甚至对

于司法实践和立法工作也都具有参考价值。

事实上,学理解释也是立法解释和司法解释的重要参考。

(二)

扩张解释、限制解释与当然解释

以解释技巧为依据,可将刑法解释分为扩张解释、限制解释与当然解释。

1. 扩张解释。扩张解释是根据立法原意,对刑法条文所作的超过字面意思

的解释。

例如,将

《刑法》

规定的“审判的时候怀孕的妇女”中的“审判的时候”解释为包括侦查、起诉时期;将《刑法》

第 341 条中的“出售”解释为包括以营利为目的的加工;将《刑法》第 116

条“破坏交通工具罪”中的“汽车”解释为包括大型拖拉机;将《刑法》第 239 条第 2

款“杀害被绑架人”中的“杀害”解释为包括杀伤、杀害未遂;等等。

1. 限制解释。限制解释是根据立法原意,对刑法条文所作的狭于字面意思

的解释。例如,将“教唆不满十八周岁的人犯罪”中的“不满十八周岁的人”解释为“已满十四周岁不满十八周岁”的人;将“二人以上共同故意犯罪”中的“人”解释为具有相应刑事责任能力的人;将入户抢劫犯罪中的“户”解释为他人生活的与外界相对隔离的住所;将“行凶”解释为故意重伤以上。

1. 当然解释。当然解释就是刑法条文虽没有明确规定,但已包含在法律条

64 i 第一章 刑法概说文的含义中,依据理所当然的方式,对刑法条文所作的解释。

例如,既然“禁止攀摘花木”,当然就意味着“禁止创根伐干”。又如,《刑法修正案(七)》颁布之前,偷税罪曾把“因偷税被税务机关给予二次行政处罚又偷税”作为入罪情节之一加以规定,那么,因偷税被税务机关给予三次行政处罚又偷税的,理所当然应解释为构成偷税罪。

一般而言,当然解释可按此进行操作:出罪,举重以明轻;入罪,举轻以明重。

(三)

文义解释、体系解释、历史解释与目的解释

以解释理由为依据,可将刑法解释分为文义解释、体系解释、历史解释与目的解释。

1. 文义解释。文义解释是对刑法条文的字义,包括词语、概念、术语,从

文理上所作的解释。刑法条文以自然语言为载体,而自然语言存在多义性和模糊性等特质,一个词语的核⑩意涵基本是明确的,但是其边缘意义则未必能够被加以明晰。因而,需要结合刑法的具体语境,确定相关字词的含义,如对刑法条文中“可以”“应当”的解释、对刑法条文中多次出现的“暴力”的解释、对抢劫金融机构中“金融机构”的解释、

对持枪抢劫中“枪支”的解释（是否包括假枪）、对组织卖淫罪的对象解释（是否包括男子）等。当然，上述特质属于自然语言的固有缺陷，并非任何时候都能通过文义解释明确刑法条文中字词的含义，更多时候文义解释只是划定了相关概念含义的范围，因此必须通过其他解释方法，在若干可能的含义中选取一种最为合适的解释。

1. 体系解释。刑法并不是零散、孤立条文的集合，而是有序的规范体系，

这要求，一方面，刑法各个条文之间应当相互协调；另一方面，各个条文的含义也应当统摄于刑法体系的核心价值。体系解释就是指将待解释的刑法条文置于整个刑法规范体系中，基于该条文本身所处语境以及与其他条文之间的相互联系，确定其含义，如对出现在不同条文中的同一用语作出同一解释、对条文中的不确定概念比照确定性概念解释其含义、

结合上下文判断特定字词的含义等。体系解释能够在一定程度上协调刑事立法稳定性与司法实践灵活性之间的张力，能够保证刑法体系的融贯性与合理性，有助于罪刑法定原则的实质性实现。

但需要注意的是，体系解释也会受到两个方面的制约：一是语境的制约，即刑法用语的含义因其所使用场合的不同而具有相对性，因此不能机械地认为体系解释就是将刑法中所有相同概念作同一解释。例如，对于“犯罪”这一概念，一般情况下是指满足《刑法》第13

条规定的具有社会危害性并且应当受到刑罚处罚的行为。但是第20条“对正在进行……危及人身安全的暴力犯罪，采取防卫行为……不负刑事责任”中的“犯罪”，则仅指具有严重社会危害性的行为，而不要求行为人应当受到刑罚处罚，否则会得出对无刑事责任能力者实施的杀人等不法行为不可进行正当防卫的荒谬结论。

所以在运用体系解释时，应当注意特定语境下概念的相对性。二是解释学循环的制约，也就是说在对文本进行解释时，需要根据文本细节来理解其整体，但是对细节的理解又需要依托文本的整体。这意味着有时必须跳出刑法条文文本，寻求其他解释方法。

3. 历史解释。历史解释是指根据刑法条文制定的历史背景及其发展演变的情况，阐明条文含义的解释方法。其所参考的材料包括立法机构和起草者对立法意图的直接说明、

立法理由书和论证报告、提案者的说明、法案审议机构的审议报告、法律草案和正式立法之间的变动源流、立法会议的讨论记录和法律起草者的其他相关言论以及立法当时的社会背景和主流观念等。不过，许多刑法条文在立法之初所面临的社会形势与如今相比已经有了很大变化，历史解释的说服力相当有限。例如，根据1997年《刑法》的立法背景，《刑法》第336条第2款规定非法进行节育手术罪显然是为了落实限制生育的人口政策，但在人口政策已经改变为鼓励生育的当下，不可能按照所谓“立法原意”解释该款规定。CD

1. 目的解释。目的解释是根据刑法规范目的或刑法规范所要实现的宗旨，

阐明刑法条文实质含义的具体解释方法。这里的“目的”不能简单等同于立法者主观上希望通过刑法规范实现的效果，而应当从客观层面理解为刑法的规范旨意即对法益的保护，这既包括刑法整体的目的，也包括具体条文的目的。

例如，在最高人民法院 97

号指导性案例“王力军非法经营再审改判无罪案”@ 中，基于目的解释，应当认为被告人王力军未经工商行政管理机关核准登记并颁发营业执照，擅自违法收购玉米并售卖给粮库的行为不构成非法经营罪。因为非法经营罪的目的在于保护市场经济秩序，而被告人收购玉米后转卖给粮库，并非通常意义上的“囤积居奇”行为，实质上并不构成对市场交易秩序的破坏，因此，其行为并未侵害非法经营罪所保护的法益，故不应当认定为犯罪。

叩 张明楷：《刑法学》（上），法律出版社 2021 年版，第 44 页。

@ 基本案情：2014 年 11 月至 2015 年 1 月期间，王力军未办理粮食收购许可证、未经工商行政管理机关核准登记并颁发营业执照，擅自在巴彦淖尔市临河区白脑包镇附近村组无证照违法收购玉米，并将所收购的玉米卖给巴彦淖尔市粮油公司杭锦后旗分公司，经营数额 218288.6 元，非法获利 6000 元。案发后，王力军主动到公安机关投案自首，并退缴获利 6000 元。内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区人民法院于 2016 年 4 月 15 日作出（2016）内 0802 刑初 54 号刑事判决，认定被告人王力军犯非法经营罪，判处有期徒刑 1 年，缓刑 2 年，并处罚金人民币 2 万元；被告人王力军退缴的非法获利款人民币 6000 元，由侦查机关上缴国库。最高人民法院于 2016 年 12 月 16 日作出（2016）最高法刑监 6 号再审决定，指令内蒙古自治区巴彦淖尔市中级人民法院对本案进行再审。内蒙古自治区巴彦淖尔市中级人民法院于 2017 年 2 月 14 日作出（2017）

内 08 刑再 1 号刑事判决：（1）撤销内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区人民法院（2016）内 0802 刑初 54 号刑事判决；（2）原审被告人王力军无罪。

66 笙 严；2. 彬·、，，免□ 拓展学习要知识点阐释 思考案例 法考真题思考题

1. 什么是刑法？

1. 如何理解刑法的任务？

1. 具体阐述刑法解释的种类及其内容。

第二章 刑法的基本原则

第一节 刑法的基本原则概述

刑法基本原则的概念刑法基本原则问题是刑事立法和刑事司法中一个全局性、根本性的问题。所谓刑法基本原则，是指全部刑事立法和司法活动均应当遵循的准则。它贯穿全部刑法规范

，具有指导和制约全部刑事立法和刑事司法的作用，并体现我国刑事法治的基本精神。

首先，刑法基本原则必须贯穿全部刑法规范，具有指导和制约全部刑事立法和刑事司法的作用。在刑事立法上，为了解决定罪和量刑问题，需要制定出各种不同的法律原则，在刑事司法中也必须遵循这些原则。但是，并非每一个原则都是刑法的基本原则，只有那些对刑法的制定、修改、补充具有全局性意义，并且在刑法的整个规范体系中具有根本性意义的原则，才能成为刑法的基本原则。

例如，我国刑法规定的对未成年人犯罪和老年人犯罪从宽处罚的原则、对累犯从严处罚的原则以及从旧兼从轻的处理刑法溯及力问题的原则等，虽然都是刑法中不可缺少的重要原则，但这些原则并不具有全局性的指导意义，只是刑法中局部性的原则，仅适用于某些问题或某些案件，因此，它们不能作为刑法的基本原则。

其次，刑法基本原则必须体现我国刑事法治的基本精神，这就是：坚持法治，摒弃人治；坚持平等，反对特权；讲求公正，反对徇私。刑法的基本原则必须贯穿刑法实施的全过程，不仅指导刑事立法、司法的各个环节，也引导着社会的刑法观念和刑法意识；不仅指导刑事立法与刑事司法机关工作人员正确履职，也影响着全体公民的刑法观念。只有符合刑事法治基本精神的原则才能成为刑法的基本原则。

刑法基本原则的确定1979年《刑法》并未明确规定刑法的基本原则。但是，在该法颁布之后，刑法基本原则作为一个重大理论问题，曾引起刑法理论界和实务界的高度关注。

特别是在20世纪八九十年代刑法修订过程中，关于刑法基本原则如何界定、刑法基本原则应在刑法中增设，以及应当如何规定刑法基本原则等问题，刑法理论界和实务界进行了充分的讨论。1997年《刑法》在广泛听取讨论意见的基础上，在第3、4、5条明确规定了三项刑法的基本原则，即罪刑法定原则、适用刑第二单尸迁L/J法人人平等原则、罪责刑相适应原则。从历史上看，马克思主义经典作家早已对这三项基本原则有过深刻阐述，如“被告既未触犯任何现行法律，就不能按照法律受到惩罚”由“在法律和法官面前，所有的人不论富贵贫贱都一律平等”@“同一类罪行具有极不相同的各种形式……不考虑任何差别的严厉手段，会使惩罚毫无效果”@等。可以说，我国《刑法》规定的三项基本原则是马克思主义者从无产阶级利益出发对西方相关刑法理论进行根本改造后的成果，是马克思主义刑法思想的结晶，开创了我国刑事法治的新纪元。

此外，刑法学界普遍认为，刑法的基本原则并不限于《刑法》明文规定的上述三项原则。依据前文关于刑法基本原则的界定，本书认为，除已为我国1997年《刑法》明确规定的三项基本原则外，以下原则也应被视为刑法的基本原则：一是保障人权原则。在刑法

中确立保障人权原则既是刑法本身的根本要求，也是刑法对宪法的积极回应，更是习近平法治思想在刑法中的直接贯彻。二是罪责自负原则。该原则在立法规定中有明显的体现，并且确立罪责自负原则有利于在刑事司法中拔除封建文化中株连思想的余毒。三是主客观相统一原则。该原则是马克思主义方法论在刑法理论与刑事立法、刑事司法实践中的直接运用，对指导刑事立法与刑事司法具有重要作用。

刑法基本原则具有重大意义：它们既有利于积极同犯罪作斗争，又有利于切实保障公民的合法权益；既有利于推进法治化进程，又有利于维护法律的公正性；既有利于实现刑法的目的，又有利于达到刑罚的最佳效果。刑事法治工作要大力贯彻这些基本原则，不断强化法治意识和公平正义观念，稳步推进刑事立法的发展完善，持续促进刑事司法的文明进步，为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴^⑨奠定法治基础。

第二节 保障人权原则

保障人权原则的含义保障人权原则是指刑法实施的全过程及刑事立法和刑事司法的各个环节都要体现对人权的保障。

2004 年 3 月 14 日，十届全国人大二次会议通过了《宪法修正案》，首次将《马克思恩格斯全集》第十一卷，人民出版社 1995 年版，第 789 页。

第一节 保障人权原则]

“人权”概念引入宪法，载明“国家尊重和保障人权”，标志着我国现行宪法首次用一个概括性条款确认了尊重和保障人权的基本原则。

这是我国民主法治和政治文明建设的一件大事，是我国人权发展的一个重要里程碑。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央始终坚持把尊重和保障人权作为治国理政的一项重要工作，不断推进人权法治保障，坚持实事求是、错案必纠，坚持罪刑法定、疑罪从无，保障无罪的人不受刑事追究、有罪的人受到公正惩罚，坚持非法证据排除，坚决禁止刑讯逼供，坚持完善死刑^⑨复核案件法律援助制度，为世界人权事业发展作出了中国贡献、提供了中国方案。

将保障人权原则确立为刑法的基本原则，主要基于以下几点：（1）是对宪法人权条款的积极贯彻与回应。宪法是国家的根本法，是制定刑法的依据。将“国家尊重和保障人权”写入宪法，必然要求在建设中国特色社会主义法治体系过程中最大限度地尊重人权、最全面地保障人权，也必然要求在刑事立法和刑事司法工作中确立和贯彻保障人权原则。（2）是在刑法中贯彻落实习近平法治思想的重要体现。习近平法治思想是全面依法治国的根本遵循和行动指南，习近平强调，“推进全面依法治国，根本目的是依法保障人民权益”^⑧“健全人权法治保障机制，实现尊重和保障人权在立法、执法、司法、守法全链条、全过程、全方位覆盖

，让人民群众在每一项法律制度、每一个执法决定、每一宗司法案件中都感受到公平正义”；“坚决杜绝因司法不公而造成伤害人民群众感情、损害人民群众权益的事情发生”^⑧

习近平法治思想的根本立足点就是坚持以人民为中心^⑩、坚持法治为人民服务。中国特色社会主义制度保证了人民当家作主的主体地位，也保证了人民在全面推进依法治国中的主体地位。

这是中国的制度优势，也是中国特色社会主义法治区别于资本主义法治的根本所在。因此，刑法必须坚决贯彻习近平法治思想的人民立场观点，也将保障人权原则确立为刑法的基本原则是习近平法治思想在刑法中的直接贯彻落实，是在刑事立法和刑事司法中坚持以人民为中心^⑩的深刻体现。

(3)

鲜明展现了刑法自身的根本要求。

刑法直接关涉公民的基本人权，保障人权本身就是刑法的根本要求。

“刑法既是犯罪人的大宪章，也是善良公民的大宪章。”^⑨一方面，刑法保障犯罪人的人权。在行为人实施了犯罪的情况下，刑法保障犯罪人免受刑法规定以外的不正当刑罚处罚，也保障犯罪人

习近平：

《坚定不移走中国特色社会主义法治道路为全面建设社会主义现代化国家提供有力法治保障》，
《求是》2021年第5期。

□ 习近平：《坚定不移走中国人权发展道路更好推动我国人权事业发展》，《求是》2022年第12期。

⑨ [日]木村龟二主编：《刑法学词典》，顾肖荣、郑树周译校，上居翻译出版公司1991年版，第9页。

70 第二章 刑法-1：侵害基本人权之罪人的基本人权在刑事诉讼中不受侵犯。

另一方面，刑法保障善良公民的人权。

只要公民没有实施刑法所规定的犯罪行为，就不能对该公民定罪处罚。

同时，刑法也通过惩罚和预防犯罪来保护公民免受犯罪的侵害。可见，刑法对人权的保障是全面的，既包括对犯罪人人权的依法保障，也包括对被害人及广大守法公民人权的依法保障。

保障人权原则的具体体现从国际法层面来看，鉴于刑法对人权保障的特殊重要性，各种国际条约或宣言均非常注重以刑事措施保障人权，其中保障人权的条款涉及刑法领域的诸多问题。

例如，联合国1948年的《世界人权宣言》、1966年的《公民权利和政治权利国际公约》等对罪刑法定原则作了明确的规定。联合国大会1985年通过的《为罪行和滥用权力行为受害者取得公理的基本原则宣言》以文书的形式集中规定了保障受害者的基本原则。此外，诸多联合国规约还旗帜鲜明地反对酷刑和其他残忍、不人道或有辱人格的待遇或处罚，并对限制和废止死刑提出了明确的要求。

从当代各国或地区立法来看，一般也都根据本国或本地区实际情况尽可能充分有效地加强刑法对人权的保护。各国或地区刑法的制定与修订充分反映了刑法随时代变迁和社会进步而改革发展的世界性潮流与趋势。尤其是 20 世纪 90 年代以来，随着保障人权的呼声日益高涨，各国或地区在以刑法手段强化人权保障方面迈出了更大的步伐：1992 年法国对其 1810 年《刑法典》的全面修订、1995 年我国澳门地区《刑法典》的颁布、1996 年《俄罗斯联邦刑法典》的出台及与《苏俄刑法典》的分离、2002 年《德国刑法典》与《奥地利联邦刑法典》的修订、2003 年《瑞士联邦刑法典》的修订，无不彰显了保障人权原则。

从我国刑事法治发展来看，基于保障人权原则进一步强化刑法的人权保护机能，是我国刑法发展完善的鲜明主题之一。经全面系统修订的 1997 年《刑法》以及后续的《刑法修正案》都充分体现了保障人权原则。

第一，确立了罪刑法定原则。罪刑法定原则的本质是限制国家的刑罚权、保障人权，只有坚持罪刑法定原则、禁止罪刑擅断，公民的自由才能获得保障。

因此，坚持保障人权原则必然要求坚持罪刑法定。正是基于此，历年的《最高人民法院工作报告》都将落实罪刑法定原则作为加强人权司法保障的具体举措予以论述。

第二，确立了罪责刑相适应原则。

罪责刑相适应原则旨在保障人权，是对保障人权原则的进一步贯彻。轻罪重罚是对犯罪人人权的侵害，重罪轻罚是对善良公民人权的忽视，二者都明显有违公平正义。坚持罪责刑相适应原则，就是确保犯罪人所承受的惩罚与其犯罪行为 and 刑事责任相适应，保证其免受不公正的惩罚，是人权保障的题中之义。因此，坚持保障人权原则也必然要坚持罪责刑相适应原则。

第三，确立了少捕慎诉慎押的刑事司法政策。2021 年 4 月，中央全面依法治国委员会明确提出适应我国新时代刑事犯罪结构性变化，坚持少捕慎诉慎押刑事司法政策，对绝大多数轻罪案件要当宽则宽，慎重羁押、追诉，依法可不捕的不捕、可不诉的不诉，尽可能减少犯罪嫌疑人羁押候审。少捕慎诉慎押是宽严相济刑事政策在新时代刑事司法中的重要体现和具体贯彻，是现代司法文明的标志，是对保障人权原则的贯彻落实，它表明了新时代我国刑事司法重⑩从惩罚犯罪转变为惩罚犯罪与保障人权相结合。

第四，促进了刑罚的人道化。

以死刑为例：一方面，在保障人权原则的指导下，我国刑事立法进一步减少了死刑罪名。自 2004 年“国家尊重和保障人权”写入宪法后，涉及死刑的罪名数量由 2002 年《刑法修正案（四）》颁布后的 68 个减少为 2020 年《刑法修正案（十一）》颁布后的 46

个，减少了近 1/3；另一方面，在不得适用死刑的对象上，增加规定了“审判的时候已满七十五周岁的人，不适用死刑，但以特别残忍手段致人死亡的除外”。此外，在保障人权原则的指导下，我国刑事立法还增设了社区矫正制度，扩大了罚金刑等非监禁刑的适用范围。从权力运作角度看，保障人权原则起到了限制国家刑罚权的作用，避免了无限度动用刑罚权而给公民权利带来的侵害。

第五，强化了对被害人权利的依法保护。例如，《刑法修正案（九）》增加规定，通过网络公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，被害人向人民法院告诉时，如果提供证据确有困难，人民法院可以要求公安机关提供协助。最高人民检察院于 2022 年 2 月发布了以“网络时代人格权刑事保护”为主题的第三十四批指导性案例，其中检例第 137 号“郎某、何某诽谤案”是一起自诉转公诉的刑事案件，针对网络诽谤传播广、危害大、影响难消除，被害人面临举证难、维权难，通过自诉很难实现权利救济的实际情况，检察机关积极主动履职，加强与其他执法机关的沟通协调，依法启动公诉程序，及时有效打击犯罪，加强对公民人格权的刑法保护，维护网络社会秩序，营造清朗网络空间。

综上所述，保障人权原则的具体实践，不仅标志着我国刑事法治的发展，也表明了我国刑事司法文明和人权事业的进步，在刑法中确立保障人权原则有助于我国在人权保护领域开展更为广泛的国际交往，与国际社会共同搭建人权保护的对话平台与合作机制，积极参与全球人权治理，推动人权事业全面发展。

第三节 罪刑法定原则

罪刑法定原则的含义罪刑法定原则的含义是：什么是犯罪，有哪些犯罪，各种犯罪的构成条件是什么，有哪些刑种，各个刑种如何适用，以及各种具体罪的具体量刑幅度如何等，均由刑法加以规定；对于刑法分则没有明文规定为犯罪的行为，不得定罪处罚。概括起来，就是“法无明文规定不为罪，法无明文规定不处罚”。

罪刑法定的思想渊源，最早可以追溯到 1215 年英王约翰签署的《大宪章》第 39 条的规定，即凡是自由人，除经贵族依法判决或遵照国内法律之规定外，不得加以扣留、监禁、没收其财产、剥夺其法律保护权、流放，或加以其他损害。经过长期的发展，1810 年《法国刑法典》第 4 条首次以刑事立法的形式明确规定了罪刑法定原则。据该条规定，实施犯罪行为时法律没有明文规定刑罚的，对任何人不得处以违警罪、轻罪和重罪。其后大陆法系各国竞相仿效。由于这一原则符合现代社会民主与法治的发展趋势，不仅有利于维护社会秩序，也有利于保障人权，至今已成为世界各国刑法最普遍、最重要的一项原则。

一般认为，罪刑法定原则包含四个传统的派生原则：一是成文法主义原则，即规定犯罪及其后果的法律必须是立法机关制定的成文法律，习惯法、判例法不得作为刑法的渊源。我国最高司

法机关发布的司法解释，虽然采用了与刑法条文类似的表述方式，但司法解释并非刑事立法，也不是刑法的渊源。同时，需要指出的是，我国最高司法机关发布的指导性案例并非判例法，其在全国法院和检察院办案具有指导作用和参照适用的效力，但不得代替法律或者司法解释作为处理案件的直接依据。^⑩二是禁止重法溯及既往原则，即重法不适用于其施行之前的犯罪。

对比新旧两个条文后，入罪门槛较低，或者法定刑较高，或者刑罚裁量、刑罚执行规定较严的，为重法。

如果允许重法溯及既往，便会损害公民的预测可能性和法的安定性。

而允许有利于被告人的轻法溯及既往，则并不违背罪刑法定原则的精神。

禁止重法溯及既往，也是从旧兼从轻原则的应有内涵。2018年11月，习近平在民CD 2019年《最高人民法院关于案例指导工作的规定》第15条第1款规定：“各级人民检察院应当参照指导性案例办理类似案件，可以引述相关指导性案例进行释法说理，

但不得代替法律或者司法解释作为案件处理决定的直接依据。”铝轟= 73,打-营企业座谈会上的讲话中指出：“对一些民营企业历史上曾经有过的一些不规范行为，要以发展的眼光看问题，按照罪刑法定、疑罪从无的原则处理，让企业家卸下思想包袱，轻装前进。勺）

这其中就蕴含了允许轻法溯及既往的思想。

三是禁止有罪类推原则，即禁止不利于被告人的类推适用。类推适用是指对于刑法无明文规定的事项，在刑法条文用语的字面含义不可能包括该事项时，因该事项与刑法明文规定的事项具有相似性，而将刑法明文规定事项的法律效果赋予刑法无明文规定事项的法律适用方法。一般认为，允许有利于被告人的类推适用，并不违背罪刑法定原则的精神，这主要是为了实现刑法的实质正义。

四是禁止绝对不确定刑原则，即禁止绝对不确定的刑种和刑度。所谓绝对不确定刑，是指刑法只规定某种行为应受处罚但不规定法定刑的种类和期限，或者刑法为某种犯罪设定了法定刑的种类但不设定期限，最终由法官自由裁定刑种或刑度。

当然，罪刑法定并不要求绝对确定刑，相对确定刑同样符合罪刑法定原则。

相对确定刑考虑到了同一犯罪的不同情形，有利于实现罪责刑相适应，维护实质公平。我国刑法分则除对个别情况规定了绝对确定刑之外（如拐卖妇女、儿童情节特别严重的，处死刑，并处没收财产），绝大多数规定的都是相对确定刑。

此外，罪刑法定原则还有两个新的派生原则：

一是明确性原则，即刑法的内容必须明确具体而不得含糊笼统。明确性原则要求消解“口袋罪”。如果刑法不明确，就不可能限制司法机关恣意定罪处刑，也不可能有效保障公民的自由。只有刑法规范明确具体，才能限制司法权滥用，才能使公民明确知晓哪些行为被刑法所禁止。二是

适当性原则，该原则主要包括两层含义：首先，刑法只能将具有处罚根据或者值得科处刑罚的行为规定为犯罪，禁止处罚不当罚的行为；其次，刑罚应当与犯罪相适应，刑罚手段不应残酷，这一层含义已为我国的罪责刑相适应原则所吸收。

罪刑法定原则的立法体现1979年《刑法》没有明确规定罪刑法定原则，却在第79条规定了类推制度。当时，在理论上，对于《刑法》是否采用了罪刑法定原则，曾存在不同的认识和理解。本书认为，在1997年修订《刑法》之前，我国刑法大体上实行了罪刑法定原则，并体现在刑法关于犯罪的概念，罪与非罪、此罪与彼罪的界限，犯罪构成的一般要件和具体要件，以及法定刑等的规定中。只不过由于当时存在类推制度以及其他一些不符合罪刑法定原则要求之处，因而当时我国刑法对罪刑法叩 习近平：《在民营企业座谈会上的讲话（2018年11月1日）》，人民出版社2018年版，第17页。

74 第定原则的认可、重视和贯彻的程度还不高。1997年修订后的《刑法》，从完善我国刑事法治、保障人权的需要出发，明文规定了罪刑法定原则，并废止类推的规定，成为我国刑法发展完善的一个重要标志。

1997年《刑法》第3条规定：“法律明文规定为犯罪行为的，依照法律定罪处刑；法律没有明文规定为犯罪行为的，不得定罪处刑。”此即我国刑法中的罪刑法定原则。

这一原则的价值内活和内在要求，在整部刑法中得到了较为全面、系统的体现：第一，1997年《刑法》实现了犯罪的法定化和刑罚的法定化。犯罪的法定化具体表现为明确规定了犯罪的概念、犯罪构成的共同要件和各种具体犯罪的构成要件；刑罚的法定化具体表现为明确规定了刑罚的种类、量刑的原则、各种刑罚制度和各种具体犯罪的法定刑。

第二，1997年《刑法》取消了1979年《刑法》第79条规定的类推制度，这是罪刑法定原则得以真正贯彻的重要前提。

第三，1997年《刑法》重申了1979年《刑法》第9条规定的刑法在溯及力问题上从旧兼从轻的原则。

第四，在分则罪名的规定方面，1997年《刑法》已相当详备。分则条文由1979年《刑法》的103条增加到350条，罪名数由1979年《刑法》的129个增加到412个。1997年《刑法》通过以来，全国人大常委会因应社会政治、经济、文化等方面的变化及与犯罪作斗争的需要，又陆续制定了1部单行刑法和11部刑法修正案，对1997年《刑法》进行了诸多修改，刑法分则条文和罪名均有大幅度的增加。

第五，在具体犯罪的罪状以及各种犯罪的法定刑设置方面，1997年《刑法》增强了法条的明确性和可操作性。一方面，把流氓罪、投机倒把罪等“口袋罪”分

解为内容具体、范围明确的若干种犯罪；另一方面，对绝大多数犯罪使用叙明罪状，具体描述了相关犯罪的构成要件，在法定刑的设置上，也注重量刑情节的具体化。

罪刑法定原则的司法适用刑法规定的罪刑法定原则的实现，有赖于司法机关的司法活动。从我国的司法实践来看，切实贯彻罪刑法定原则，必须注意以下两个问题：第一，罪刑法定与司法适用。罪刑法定原则是衡量刑法适用是否合理的根本标准。刑法适用必须在罪刑法定原则的前提下进行，司法工作人员不得超出刑法文本可能具有的含义范围适用刑法。刑法通过文字表述指引、指示人们的行为，反过来，公民则通过刑法用语了解刑法规范、获悉刑法禁止什么行为。在进行刑法解释时，如果超出刑法文本可能具有的含义范围进行解释，将一般公民根据刑法用语所预想不到的事项解释为刑法用语所包含的事项，进而处罚一般公民原本不认为是犯罪的行为，就会损害一般公民的预测可能性，导致公民无法预测自己的行为性质及后果，从而不当限缩公民的行动自由。因此，一切超出一般公民预测可能性的解释都属于类推适用而非扩张解释，都应该被禁止。

第二，罪刑法定与司法解释。对于刑法规定不够具体的犯罪，最高司法机关通过司法解释指导具体的定罪量刑活动，这对于统一规范适用和正确指导司法实践，具有重要的意义。

但是，制定司法解释也要遵守罪刑法定原则。一方面，司法解释必须具有明确性。如果司法解释不明确，就会为下级司法机关留出滥用权力的空间。从行为规范的角度讲，我国的司法解释采用了与刑法条文一样的表述方式，所以公民很可能通过阅读司法解释了解相关行为的性质，从而决定是否实施相关行为。因此，如果司法解释不明确，也可能导致公民无所适从。另一方面，司法解释也不得类推适用。司法解释归根到底属于刑法解释活动，而非刑事立法活动，类推适用属于“法官造法”而非“法官释法”，理应杜绝。

《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》强调，要“健全落实罪刑法定、疑罪从无、非法证据排除等法律原则的法律制度”。由此可见，虽然我国的刑事立法、司法在贯彻罪刑法定原则方面取得了很大进步，但仍有较大的改进空间，需要继续不断努力。

第四节 适用刑法人人平等原则

适用刑法人人平等原则的含义法律面前人人平等是我国宪法确立的社会主义法治的基本原则。《宪法》明确规定，任何组织或个人，“都必须遵守宪法和法律”，“都不得有超越宪法和法律的特权”，“一切违反宪法和法律的行为，必须予以追究”。为了使这一原则进一步得到贯彻执行，我国一些基本法律也对之加以规定，如《刑事诉讼法》《民事诉讼法》都规定了公民在适用法律上一律平等。刑法作为惩罚犯罪、保护人民的基本法律，更应当贯彻这一原则。为此，《刑法》第4条规定：“对任何人犯罪，在适用法律上一律平等。不允许任何人有超越法律的特权。”这就将宪法确立的法律面前人人平等原则，结合刑法的特殊性质和内容，具体化

为适用刑法人人平等这样一项刑法基本原则。

适用刑法人人平等原则的含义是：对任何人犯罪，不论犯罪人的民族身份、家庭出身、社会地位、职业性质、财产状况、政治面貌、才能业绩如何，都应追究刑事责任，一律平等地适用刑法，依法定罪、量刑和行刑，不允许任何人有超越法律的特权。

适用刑法人人平等原则的具体体现适用刑法人人平等原则具体体现在定罪、量刑和行刑三个方面。

第一，定罪上一律平等。

任何人犯罪，无论其身份、地位等如何，一律平等对待，适用相同的定罪标准。不能因为被告人地位高、功劳大而使其逍遥法外，不予定罪；也不能因为被告人是普通公民就妄加追究，任意定罪。

第二，量刑上一律平等。犯相同的罪且有相同的犯罪情节的，应做到同罪同

罚。虽然触犯相同的罪名，但因犯罪情节不同，比如有的具有法定从重处罚的情节，有的具有法定从轻、减轻或者免除处罚的情节，从而同罪不同罚，这是合理的、正常的，并不违背适用刑法人人平等原则。但如因某人权势大、地位高或财大气粗而给予从宽处罚，则是违背适用刑法人人平等原则的，因为这等于承认某人享有超越法律的特权。

第三，行刑上一律平等。在执行刑罚时，对于所有的受刑人都应平等对待，凡罪行相同、主观恶性相同的，刑罚处遇也应相同，不能基千权势地位、富裕程度等而对一部分人搞特殊，对另一部分人加以歧视。对于法律规定的减刑、假释的条件的适用也应体现平等，谁符合条件，谁不够条件，都要严格以法律为准绳，不搞亲疏贵贱。当然，因罪行轻重不同、主观恶性不同、改造表现不同而给予差别处遇，是行刑的题中应有之义，比如教育改造工作中的评分制、累进制，都体现了相同情况相同对待、不同情况区别对待的司法公正精神，这既不违反适用刑法人人平等原则，反而恰恰是适用刑法人人平等原则的实质体现。

第五节 罪责刑相适应原则

罪责刑相适应原则的含义我国《刑法》第 5 条规定：“刑罚的轻重，应当与犯罪分子所犯罪行和承担的刑事责任相适应。”该条规定的就是罪责刑相适应原则。罪责刑相适应原则的含义是：犯多大的罪，就应承担多大的刑事责任，法院也应判处其相应轻重的刑罚，做到重罪重罚，轻罪轻罚，罪刑相称，罚当其罪；在分析罪重罪轻和刑事责任大小时，不仅要看犯罪的客观社会危害性，还要考虑行为人的主观恶性和人身危险性，把握罪行和罪犯各方面因素综合体现的社会危害程度，进而确定其刑事责任程度，适用相应的刑罚。

罪责刑相适应原则的提出伴随着罪刑相适应原则与刑罚个别化原则的角力。

罪刑相适应原则最早可以追溯到原始社会的同态^{⑨⑧}和奴隶社会的等量报^⑨。

“以血还血、以眼还眼、以牙还牙”是罪刑相适应原则最原始、最粗俗的表现形式。罪刑相适应成为刑法的基本原则，则是17、18世纪的资产阶级启蒙思想家和法学家倡导的结果。孟德斯鸠指出：“惩罚总应有程度之分，按罪行大小，定惩罚轻重。”^{CD}贝卡里亚在其传世之作《论犯罪与刑罚》一书中指出：“犯罪对公共利益的危害越大，促使人们犯罪的力量越强，制止人们犯罪的手段就应该越强有力。这就需要刑罚与犯罪相对称。”^⑩资产阶级革命胜利后，罪刑相适应原则被写进了法律。然而，从19世纪末开始，随着刑事人类学派和刑事社会学派的崛起，刑罚个别化原则对传统的罪刑相适应原则发起了有力的挑战。刑罚个别化原则是指，根据犯罪人的人身危险性大小和改造的难易程度决定刑罚的轻重，对不同的犯罪人处以不同的刑罚，使刑罚最大限度地满足改造犯罪人的需要。

不难看出，罪刑相适应原则与刑罚个别化原则都各有所短：罪刑相适应原则全然不顾初犯、累犯等犯罪人自身情况的差异，势必导致刑罚的机械和僵硬，难以实现特殊预防；刑罚个别化原则片面地根据人身危险性的大小决定刑罚的轻重，违背了罪、刑之间的基本关系，容易造成司法擅断和人权侵犯。相比之下，我国的罪责刑相适应原则既注重刑罚与犯罪行为相适应，又注重刑罚与犯罪人个人情况（主观恶性和人身危险性）相适应，通过刑事责任这个中介有机地将犯罪与刑罚统一起来，巧妙地融合了罪刑相适应原则与刑罚个别化原则，兼具科学性和时代性。

罪责刑相适应原则的立法体现我国刑法明文规定的罪责刑相适应原则，贯穿刑法始终，具体表现为：第一，确立了科学严密的刑罚体系。我国刑法总则确定了一个科学的刑罚体系，这一体系由不同的刑罚方式构成。从性质上区分，包括生命刑、自由刑、财产刑、资格刑；从程度上划定，有重刑也有轻刑；从种类上分，包括主刑和附加刑。各种刑罚方式相互区别又互相衔接，可根据犯罪的具体情况灵活适用，从而为罪责刑相适应原则的适用奠定了基础。

第二，规定了区别对待的处罚原则。我国刑法总则根据各种行为的社会危害程度和行为人身危险性的大小，规定了不同的处罚原则。例如，对于因防卫过当、避险过当而构成犯罪者，应当减轻或者免除处罚；对于预备犯，可以比照既^{CD} [法] 孟德斯鸠：《波斯人信札》，罗大冈译，人民文学出版社1958年版，第140页。

@ [意] 贝卡里亚：《论犯罪与刑罚》，黄风译，中国大百科全书出版社1993年版，第65页。

第一遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚；对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚；对于中止犯，没有造成损害的，应当免除处罚，造成损害的，应当减轻处罚。在共同犯罪中，对

组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚；对于其他主犯，按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；对于胁从犯，应当按照他的犯罪情节减轻处罚或者免除处罚；对于教唆犯，应当按照他在共同犯罪中所起的作用处罚。凡此种种，都体现了罪责刑相适应原则。此外，刑法总则还基于刑罚个别化的要求，规定了一系列刑罚裁量与执行制度，如累犯制度、自首制度、立功制度、缓刑制度、减刑制度、假释制度和社区矫正制度等。在这些刑罚制度中，累犯因其人身危险性大而应从重处罚；自首、立功者因其人身危险性小而可以从宽处罚；对短期自由刑适用缓刑的前提是犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险且宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响；减刑和假释是因为罪犯在刑罚执行期间确有悔改或立功表现。

第三，设置了轻重不同的法定刑幅度。我国刑法分则不仅根据犯罪的性质 and 危害程度建立了一个犯罪体系，还为各种具体犯罪规定了可以分割、能够伸缩、幅度较大的法定刑，有助于司法机关根据犯罪的性质、罪行的轻重、犯罪人主观恶性的大小，依法判处适当的刑罚。

罪责刑相适应原则的司法适用根据罪责刑相适应原则的基本要求，结合我国刑事司法实践，司法机关在贯彻这一原则时，应当注意以下两个问题：第一，作为刑法基本原则，罪责刑相适应原则具有指导刑法适用、制约定罪的功能。例如，《刑法》第333条规定：“非法组织他人出卖血液的，处五年以下有期徒刑，并处罚金；以暴力、威胁方法强迫他人出卖血液的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。有前款行为，对他人造成伤害的，依照本法第二百三十四条的规定定罪处罚。”从文义上讲，该条中的“伤害”当然包括轻伤，但是，这样的解释会导致罪责刑明显不相适应：以暴力强迫他人出卖血液但没有造成他人轻伤的，认定构成强迫卖血罪，处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金；而以暴力强迫他人出卖血液造成他人轻伤的，认定构成故意伤害罪，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制。这显然有违公平正义，不符合罪责刑相适应原则，因此，从罪责刑相适应原则出发，应当认为《刑法》第333条中的“伤害”不包括轻伤。

第二，要正确处理好罪、责、刑之间的关系。一方面，罪行是刑事责任的前提，罪行的存在与否决定着刑事责任的存在与否，刑事责任的大小也主要由罪行的危害程度决定。另一方面，刑事责任是刑罚适用的根据，刑事责任的大小直接决定了刑罚的轻重，刑事责任重则刑罚重，刑事责任轻则刑罚轻，刑事责任很轻时，还可免于刑事处罚。因此，作为集中反映罪行的社会危害性和犯罪人的人身危险性的概念，刑事责任发挥着居中协调犯罪与刑罚的作用。

第六节 刑法的其他基本原则

罪责自负原则

(一)

罪责自负原则的含义

罪责自负原则的含义是：谁犯了罪，就应当由谁承担责任；刑罚只及于犯罪者本人，任何人不因他人的犯罪行为而受处罚。罪责自负与罪责株连根本对立。

罪责株连是奴隶社会和封建社会司法裁判制度的重要特征。在人类社会的发展史上，株连之法存在了数千年之久，而我国封建社会的株连制度达到了登峰造极的地步。

我国古代刑法规定的株连制度有族诛、缘坐、连坐、籍没、禁锢、联保连坐等。

在株连制度下，因一起案件而受株连者少则数人，多则成百上千。

犯罪者之亲友、邻里、主仆、师生、同僚等皆有可能受牵连，难逃祸殃。

西方社会古代则盛行“团体责任”，《汉谟拉比法典》《十二铜表法》中都有大量有关责任牵连的规定，类似的规定在一定程度上被中世纪教会法所承继，针对这种黑暗的刑罚制度，17、18世纪的西方资产阶级启蒙思想家和革命家，率先向其发起了冲击，并提出“刑罚止于一身”的思想。资产阶级革命胜利后，罪责自负正式成为刑法的基本原则，宣告了株连无辜的专制主义刑罚制度彻底崩溃。

（二）

罪责自负原则的立法体现

罪责自负原则在我国刑法中具体体现为：（1）明确规定了犯罪的概念和犯罪构成的共同要件，原则上划清了罪与非罪的界限，从而为无辜者不受刑事追究提供了法律保障。（2）明确规定了共同犯罪的条件和处罚原则，对于主犯、从犯、胁从犯和教唆犯，应当根据他们在共同犯罪中的实际地位和作用进行处罚。

对于没有共同犯罪故意或者根本未参加任何犯罪活动的人，不能以共同犯罪论处。（3）

明确规定了各种刑罚的适用对象，从根本上排除了株连无辜的可能。例如，《刑法》第59条规定：“没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。”

没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。

在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。”（4）

明确规定了各种犯罪的主体范围，以防止株连无辜。

第一 巨基本原则

（三）

罪责自负原则的司法适用

我国在刑事立法上坚持罪责自负原则，反对株连。

这一立法精神要求司法机关在刑事诉讼活动中，必须注意下列问题：（I）对所有刑事案件的侦

查、起诉和审判，都必须深入实际调查研究，做到事实清楚、证据确实充分，防止错捕、错判，切实保障无罪者不受刑事追究。（2）对共同犯罪案件中各被告人刑事责任的确定，应当以共同犯罪人预谋范围内的犯罪为依据，令被告人承担共同犯罪的刑事责任；对超出共同预谋范围的犯罪，应当由实行者本人对该罪独立承担责任，其他未参与此罪的人，不应对该罪负责。（3）对单位犯罪案件的处理，应严格依照刑法的规定追究单位及其直接负责的主管人员和其他直接责任人员的刑事责任，不能把单位的其他成员作为承担刑事责任的主体，对其定罪判刑。（4）对于法律明文规定犯罪主体范围的犯罪，要严格依法办案，不能随意扩大犯罪主体的范围，以防累及无辜。

主客观相统一原则

（一）

主客观相统一原则的含义

主客观相统一原则是 20 世纪四五十年代苏联刑法学家运用马克思主义方法论在建构四要件犯罪构成理论的过程中提出来的刑法基本原则，其含义是：对被告人追究刑事责任，必须同时具备主客观两方面条件，并要求主客观两方面条件有机统一。缺少其中任何一方面的条件，犯罪就不能成立，就不能要求被告人承担刑事责任。

主客观相统一原则与奴隶制和封建制刑法中的主观归罪和客观归罪相对立。

主观归罪把犯罪意思作为犯罪成立的基本条件，把人身危险性、反社会性格、犯罪动机等主观因素作为认定犯罪和适用刑罚的标准。至于是否实施了危害社会的行为，行为是否造成了危害社会的结果，行为和结果与被告人的主观心理状态之间有无联系，则不影响犯罪的成立。而客观归罪则把客观上发生的实际危害作为犯罪的基本要件，认为只要有危害行为或者发生了危害后果即应严惩，至于行为人在主观上是否有认识，则不予理会。主客观相统一原则既不是对主观归罪和客观归罪的简单否定，也不是将二者简单地加以调和或折中，而要求只有主客观要素齐备，才能追究被告人的刑事责任。

（二）

主客观相统一原则的立法体现

主客观相统一原则在我国刑法中得到了充分的贯彻和体现，具体而言：（1）《刑法》第 14 条和第 15 条明文规定了故意犯罪和过失犯罪的概念，说明任何一种犯罪的成立，都必须具备故意或过失的心理状态。（2）《刑法》第 16 条明文规定：“行为在客观上虽然造成了损害结果，但是不是出于故意或者过失，而是由于不能抗拒或者不能预见的原因所引起的，不是犯罪。”进一步明确了对缺乏犯罪主观要件的不可抗力事件与意外事件，不能加以客观归罪。（3）《刑法》第 18 条第 1 款明文规定：“精神病

人在不能辨认或者不能控制自己行为的时候造成危害结果，经法定程序鉴定确认的，不负刑事责任，……“其根据就在于精神病人在主观上没有犯罪的故意或过失。（4）《刑法》第20条和第21条分别规定了正当防卫和紧急避险行为不负刑事责任，原因在于这两种行为客观上没有社会危害性，行为人主观上也没有犯罪的故意或过失，而是基于正当合法的目的进行防卫或避险。（5）《刑法》第22-24条规定了预备犯、未遂犯和中止犯，排除了犯意表示行为的犯罪性，表明了我国刑法不惩罚思想犯的立场。（6）刑法分则条文明确规定了各种具体犯罪构成在主客观方面的条件。

（三）

主客观相统一原则的司法适用

根据主客观相统一原则，在司法实践中贯彻实施这一原则，必须注意以下两个问题：（1）坚决反对主观归罪。主观归罪在司法实践中主要有两种表现形式：一是把错误思想或犯意表示当作犯罪处理，如对声言要报⑨杀人但尚未实施任何杀害行为的人以故意杀人罪予以逮捕等。二是把事前的犯意当作事中的犯意，以事前的犯意定罪判刑。例如，行为人事前预谋杀人，但实施行为时改变犯意，而实施故意伤害行为，但对其仍以故意杀人罪（未遂）论处。

可见，主观归罪的危害包括：一是导致惩罚思想犯，二是混淆犯罪的性质。无论何种情况，都是对主客观相统一原则的破坏，因而必须坚决予以反对。（2）

坚决反对客观归罪。客观归罪在司法实践中也有两种表现形式：一是一味强调行为、结果的客观危害性，将缺乏犯罪主观要件的意外事件认定为过失犯罪。二是依行为造成的实际结果确定犯罪性质，而忽视行为人对结果所持的真实⑩心理状态。例如，只要发生了死亡结果，就按故意杀人罪或过失致人死亡罪处理，而行为人很可能构成故意伤害（致死）罪。

可见，客观归罪的实质是忽视或根本不考虑行为人的主观认识情况，唯行为、唯结果定罪处刑。这种割裂犯罪构成主客观要件的做法，也是违背主客观相统一原则的，应当坚决予以摒弃。

崖媚 言卧知识点阐释 思考案例 法考真题第一思考题

1. 如何理解刑法基本原则的概念与意义？
1. 为什么说保障人权原则也是刑法的基本原则？
1. 什么是罪刑法定原则？如何贯彻落实罪刑法定原则？
1. 适用刑法人人平等原则的基本要求有哪些？
1. 如何在立法和司法实践中贯彻罪责刑相适应原则？
1. 如何理解罪责自负原则？
1. 如何理解主客观相统一原则？

第三华刑法的效力刑法的效力，也叫刑法的适用范围，是指刑法在什么地方、对什么人以及在什么时间具有效力。

从上述定义可见，刑法的效力范围包括刑法的空间效力和刑法的时间效力。

第一节 刑法的空间效力

刑法空间效力的概念和原则刑法的空间效力，是指刑法在什么地方和对什么人具有效力。易言之，即刑法对何地与何人能够适用。关于刑法的空间效力，有以下几种不同的处理原则：

（一）

属地原则

属地原则，也叫属地主义，或称领土原则。

该原则以犯罪发生地为标准确定刑法的空间效力。

即凡在本国领域内犯罪的，

一律适用本国刑法；凡不在本国领域内犯罪的，一律不适用本国刑法。该原则较好地维护了国家主权，但如果仅仅规定该项原则，本国人在本国领域外犯罪的，将不能适用本国刑法，这不利于促使本国入更好地遵守本国刑法；外国人在本国领域外针对本国国家或本国公民犯罪，侵害了本国国家或本国公民利益的，也不能适用本国刑法，不利于保护本国利益。

（二）

属人原则

属人原则，也叫属人主义，或称国籍原则。

该原则以犯罪人的国籍为标准确定刑法的空间效力。即凡是本国人犯罪的，不管犯罪行为发生在本国领域内还是本国领域外，一律适用本国刑法；凡是外国人犯罪的，不管犯罪地在本国领域之内还是本国领域之外，一律不适用本国刑法。该原则有利于使本国公民遵守本国法律，但如果仅仅规定该原则，外国人在本国领域内犯罪的，将无法适用本国刑法，有损国家的主权；外国人在本国领域外实施的犯罪行为侵害了本国国家或本国公民利益的，也将无法适用本国刑法，不利于保护本国利益。

（三）

保护原则

保护原则，也叫保护主义，或称自卫原则。

该原则以保护本国利益为标准确定刑法的空间效力。即凡是侵害本国国家或者本国公民利益的犯罪，不管行为发生在何处，也不管行为是否由本国公民实施，一律适用本国刑法；凡是没有侵害F法3J效力本国国家或本国公民利益的犯罪，一律不适用本国刑法。该原则有利千保护国家利益，但若单纯规定保护原则，外国人在本国犯罪而未侵犯本国国家或本国公民利益的，不能适用本国

刑法，有损国家的司法主权；本国犯罪而未侵犯本国国家或本国公民利益的，也不适用本国刑法，这既有损于国家司法主权，也不利于促使本国公民遵守本国刑法；对于在国外实施的侵害本国国家或者本国公民利益的犯罪，一般也很难追究其责任。

（四）

普遍管辖原则

普遍管辖原则，是指当一个国家既不是犯罪行为的发生地国，也不是行为人和受害人的国籍国，甚至也不是犯罪行为的受害国时，该国仅基于行为人所犯的罪行是严重的国际罪行而对该案件具有刑事管辖权。一个国家基于属地原则、属人原则或保护原则对犯罪行使管辖权，要求该国必须是犯罪行为的发生地国，或者是行为人和受害人的国籍国，或者是犯罪行为的受害国。这些连接点或连接因素，是一国行使管辖权的前提和基础。普遍管辖的特殊性在于，一个国家与犯罪并没有上述连接点或连接因素，而是基于对“绝对实质正义”的追求对犯罪进行管辖。

普遍管辖权包括有限的普遍管辖权与绝对的普遍管辖权。有限的普遍管辖权，是指一个与犯罪没有任何具体连接点或连接因素的国家要对该犯罪行使管辖权，必须以行为人出现在该国或者在该国被拘捕或被控制为前提。从某个角度，也可以将行为人出现在该国或者在该国被拘捕或被控制视为有限的普遍管辖的连接点。绝对的普遍管辖权，是指即使一个国家既不是犯罪行为地国，也不是行为人和被害人的国籍国，犯罪行为也没有侵害到本国利益，甚至行为人未在该国出现或未在该国被逮捕，一个国家也可以对该种犯罪行使管辖权。

绝对的普遍管辖可以说与具体发生的案件没有任何连接因素。^⑩在公海上，或在任何国家管辖范围以外的任何其他地方，每个国家均可扣押舟盗船舶或飞机或为居盗所夺取并在海盗控制下的船舶或飞机，以及逮捕船上或机上人员并扣押船上或机上财物。

扣押国的法院可判定应处的刑罚，并可决定对船舶、飞机或财产所应采取的行动，但受善意第三者的权利的限制。就居盗罪而言，《联合国启库法公约》明文规定各个国家在公海上或者任何国家管辖范围以外的其他地方都可以抓捕海盗及海盗船舶自行审判，即便案件的发生与该国没有任何关系，行为人也及有在该国出现或在该国被抓捕。这意味着公约对海盗犯罪明确规定了绝对的普遍管辖权。

而针对国际犯罪的刑事管辖权，主要指的是有限的普遍管辖权。

基于国际犯罪危及人类共同利益，从纽伦堡原则到《国际刑事法院规约》，国际社会确立了对国际犯罪的有限普遍管辖原则。有限普遍管辖原则确立之基本目的在于防止国际罪行免于处罚。世界上每个主权国家都有权对国际犯罪实行刑事管辖，而不论这种犯罪是否在本国领土内发生，不论是否由本国国民实施，也不论是否侵害本国国家或本国国民的利益，只要罪犯在其领土之内被发现即可；

对于在本国领土之内发现的国际罪行，
每个国家都应当把犯罪人引渡给有权并要求对其进行惩罚的国家，
如果不予引渡，
则应按照国内法对其进行惩罚。

节刊法约 85

（五）

折中原则

折中原则，也叫折中主义，或称综合原则、混合原则。

上述各原则都既有优点，又有缺点，于是就产生了折中原则。

折中原则是以属地原则为基础，以属人原则、保护原则和普遍管辖原则为补充的原则。该原则主张，凡在本国领域内犯罪的，一律适用本国刑法；本国人或外国人在本国领域外犯罪的，有条件地适用本国刑法。现代多数国家都采用折中原则，我国也如此。

我国刑法的属地管辖权《刑法》第

6

条规定：“凡在中华人民共和国领域内犯罪的，除法律有特别规定的以外，都适用本法。

凡在中华人民共和国船舶或者航空器内犯罪的，也适用本法。犯罪的行为或者结果有一项发生在中华人民共和国领域内的，就认为是在中华人民共和国领域内犯罪。”该条文体现了属地管辖的精神。

（一）

关于“领域”

1. 领域的含义。领域包括领陆、领水、领陆和领水的底土以及领空。领陆，

指国家疆界以内的所有陆地领土，包括大陆、岛屿。领水，包括内水和领海。内水，指国境线以内的河流、运河、湖泊、内海、内海峡；领海，指与一国陆地领土或者内水相连的、

一定宽度的海水带。根据我国《领海及毗连区法》的规定，我国的领海宽度为 12

海里，即从领海基线向外延伸 12 海里的水域是我国的领海。

领陆和领水的底土在理论上直至地⑩。

领空，指领陆和领水的上空，其最高边缘为大气层的上边缘，不包括外层空间。

1. 领域的拟制。船舶和航空器在国际法上被称为“拟制领土”。根据我国

《刑法》的规定，凡是在中华人民共和国船舶和航空器上犯罪的，适用我国刑法。理论上认为，国有船舶和公有船舶属于拟制领土的范围，无论在行驶时还是停泊时，也无论停泊在什么地方，都属于我国的领土。私有船舶进入一国领水的，应当适用进入国法律；在公海上行驶的，适用船旗国法律，因此，私有船舶并不属于拟制领土。

飞机等航空器只能在所有权人的国家注册，不存在挂何国国旗的问题。

无论飞机是国有、公有还是私有，均属于拟制领土。

1. 领域的虚拟。 这是指与现实领域相对的虚拟领域，即网络空间问题。网

络空间是传统领域（即领水、领陆、领空）以及拟制领域（即船舶、航空器）

之外的所谓“第五空间”。 对于“第五空间”刑事管辖的确定宜采用何种原则，应如何适用法律，现行刑法并未涉及，理论界也见解不一，值得深入探索。

对于领域的理解，以下两个问题值得注意：

1. 关于使领馆问题。 西方一些学者将使领馆也作为拟制领土，我国刑法学

界也有人持该观点，但这种观点并没有法律根据。 我国于 1975 年加入的《维也纳领事关系公约》虽然规定使馆馆舍不容侵犯，但该公约第 41 条第 3 款又规定，使馆馆舍不得充作与使馆职务不相符合的用途——主要指在馆舍内庇护人或抓捕人。 有关国际法院的判决表明，使馆馆舍并不是派遣国领土的延伸部分，在其内发生的犯罪行为，应视为发生在接受国的领土上。 虽说当罪犯是外交或领事人员时，由于罪犯在驻在国可能享有外交特权和豁免权或领事裁判权和豁免权，一般由派遣国行使刑事管辖权；而对于非使馆人员涉嫌在使领馆内犯罪的，派遣国可能根据具体情形行使属人管辖权或保护管辖权，但派遣国无权行使属地管辖权。

对于在使馆避难的罪犯，应交给接受国司法机关，否则便是对接受国主权的侵犯。

可见，在国际法上，使馆馆舍并不属于派遣国的领土。 我国刑法也未规定在我国驻外国使领馆馆舍内犯罪应适用我国刑法，这表明我国不承认使领馆是派遣国领土的延伸部分。

1. 关于犯罪地问题。 如何认定行为人在本国领域内犯罪？换言之，应以什

么因素为标准确定犯罪发生在本国领域内？这就涉及犯罪地的确定问题。

对此，有以下观点和立法例： （1）行为地说。 该说认为犯罪行为实行之地，就是犯罪地。

即只有犯罪行为发生在本国领域内，才可认为在本国领域内犯罪。 （2）结果地说。

该说认为犯罪结果发生之地，就是犯罪地。

即只有危害结果发生在本国领域内，才可认为在本国领域内犯罪。 （3）

中间地说，又称中间现象地说、中间影响地说、中间结果地说。 该说认为实施犯罪行为与发生危害结果之间增加结果发生危险的地点，是中间犯罪地，故中间影响地或中间结果地也是犯罪地。

（4）遍在地说，又叫混在说，或称折中说、综合说。

该说认为行为实施地与结果发生地都是犯罪地。

行为或结果只要有一项发生在本国领域内，就是在本国领域内犯罪。

《刑法》第6条第3款规定：“犯罪的行为或者结果有一项发生在中华人民共和国领域内的，就认为是在中华人民共和国领域内犯罪。”可见，我国刑法在犯罪地的确定上采用的是遍在地说。

（二）

关于“法律有特别规定”

根据《刑法》第6条的规定，行为或结果虽然发生在我国领域内，但如果法律对此有特别规定，则应适用法律的特别规定。法律的特别规定主要包括以下几种情况：

1. 享有外交特权与豁免权的外国人的刑事责任，通过外交途径解决。《刑

法》第11条对此作了明确规定。所谓外交特权与豁免权，是指根据国际法，在国家间互惠的基础上，为使外国的外交代表在驻在国能够有效地执行职务，由驻在国给予的特殊权利和待遇。其通常包括：代表的人身、馆舍和公文档案不受侵犯，代表享有司法豁免权、通信自由权，免除捐税，以及其他特权。我国于1986年7月列法的87年9月5日通过的《外交特权与豁免权条例》详细地规定了外交特权与豁免权问题。根据该条例的规定，外交代表享有的特权与豁免权有：外交代表人身不受侵犯，不受逮捕或者拘留；外交代表的寓所不受侵犯，并受保护；外交代表享有刑事管辖豁免；外交代表免交捐税；外交代表免除一切个人和公共劳务以及军事义务。此外，与外交代表共同生活的配偶和未成年子女，如果不是中国公民，享有与外交代表相同的特权与豁免权；使馆行政技术人员和与其共同生活的配偶、未成年子女，如果不是中国公民并且不在中国永久居住，也基本享有与外交代表相同的特权与豁免权；来中国访问的外国国家元首、政府首脑、外交部长及其他具有同等身份的官员，享有该条例所规定的特权与豁免权。所以，这些人员如果在我国实施犯罪行为，应当通过外交途径解决，如宣布其为不受欢迎的人，令其限期出境，建议派遣国依法处理，其中犯罪严重的，可以由政府宣布驱逐出境，等等。

1. 我国香港特别行政区、澳门特别行政区以及我国台湾地区的特殊情况。

根据“一国两制”方针，在对香港、澳门恢复行使主权之后，香港、澳门的政治、经济制度不变，法律制度基本不变。香港特别行政区、澳门特别行政区享有行政管理权、立法权、独立的司法权和终审权，全国性的刑法不适用于两地。我国台湾地区现行所谓的“刑法典”仍然是国民党政府1935年制定的刑法。

1. 民族自治地方的特别规定。《刑法》第90条规定：“民族自治地方不能全

部适用本法规定的，可以由自治区或者省的人民代表大会根据当地民族的政治、经济、文化的特点和本法规定的基本原则，制定变通或者补充的规定，报请全国人民代表大会常务委员会批准施行。”

1. 特别刑法的特别规定。特别刑法是以独立于刑法典的形式存在，适用于特定时间、特定地域和特定范围，或者针对特定对象或特定领域的刑法。在我国，单行刑法和附属刑法都属于特别刑法。特别刑法有特别规定时，应当按照特别法优于一般法的原则，适用特别刑法的规定。

我国刑法的属人管辖权《刑法》第7条规定：“中华人民共和国公民在中华人民共和国领域外犯本法规定之罪的，适用本法，但是按本法规定的最高刑为三年以下有期徒刑的，可以不予追究。中华人民共和国国家工作人员和军人在中华人民共和国领域外犯本法规定之罪的，适用本法。”该条文体现了属人管辖的精神。

我国公民在我国国内犯罪的，当然适用我国刑法。这既是属地原则的要求，也是属人原则的要求。

我国公民在我国领域外犯罪的，是否适用我国刑法，根据《刑法》第7条的规定，分为两种情况：

第二章 严法

1. 中华人民共和国国家工作人员和军人在我国领域外犯我国刑法规定之罪

的，一律适用我国刑法。因为国家工作人员和军人身份特殊，承担着更高的守法义务，他们在国外犯罪，会给我国的国家形象及声誉带来极为恶劣的影响，给我国日益频繁的国际交往造成损害，所以他们在我国领域外仍然应当像在国内一样遵守我国的法律，在国外犯任何罪，都应当适用我国刑法。

1. 军人和国家工作人员以外的人员在我国领域外犯我国刑法规定之罪的，

同样适用我国刑法，但是，如果所犯之罪的法定最高刑在 3 年有期徒刑以下的，可以不予追究。

这说明，我国普通公民在国外犯我国刑法规定之罪的，如果符合所犯之罪的法定最高刑为 3 年以下有期徒刑的条件，可以不予追究。上述规定，在有力地捍卫国家主权的同时，兼顾了属人原则在具体适用中可能出现的种种⑨杂情况。因此，在主张刑事管辖权的前提下，这类案件如果不予追究更符合实际情况的，我国司法机关依法可以不予追究。在现代社会，一国公民的人身或财产在国外遭受损害的，该国也有义务依国内法予以保护；相应地，该国公民居住在国外时也应遵守本国的法律。但是，居住在外国的本国公民情况比较⑨杂，有的长期居住在国外，有的〔人小在国外长大，国外的环境、形势同国内有重大差别，他们未必熟悉或者了解国内法的规定，因此他们的守法义务应当和居住在国内的公民有所区别。

正因如此，我国刑法结合他们的实际情况，作出了以上规定。

我国刑法的保护管辖权《刑法》第 8 条规定：“外国人在中华人民共和国领域外对中华人民共和国国家或者公民犯罪，而按本法规定的最低刑为三年以上有期徒刑的，可以适用本法，但是按照犯罪地的法律不受处罚的除外。”该条文体现了保护管辖的精神。

外国人在我国领域外犯我国刑法规定之罪的，我国刑法也具有管辖权，这对于保护我国国家及我国公民的利益，当然是极其有利的。但是，由于罪行发生在国外，罪犯既不是我国公民又不在我国境内，要贯彻这一原则是有现实困难的。

同时，保护管辖权毕竟是对在国外犯罪的外国人行使管辖权，如果把握失当，极有可能损害有关国家的主权，危及国际关系。

这正是各国在采用保护管辖原则时，一般均在法律上设置一定限制的原因，我国也不例外。根据

《刑法》第 8 条规定，外国人在我国领域外犯罪，适用我国刑法应具备以下条件：（1）

侵害了我国国家或者我国公民的利益，并且已经构成犯罪；（2）

依我国刑法规定，所犯之罪的法定最低刑为 3 年以上有期徒刑；（3）

依照犯罪地的法律也构成犯罪。

然而，即使犯罪人的行为符合我国刑法规定的上述三个条件，我国对其予以刑事追究，还要受到客观情况的极大限制。因为只要犯罪的外国人不是中国公民，不是在中国境内被拘捕，我国在事实上就很难实现保护管辖权。犯罪地不在我国领域内，犯罪人也没有我国国籍，通过外交途径、司法途径予以引渡同样不易办到。

但是，我国作为一个主权国家，为了维护国家安全，保护国家和公民的利益不受侵犯，在刑法上设立保护管辖权还是很有必要的。

我国刑法的普遍管辖权我国《刑法》第9条规定的普遍管辖权，主要指的是有限的普遍管辖权，而不是绝对的普遍管辖权。其适用应满足以下三个条件：（1）必须是中华人民共和国缔结或者参加的国际条约规定的罪行。一些国际条约规定了某些侵害国际共同利益的犯罪，包括：战争犯罪，如侵略罪、战争罪、使用禁用武器罪等；危害人类生存和尊严的犯罪，如种族灭绝罪、种族隔离罪等；危害国际交往秩序的犯罪，如杀害外交使节罪、袭击外国元首罪等；危害国际生活秩序的犯罪，如海盗罪、恐怖行为罪、毒品犯罪等。只能对这些犯罪行使普遍管辖权。（2）必须在中华人民共和国所承担的条约义务范围内。我国加入一些国际条约时，有时会对某些条文声明保留，对于声明保留的条文中规定的义务，我国不予履行。（3）原则上，这些犯罪行为进入我国领域或被我国发现的，我国有权力也有义务将其缉拿归案，并遵照“或引渡或起诉”原则，对其进行刑事管辖。

管辖冲突问题在适用我国刑法有关上述刑事管辖的规定时，不可避免地会遇到管辖冲突的问题，主要发生在对跨国犯罪或国际犯罪进行管辖时。

管辖冲突包括事实上的管辖冲突和法律上的管辖冲突。

（一）

事实上的管辖冲突

我国公民在我国领域外犯罪，应受我国刑法属人管辖权的管辖；外国公民在我国领域外对我国国家或者我国公民犯罪，也应受我国刑法保护管辖权的管辖，但同时他们也受犯罪地所在国的属地管辖权或者犯罪人所在国的属人管辖权的管辖，有的甚至已经被犯罪地国或犯罪人国的法律处罚了。这不仅涉及刑事管辖权的冲突问题，也涉及对外国审判是否认可的问题，更涉及一个国家的主权问题。

对此，我国《刑法》第10条明文规定：“凡在中华人民共和国领域外犯罪，依照本法应当负刑事责任的，虽然经过外国审判，仍然可以依照本法追究，但是在外国已经受过刑罚处罚的

，可以免除或者减轻处罚。”该条规定表明，我国是一个独立自主的主权国家，有独立的刑事审判权，不受外国审判效力的约束，不能因为犯罪行为已受外国审判，我国就放弃对该犯罪的管辖权，即使犯罪行为已受外国审判，我国仍然保留刑事管辖权。当然，考虑到犯罪分子已经受过刑罚处罚的实际情况，我国《刑法》规定“可以免除或者减轻处罚”。该条规定的“经过外国审判”，是指经过了外国法院的审理，并已作出了生效判决。既包括外国法院作出的无罪判决，也包括有罪判决；既包括给予刑事处罚的判决，也包括免予刑事处罚的判决。该条规定的“可以依照本法追究”，是指对犯罪分子，根据我国刑法的规定和案件的具体情况，可以追究其刑事责任，也可以不予追究。

也就是说，要不要追究犯罪分子的刑事责任，由我国司法机关根据我国的需要来决定。

（二）

法律上的管辖冲突

当某一犯罪既为我国刑法所规定，可以适用《刑法》第 6—8 条分别规定的属地原则、属人原则和保护原则，又为国际条约所规定，可以适用我国《刑法》第 9 条规定的普遍管辖原则时，属地原则等与普遍管辖原则就有可能发生冲突，如发生在我国领空的劫持航空器的犯罪。

解决这一管辖冲突的原则是优先适用属地原则等。这是因为：（1）

该行为是我国刑法规定的犯罪行为，按照国家司法主权原则，当然应优先适用我国刑法的规定；

（2）在这种情况下，优先适用我国刑法，既直接便利，又节约资源。

第二节 刑法的时间效力

刑法的时间效力，是指刑法的生效时间、失效时间以及刑法是否具有溯及力的问题。

刑法的生效时间刑法的生效时间，是指刑法从什么时间开始具有法律效力。只有在发生法律效力之后，刑法规范才能对人们的行为起到规制作用，司法机关才能适用该刑法规范，作为定罪量刑的根据。从我国的刑事立法活动看，刑法的生效时间包括两种：

（一）自公布之日起生效

在 1997

年《刑法》实施之前，我国颁布的所有单行刑法都采用这种方式，如《关于禁毒的决定》第 16 条规定：“本决定自公布之日起施行。”1997

年《刑法》实施后，我国立法机关对《刑法》进行了 11 次修正，前 7

次修正活动在生效时间问题上采用的也是自公布之日起生效的方式。

（二）

公布后过一段时间才生效

对于条文众多、内容⑨杂的刑事法律，如果自公布之日起生效，往往无法使司法人员准确地理解法律的含义，也不能使公民学习、领会其内容，这必然会影，弟!., --一L, -- • • 了+J+ • • 目入】 i'、1 、... 91响法律的执行效果。

所以，对于这样的法律，立法者一般都采用公布后过一段时间才生效的方式。 如 1979 年《刑法》是 1979 年 7 月 6 日公布的，其生效时间是1980 年 1 月 1 日； 1997 年《刑法》是 1997 年 3 月 14 日公布的，其生效时间是1997 年 10 月 1 日。

刑法的失效时间刑法的失效时间，是指刑法从什么时候开始不再具有法律效力。刑法在失去法律效力后，对于新发生的犯罪行为，不再适用。一般而言，新的法律生效的时间，就是旧的法律失效的时间。关于刑法的失效，从我国刑事立法的情况看，主要有两种方式：

（一）

明示废止

即以立法的方式明确宣布旧的法律失去法律效力。 如 1997 年《刑法》 第452 条规定，列于附件一的 《惩治军人违反职责罪暂行条例》 等 15 项单行刑法已纳入新《刑法》或不再适用，自新 《刑法》生效之日起，予以废止；列于附件二的 《关于禁毒的决定》 等 8 项补充规定中有关行政处罚和行政措施的规定继续有效，有关刑事责任的规定则予以废止。又如， 1999 年 《刑法修正案》 第 2 条对 1997 年 《刑法》第 168 条的规定作了修正，代之以新的条文，原来规定的徇私舞弊造成破产、亏损罪在该修正案生效之后就不再适用。

（二）

默示废止

即立法中虽然没有明确地废止旧法，但因为旧刑法的规定或者与新刑法的规定相抵触，或者已经为新刑法所取代，所以旧刑法自然予以废止。 如在 1997 年《刑法》 实施之前，我国在《海关法》《专利法》 等非刑事法律中规定了单位走私罪、假冒专利罪等一些附属刑法条款，1997 年 《刑法》 并没有专门对其是否失效的问题作出规定，但随着 1997 年《刑法》 的实施，这些附属刑法自然废止。

又如 1987 年全国人大常委会通过的 《关于对中华人民共和国缔结或者参加的国际条约所规定的罪行行使刑事管辖权的决定》 的时间效力问题，也没有在 1997 年 《刑法》第 452 条中予以明确规定，但是因为其内容已经为 1997 年 《刑法》第 9 条所吸收，所以在 1997 年 《刑法》

生效之后，该单行刑法自然就被废止。

刑法的溯及力

（一）

刑法的溯及力的概念和原则

刑法的溯及力，是指新的刑事法律生效后，对其生效以前发生的未经审判或者判决未确定的行为是否适用的问题。

如果适用，新的刑法就具有溯及力；如果不适用，新的刑法就不具有溯及力。

92 严1法召，效力在刑法的溯及力问题上，世界各国刑事立法选择的原则主要有如下四种：

1. 从旧原则。即新的法律不具有溯及力，对于任何犯罪行为，无论新旧法律的规定如何，一律适用行为时的法律。

1. 从新原则。即新的法律具有溯及力，对于新法生效前发生的未经审判或者判决未确定的行为，无论新旧法律的规定如何，一律适用新的法律。

1. 从旧兼从轻原则。即新法原则上不具有溯及力，对于新法生效前发生的未经审判或者判决未确定的行为，原则上适用旧法，但当适用新法对被告人有利时，则适用新法。

1. 从新兼从轻原则。即新法原则上具有溯及力，对于新法生效前发生的未经审判或者判决未确定的行为，原则上适用新法，但当适用旧法对被告人有利时，则适用旧法。

现代各国在刑法的溯及力问题上大多采用从旧兼从轻原则。

罪刑法定原则要求“法无明文规定不为罪，法无明文规定不处罚”。由于行为时尚没有相应的新法律或者新法律还没有生效，如果采用从新原则，将会把行为时法无明文规定的行为认定为犯罪，并根据行为时尚无明文规定的法律量刑，违反了罪刑法定原则。但是，如果绝对采用从旧原则，对于新的法律不认为是犯罪的行为或者根据新的法律处罚较轻的行为，在定罪处罚时适用旧法就会对被告人十分不利，从而与罪刑法定原则保障人权的宗旨发生冲突。

所以，对于从旧原则也应作适当修正，以更好地实现刑法保障人权的机能。

这样，从旧原则也就演变为从旧兼从轻原则。

（二）

我国刑法关于刑法的溯及力的规定

《刑法》第12条规定：“中华人民共和国成立以后本法施行以前的行为，如果当时的法律不认为是犯罪的，适用当时的法律；如果当时的法律认为是犯罪的，依照本法总则第四章第八节的规定应当追诉的，按照当时的法律追究刑事责任，但是如果本法不认为是犯罪或者处刑较轻的，适用本法。本法施行以前，依照当时的法律已经作出的生效判决，继续有效。”根据该规定，我国刑法在溯及力问题上，采用从旧兼从轻原则。具体表现为以下四种情形：

1. 行为时的法律不认为是犯罪，新的法律认为是犯罪的，适用行为时的法律，不能根据新的法律规定追究行为人的刑事责任。

1. 行为时的法律认为是犯罪，新的法律也认为是犯罪，并且在追诉期内的，适用行为时的法律，但是新的法律对该行为规定的法定刑与旧的法律对该行为规定的法定刑相比较轻时，适用新的法律的规定。

其中，法定刑较轻指法定最高刑较轻；如果法定最高刑相同，则指法定最低刑较轻。如果某种犯罪只有一个法定刑幅度，法定最高刑、法定最低刑指该幅度的最高刑、最低刑；如果有两个以上第二档次，法定最高刑、法定最低刑指该幅度的最高刑、最低刑。如果法定最高刑为无期徒刑或死刑的，法定最低刑指对具体犯罪行为应当适用的法定刑幅度的最高刑、最低刑。

1. 行为时的法律认为是犯罪，新的法律不认为是犯罪的，适用新的法律，不能根据行为时法律的规定追究行为人的刑事责任。

1. 新的法律生效以前，依照当时的法律已经作出的生效判决，继续有效。也就是说，从旧兼从轻原则不适用于已经作出的生效判决。

在1997年《刑法》生效之后，我国立法机关先后以1部单行刑法、11部刑法修正案修正了刑法。

在单行刑法及有关修正案的时间效力问题上，也应该采用从旧兼从轻原则。

为了正确地适用1997年《刑法》，最高人民法院发布了有关司法解释。对于新刑法适用中涉及时间效力的一些疑难问题作了详细的规定。根据这一解释，在实践中应注意以下问题：

1. 对于行为人1997年9月30日以前实施的犯罪行为，在司法机关立案后，行为人逃避侦查或者审判，超过追诉期限或者被害人在追诉期限内提出控告，司法机关应当立案而不立案，超过追诉期限的，是否追究行为人的刑事责任，适用旧《刑法》第77条的规定。

1. 犯罪人在1997年9月30日以前犯罪，不具有法定减轻处罚情节，但是根据案件具体情况需要在法定刑以下判处刑罚的，适用旧《刑法》第59条第2款的规定。

1. 前罪判处的刑罚已经执行完毕或者被赦免，在 1997 年 9 月 30 日以前又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是否构成累犯，适用旧《刑法》第 61 条的规定；1997 年 10 月 1 日以后又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是否构成累犯，适用新《刑法》第 65 条的规定。

1. 1997 年 9 月 30 日以前被采取刑事强制措施的人或者在 1997 年 9 月 30 日以前犯罪，1997 年 10 月 1 日以后仍在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人犯罪的，适用新《刑法》第 67 条的规定。

1. 1997 年 9 月 30 日以前犯罪的人，有揭发他人犯罪行为，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，适用新《刑法》第 68 条的规定。

1. 1997 年 9 月 30 日以前犯罪被宣告缓刑的犯罪分子，在 1997 年 10 月 1 日以后的考验期内又犯新罪，被发现漏罪，或者违反法律、行政法规或者国务院公安部门有关缓刑的监督管理规定，情节严重的，适用新《刑法》第 77 条的规定。

1. 1997 年 9 月 30 日以前犯罪，1997 年 10 月 1 日以后仍在服刑的犯罪分子，少参见最高人民法院 1997 年《关于适用刑法时间效力规定若干问题的解释》。

1. 第一草案刑法包效力因特殊情况，需要不受执行刑期限限制假释的，适用新《刑法》第 81 条第 1 款的规定，报经最高人民法院核准。

1. 1997 年 9 月 30 日以前犯罪，1997 年 10 月 1 日以后仍在服刑的累犯以及因杀人、爆炸、抢劫、强奸、绑架等暴力性犯罪被判处 10 年以上有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，适用旧《刑法》第 73 条的规定，可以假释。

1. 1997 年 9 月 30 日以前被假释的犯罪人，在 1997 年 10 月 1 日以后的考验期内，又犯新罪，被发现漏罪，或者违反法律、行政法规或者国务院公安部门有关假释的规定的，适用新《刑法》第 86 条的规定，撤销假释。

1. 按照审判监督程序重新审判的案件，适用行为时的法律。

（三）

立法解释和司法解释的溯及力问题

对于刑法的有权解释，同样存在溯及力的问题。具体而言，包括以下两个问题：（1）立法解释或司法解释能否适用于其生效之前的犯罪行为？（2）犯罪行为发生后立法解释或司法解释出现变更的，应当适用新解释还是旧解释？对于第一个问题，较为通行的观点认为，无论是

立法解释抑或司法解释，其实质上都是对刑法条文的阐释和明确，而非对刑法的修改和补充，因此应当认为立法解释和司法解释的精神旨意，本就蕴含于刑法条文之中。而刑法溯及力的相关规定，从根本上来说是为了保证刑法的可预见性，即确保公民在其行为当时能够规避不利后果，作出适法行为，最终实现刑法的人权保障机能。因此，在犯罪行为发生后出台的有权解释，并没有超出行为人对其行为后果的预见范围，故而原则上来说，有权解释的适用应当延及其所解释规范的全部施行时间。

《最高人民法院、最高人民检察院关于适用刑事司法解释时间效力问题的规定》（以下简称《时间效力规定》）第2条规定：“对于司法解释实施前发生的行为，行为时没有相关司法解释，司法解释施行后尚未处理或者正在处理的案件，依照司法解释的规定办理。”这意味着最高人民法院和最高人民检察院也认可了司法解释具有溯及力。

对于第二个问题，《时间效力规定》第3条规定：“对于新的司法解释实施前发生的行为，行为时已有相关司法解释，依照行为时的司法解释办理，但适用新的司法解释对犯罪嫌疑人、被告人有利的，适用新的司法解释。”该条规定表面上因适用了从旧兼从轻原则，与第2条规定存在一定冲突。但实际上，如果旧解释认为某行为不是犯罪，而新解释认为该行为构成犯罪，适用旧解释的原因是行为人在行为时并不存在违法行为认识可能性，而非适用“从旧原则”；反过来，旧解释认为某行为是犯罪，而新解释认为该行为不构成犯罪，适用新解释的原因是新解释对刑法条文作出了正确的理解，而非适用“从轻原则”。上述理由对立法解释一样成立。

思考题 □ 拓展学习 知识点阐释 思考案例 法考真题思考题

1. 什么是刑法的空间效力？我国刑法对空间效力作了哪些规定？

1. 为什么我国刑法对于溯及力问题采取从旧兼从轻原则？

第四章 犯罪概念与犯罪构成

第一节 犯罪概念

犯罪概念是对犯罪特征的概括和抽象，旨在从一般意义上解决“什么是犯罪”的问题，其在刑法犯罪论理论体系中居于基础与核心^⑩的地位，是犯罪论乃至整个刑法学体系的逻辑起点。

犯罪概念的界定模式尽管犯罪是一种普遍的社会现象，但对于何谓犯罪，学者们表述不一，各国刑事立法中的界定也不尽相同。

具体而言，大体可以分为犯罪的形式概念、犯罪的实质概念和犯罪的混合概念。

（一）

犯罪的形式概念

犯罪的形式概念，也称形式意义的犯罪概念，是指仅基于法律特征而给犯罪下定义，至于法律为何将诸如此类的行为规定为犯罪则不予涉及。

在大陆法系国家的刑事立法中，犯罪的形式概念屡见不鲜。如 1810 年《法国刑法典》第 1 条规定：法律以违警刑处罚之犯罪，称为违警罪；法律以矫正刑处罚之犯罪，称为轻罪；法律以身体刑处罚之犯罪，称为重罪。《西班牙刑法典》第 1 条规定，依自由意志及疏忽之行为而为法律所处罚者谓之犯罪和过失罪。《瑞士刑法典》第 9 条规定，重罪是指应处重惩役之行为；轻罪是指最高刑为普通监禁刑之行为。

刑事立法中对于犯罪的界定显然源于刑法理论，理论上往往把犯罪界定为违反刑事法律、应当受到刑罚处罚的行为。如德国刑法学家宾丁认为，犯罪即违反刑事制裁法律的行为。^⑩法国刑法学家盖洛认为，犯罪乃由事先制定的法律以刑罚相威胁和禁止的行为。而日本刑法理论通常认为，犯罪是符合构成要件的违法并且有责任的行为。[@]犯罪的形式概念，虽然未能触及犯罪的阶级本质，而只从犯罪的法律特征上阐述“犯罪是什么”，但西方刑法学者指出其具有巨大的历史意义和社会价值。

犯罪的形式概念立场鲜明地抨击封建刑法的罪刑擅断，强调犯罪乃“刑法之明定”，充分彰显了罪刑法定原则，清楚、明了地揭示了判定是否犯罪的唯一标准。徐久生编著：《德国犯罪学研究探要》，中国人民公安大学出版社 1995 年版，第 1 页。

[@] 高铭暄主编：《刑法学原理》第一卷，中国人民大学出版社 1993 年版，第 374 页。

[@] [日] 佐佐木养二：《刑法学原论》，南窗社 1987 年版，第 71 页。

第 1 章 1.1 节 犯罪概念标准在于刑法的明确规定。对于刑事司法者而言，采取犯罪的形式概念显然更易于操作，其只需要根据刑法的规定来区别罪与非罪，追究依法构成犯罪者的刑事责任。对于守法者来说，若刑法有明文规定，即系法外定罪和量刑，自己有权拒绝接受。所以，基于对罪刑法定原则的坚持，犯罪形式概念的积极意义是无法否定的。

（二）

犯罪的实质概念

犯罪的实质概念，也称实质意义的犯罪概念，是指不涉及犯罪的法律特征，而从犯罪现象的本质给犯罪下定义，借此揭示一种行为被刑法规定为犯罪的内在原因。以这一形式来界定犯罪概念的，既有学界言说，也有立法实践。

就理论而言，诸多学者力图从实质意义上给犯罪下定义。如康德认为，犯罪的本质就在于犯罪人为了实现个人的自由而实施侵害他人自由的行为，因此，犯罪是出于不道德的动机而实施的不道德的行为。黑格尔认为，犯罪是对他人权利的一种侵犯行为，是对权利普遍性的否定，换言之

之，也就是对法律秩序的否定。

德国刑法学家李斯特认为，犯罪的本质在于对社会共刑法益的侵害。

意大利刑法学家加罗伐洛认为，犯罪是违反社会的怜悯和诚实二道德情感的行为。也

而在马克思、恩格斯看来，犯罪则是孤立的个人反对统治关系的斗争置

是蔑视社会秩序的最明显、最极端的表现□。

刑事立法中从实质意义上界定犯罪概念的主要是苏联。例如，1922年的《苏俄刑法典》第6条规定：“威胁苏维埃制度基础及工农政权向共产主义过渡时期所建立的法律秩序的一切危害社会的作为或不作为，都被认为是犯罪。”1926年的《苏俄刑法典》也规定：“目的在于反对苏维埃制度或者破坏工农政权向共产主义过渡时期所建立的法律秩序的一切危害社会的作为或不作为，都被认为是危害社会的行为。对于形式上虽然符合本法分则任何条文所规定的要件，但因为显著轻微，并且缺乏损害结果，而失去危害社会的性质的行为，不认为是犯罪行为。”与形式意义的犯罪概念强调司法认定犯罪应如何寻找根据不同，实质意义的犯罪概念注重的是刑事立法中应当如何设置犯罪。这种犯罪概念的表述是与统治阶级的犯罪观和刑事责任观紧密联系的。不过，实质意义的犯罪概念虽然旨在从本质上给犯罪下定义，但若脱离形式意义的犯罪概念，仅依靠实质意义的犯罪概念，刑事司法必然无所适从，甚至极易造成定罪的随意性和刑罚的滥用，因为否^⑩ 转引自高铭喧主编：《刑法学原理》第一卷，中国人民大学出版社1993年版，第375页。

98：第阴兰定了形式意义的犯罪概念，就等于否定了罪刑法定原则。

（三）

犯罪的混合概念

犯罪的混合概念，是指既强调犯罪的实质概念，亦注重犯罪的形式概念，以同时揭示犯罪的本质特征和法律特征的概念。

这种界定犯罪概念的方式系苏联刑法学界的通说，并对苏联的刑事立法产生了影响。

例如，苏联刑法学家 A.A. 皮昂特科夫斯基指出，犯罪乃对社会主义国家或社会主义法律秩序有危害的、违法的、有罪过的、应受惩罚的作为或不作为。CD 就刑事立法而言，1958 年的

《苏联和各加盟共和国刑事立法纲要》第 7 条即规定：“凡是刑事法律规定的危害苏维埃社会制度或国民的人身、政治权利、劳动权利、财产权利和其他权利的危害社会的行为（作为或不作为），以及刑事法律规定的违反社会主义法律秩序的其他危害社会的行为，都是犯罪。”随后，这一界定方式为其他社会主义国家的刑法理论和刑事立法所效仿，包括中国在内的大多数社会主义国家，在犯罪概念问题上采纳了混合概念。当然，西方国家也存在采纳犯罪混合概念的主张。例如，德国刑法学家耶赛克认为，犯罪是行为

人实施的符合犯罪构成、危害社会因而应受刑罚处罚的不法行为，
 出了犯罪的形式特征，又指出了犯罪的实质特征。

这就既突

我国刑法理论对我国刑法中犯罪概念的研究，始终是围绕刑法的规定展开的。《刑法》第13条规定：“一切危害国家主权、领土完整和安全，分裂国家、颠覆人民民主专政的政权和推翻社会主义制度，破坏社会秩序和经济秩序，侵犯国有财产或者劳动群众集体所有的财产，侵犯公民私人所有的财产，侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利，以及其他危害社会的行为，依照法律应当受刑罚处罚的，都是犯罪，但是情节显著轻微危害不大的，不认为是犯罪。”据此，我国刑法中的犯罪，是指严重危害社会，触犯刑法并应受刑罚处罚的行为。此一定义既揭示了犯罪对各种社会关系所造成的严重的社会危害性之本质特征，也强调了犯罪所具有的依法应当受刑罚处罚的法律特征。如此界定显然属于混合概念的类型。本书认为，我国刑法所采纳的犯罪的混合概念并非把形式意义的犯罪概念和实质意义的犯罪概念加以混淆，而是基于两个不同的视角将犯罪的形式概念和实质概念有机统一起来，进而在刑事立法和刑事司法中发挥指导性作用，成为认定犯罪、划分罪与非罪界限的基本依据。

犯罪的基本特征关于犯罪的基本特征，我国刑法学界存在不同的观点。
 有观点认为，犯罪具有《苏联刑法科学史》，曹子丹等译，志律出版社1984年版，第23-24页。

④ 徐久生编著：《德国犯罪学研究探要》，中国人民公安大学出版社1995年版，第2页。

第 t · 十 犯罪概念有应受刑罚惩罚的社会危害性和刑法的禁止性两个特征。
 有观点主张，犯罪具有社会危害性和刑事违法性两个特征。
 有观点指出，犯罪的两个基本特征是应受刑罚惩罚的社会危害性和依法应受刑罚惩罚性。还有观点认为，犯罪是危害社会、触犯刑事法律、出于故意或者严重的过失和应当承担刑事责任四方面特征的密切统一。

本书认为，目前刑法学界普遍接受的三特征说较为全面地阐释了犯罪的基本特征。根据《刑法》第13条的规定并依据此一通说，犯罪具有如下三个特征：(1) 犯罪是危害社会的行为，即具有相当程度的社会危害性。
 这是犯罪具有决定意义的特征，是犯罪的实质内容。(2)
 犯罪是触犯刑律的行为，即具有刑事违法性。
 这是社会危害性的法律表现，是犯罪与一般违法行为相区别的重要特征之一。(3)
 犯罪是应受刑罚惩罚的行为，即具有应受惩罚性。这是犯罪前两个特征即社会危害性和刑事违法性的必然法律后果，也是犯罪行为区别于其他违法行为的重要特征之一。

（一）

犯罪是具有严重社会危害性的行为

行为具有严重的社会危害性，是犯罪最本质、最基本的特征。

的确，晚近刑法学界始终存在一种对社会危害性理论的批评之声。考察这些持否定态度的观点，不难发现其核⑩在于担⑩社会危害性的判断标准模糊，不利于罪刑法定原则的贯彻。但是，否定社会危害性的观点或多或少地存在孤立地看待社会危害性标准，进而将其视为独立判断行为是否构成犯罪的标准的偏见。而实际上，肯定社会危害性标准的学界通说并不认为社会危害性标准可以用来独立判断行为是否构成犯罪，而是一再强调必须与刑事违法性结合起来。

所以有学者认为，否定论者在一定程度上是在攻击一个并不存在的目标。⑩

离开严重社会危害性这一犯罪的内在本质特征，犯罪概念就成了一具空壳，难免流于空洞苍白。

所谓社会危害性，是指行为对刑法所保护的社会关系造成或可能造成损害的特性。

犯罪的社会危害性，亦即对国家和人民利益的危害性。犯罪的本质就在于其具有社会危害性。

如果某种行为根本不可能给社会带来危害，法律就不能把它规定为犯罪，更不能对它进行惩罚。

根据《刑法》第13条但书的规定，行为人的行为虽然具有社会危害性，但是情节显著轻微危害不大的，不认为是犯罪。例如，殴打他人，造成轻微伤害的，不能构成故意伤害罪。

由此可见，没有社会危害性，就没有犯罪；社会危害性未达到相当严重的程度，也不构成犯罪。

社会危害性达到相当严重的程度是犯罪与其他违法行为的根本区别。

⑩ 储槐植、张永红：《善待社会危害性观念——从我国刑法第13条但书说起》，《法学研究》2002年第3期。

100

第[];犯罪的社会危害性是各种主观因素和客观因素的统一。

具体而言，影响犯罪社会危害性程度的因素主要包括：（1）

行为侵犯的客体，即行为侵犯了什么样的社会关系。例如，危害国家安全罪侵犯的是国家安全，此类犯罪的社会危害性显然要大于其他犯罪，可谓最危险的犯罪。放火罪、爆炸罪等犯罪侵犯的是公共安全，即不特定多数人的生命财产安全，社会危害性也很大。同样是侵犯他人的人身权利，故意杀人罪侵犯的是他人的生命权，而故意伤害罪侵犯的是他人的身体健康权，前者的社会危害性明显大于后者。（2）行为的手段、后果以及时间、地点。就具体犯罪而言，犯罪的手段是否凶残，是否使用暴力，犯罪造成的后果状况，以及犯罪行为的时间、地点如何，在很大程度上体现和决定了社会危害性的大小。（3）行为人的情况及其主观因素。诸如行为人是成年人还是未成年人，出于故意、过失还是意外事件，是事前有预谋还是临时起意，动机、目的是否卑劣，是初犯、偶犯还是累犯、惯犯等，都会对行为的社会危害性产生不同的影响。

在考察行为的社会危害性时，要用历史、发展、全面的观点看问题。

社会条件发生变化，可能导致对某一行为是否具有社会危害性的评判结果亦发生变化。

例如，投机倒把行为在计划经济时期被认为具有相当的社会危害性，并被明确规定为犯罪行为，但随着社会主义市场经济在我国的逐步构建，这一行为的社会危害性已经基本不^⑨存在了。同时，衡量社会危害性的大小，要综合各种主客观情况，既要看到有形的、物质性的危害，也要看到对社会政治、对人们的社会^⑩理带来的危害。

（二）

犯罪是具有刑事违法性的行为

犯罪是触犯刑事法律的行为，这是犯罪的法律特征。我们知道，违法行为表现形式多样，既有民事违法行为，也有行政违法行为，还有刑事违法行为。

犯罪不是一般的违法行为，而是触犯刑事法律的刑事违法行为，是最为严重的违法行为。

触犯刑事法律是构成犯罪的前提。例如，小偷小摸属于违反治安管理处罚法的行为；只有盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，才能构成刑法中的盗窃罪。如果没有触犯刑事法律，即便该行为具有严重的社会危害性，也不能以犯罪论处。犯罪的严重社会危害性是刑事违法性的基础，也是犯罪的内在本质；犯罪的刑事违法性则是其严重社会危害性在刑法上的表现。

只有当行为既具有严重社会危害性，又违反了刑法，具有刑事违法性时，才能被认定为犯罪。这是遵循罪刑法定原则的必然要求。

犯罪的刑事违法性是主观因素和客观因素的统一。行为人虽然主观上有危害社会的企图，但客观上没有实施危害社会的行为的，不会产生刑事违法性问题；行为虽然客观上造成了严重的危害社会的后果，但行为人主观上不存在故意或者第二勺仁罪构成；
101过失的，也不会产生刑事违法性的问题。

（三）

犯罪是应受刑罚惩罚的行为

对于任何违法行为，无论是民事的、行政的还是刑事的，行为人都应当承担相应的法律后果。民事违法行为要承担赔偿责任、返还财产、支付违约金等民事责任；行政违法行为要承担罚款、行政拘留等行政处罚，或者警告、记过、降级、撤职、开除等行政处分。

而对于刑事违法行为即犯罪来说，行为人应当承担的法律后果是受到刑罚惩罚。

犯罪是适用刑罚的前提，刑罚是犯罪的法律后果。

因此，应受刑罚惩罚也是犯罪的一个基本特征。应受惩罚性之特征将犯罪与刑罚这两种社会现象紧密联系起来，它体现出犯罪在引发的法律后果方面迥异于其他一般违法行为的特点，对于我们充分认识犯罪现象无疑是必要的。

这一特征表明，如果某一行为不应当受刑罚处罚，也就意味着它不是犯罪。

需要注意的是，不应受刑罚惩罚和不需要刑罚惩罚是两个不同的概念。不应受刑罚惩罚，是指行为人的行为根本不构成犯罪，当然就不存在应受刑罚惩罚的问题。而不需要刑罚惩罚，是指行为人的行为已经构成了犯罪，本应受刑罚惩罚，但考虑到案件的具体情况，如犯罪情节轻微，或者有自首、立功、悔改等表现，从而免予刑罚惩罚。免予刑罚惩罚说明行为已构成犯罪，只是不给予刑罚惩罚罢了，它与无罪不应当受刑罚惩罚具有不同的性质，不能混淆。

犯罪的上述三个基本特征是紧密结合、有机联系的。

严重的社会危害性是犯罪最基本的属性，是刑事违法性和应受刑罚惩罚性的基础。刑事违法性是严重的社会危害性的法律表现，应受刑罚惩罚性是行为严重危害社会、违反刑事法律应当承担的法律后果。

因此，这三个基本特征都是必要的，是任何犯罪都必然具备的。这三个基本特征将犯罪与非罪区别开来。

第二节 犯罪构成

犯罪构成与犯罪概念一样，是犯罪论体系乃至整个刑法学体系的灵魂和基石，是其他犯罪论理论得以展开的核⑩和基础。把握和研究犯罪构成，具有重要的意义。

犯罪构成理论的发展与模式

（一）

犯罪构成理论的缘起

犯罪构成，肇始于拉丁文 *corpusdelicti*。1796 年，德国学者克莱因把 *corpusdelicti* 引入德国，并译为 *Tatbestand*。不过，*Tatbestand* 当时还仅具有诉讼法¹⁰²第18条上的意义，表示与特定的行为人没有联系的外部客观事实（罪体）。

司法部门如果不能根据严格的证据法则对这种客观犯罪事实进行确证，就不能进行特别追问。

直到 19 世纪初，德国刑法学家费尔巴哈、斯鸠别尔始将 *Tatbestand* 用于实体法中。费尔巴哈认为，犯罪构成乃违法的（从法律上看）行为中所包含的各个行为的或事实的诸要件的总和。但费尔巴哈等人所谓的犯罪构成，仅指刑法分则中具体犯罪的构成。

20 世纪初，德国刑法学者贝林格开始将犯罪构成与刑法总则中犯罪的一般规定联系起来，创立了系统的构成要件理论。贝林格认为，行为是否构成犯罪，需要经过实体法明文规定，只有与实体法明文规定的构成要件相符合的行为，才能视为犯罪，故而犯罪概念应补充“构成要件该当

性”，任何犯罪都必须具备行为、行为符合构成要件、行为是违法的、行为是有责的、行为有适合处罚的规定以及行为具备处罚的条件等六个条件。□至此，构成要件与违法性、有责性分离。

贝林格的构成要件理论在德国刑法学界引起了关于构成要件与违法性的关系以及构成要件是否包含规范和主观的要素之争。立足于这些争论，麦兹格、迈耶等人又对贝林格的构成要件理论进行了完善，并由迈耶基本完成了这一理论的架构。迈耶于1915年发表了其名著《刑法总论》，明确将贝林格提出的犯罪成立的六个条件简化为三个，即构成要件的符合性（或称该当性）、违法性和有责性。

时至今日，这一阶层式构成要件理论在德日刑法学界占据了相当重要的地位，也成为我国部分学者力图重构犯罪构成理论的模板。

（二）

犯罪构成理论的主要模式及评析

1. 犯罪构成理论的主要模式。事实上，在外国刑法理论中，除德日三阶层

构成要件理论外，还主要存在英美法系双层次犯罪成立理论和苏联四要件犯罪构成理论。

现就这三种犯罪构成理论的基本内涵简要介绍如下：（1）三阶层构成要件理论。

以德日为代表的这一理论，主张犯罪由构成要件的符合性、违法性和有责性构成，

三要件之间具有递进的阶层逻辑结构。构成要件的符合性也称为该当性，是指行为符合刑法分则规定的某个具体犯罪的特征，包括主体、行为、行为客体、结果、行为状况、因果关系、构成要件的故意或过失等要素。

违法性，是指行为对刑法所保护的合法权益或者整体法秩序的实质侵害性。确定行为人的行为是否构成犯罪，不仅要看其行为是否具有构成要件的符合性，还要看该行为是否具有违法性，即为法律所禁止。如果行为具有刑法规定^⑩ 转引自高铭喧王编：《刑法学原理》第一卷，中国人民大学出版社1993年版，第438页。

@ 马克昌主编：《近代西方法学思想史》，中国人民公安大学出版社2008年版，第284-299页。

第一·一〇

犯罪构成的或者法秩序认可的违法性阻却事由，该行为就因不具违法性而不构成犯罪。

正当防卫、紧急避险、自救行为、被害人承诺、正当业务等均属此处所谓的违法性阻却事由。

有责性，是指能够对实施违法行为的行为人进行非难、谴责。如果不具备违法性阻却事由，则需进一步判断责任之有无，这是对行为人非难的可能性进行的判断。

“无责任即无刑罚”，只有在行为人具有主观责任或个人责任的基础上，其行为方成立犯罪。

据此，确立犯罪成立需要经过构成要件的符合性—违法性—有责性三个阶层递进式的判断。

(2) 双层次犯罪成立理论。英美法系刑法学中的犯罪构成体系由两个层次构成：第一层次是犯罪本体要件，包括犯罪行为和犯罪意图，这些要件包含在犯罪定义之中；第二层次是责任充足要件，这是诉讼意义上的犯罪要件，通过合法抗辩事由体现出来。其中，第一层次侧重体现国家意志，表现为公诉机关的权力，通过确立行为规范，发挥刑法维护秩序和保卫社会的功能；第二层次侧重体现公民权利，通过发挥刑法保障人权的机能，制约国家权力。两个层次相辅相成，共同构成英美刑法运行的内在制约机制，体现刑法公正性的价值取向。

(3) 四要件犯罪构成理论。苏联的犯罪构成理论是在批判大陆法系犯罪构成要件理论的基础上形成的，主张将主客观相结合的犯罪构成理论作为认定刑事责任的唯一根据。例如，A.H. 特拉伊宁在其《犯罪构成的一般学说》中指出，犯罪构成乃苏维埃法律认为决定具体的、危害社会主义国家的作为（不作为）

犯罪的一切客观要件和主观要件的总和，是认定刑事责任的唯一根据。CD 进言之，苏联犯罪构成理论把犯罪构成要件奠基于社会危害性的概念之上，认为所谓犯罪构成，就是社会危害的构成，是犯罪客体、犯罪客观方面、犯罪主体、犯罪主观方面这四个要件的总和。

有学者认为这四个要件之间具有耦合式的逻辑结构，因而也将其称为耦合式的犯罪构成体系。

苏联的犯罪构成理论对其他社会主义国家包括中国的刑法理论产生了重要的影响。

1. 三种主要犯罪构成理论模式简评。德日的三阶层构成要件理论虽然注重

理论的抽象研究，与法律对犯罪诸要素的规定不具有直接联系，但其逻辑思考过程严密、先后有序、不可互易，这使得犯罪构成理论对犯罪构成要件的叙述，与实践中认定犯罪的实际情况基本保持了形式上的一致性，反映了理论与实践的统一，对犯罪的认定比较严格，对于犯罪人的人权保障具有一定的积极意义。而且，从构成要件符合性、违法性到有责性的递进，体现的是一种从以外表、客观为主到以内在、主观为主的评价过程和顺序，直观地反映了刑事诉讼循序渐进的⑩ [苏联] A. H. 特拉伊宁：《犯罪构成的一般学说》，王作富等译，中国人民大学出版社 1958 年版，第 48—49 页。

104 第匠过程，有助于明确要件之间的逻辑关系，也有助于较好地维护法律适用的安全性，实现结果的正义性。印 但是，三阶层构成要件理论只是大陆法系众多犯罪构成理论中有代表性的一种，其本身也存在诸多缺陷。例如，构成要件的推定机能在正当防卫、紧急避险等场合失灵；关于违法性、有责性的判断可能先入为主；实际操作中容易偏离司法实践，有唯体系论的倾向；概念、范畴众多，学术体系庞杂，晦涩难懂；等等。

英美法系的双层次犯罪成立理论在某种程度上属于程序性犯罪构成，具有浓厚的程序化特征，侧重体现的是以程序正义为主导的价值取向。在此一理论模式中，本体要件框定了犯罪成立的基础，虽具有推定的性质，但仍属于一般性的、抽象的、形式的评价，而其责任充足要件则从个别、具体和实质的角度限定了犯罪成立的范围。

其思维方式，无疑与人类认识的方式以及定罪的过程也是基本一致的。反映到实践中，这种控、辩双方的对抗对于维护罪刑法定原则，保障被告人人权，无疑也是有利的。但是，英美法系的双层次犯罪成立理论仅仅满足于实用，不注重深入的理论分析与体系的构建，很多问题点到为止，未能展开，甚至没有涉及。例如，欠缺明显的违法性判断标准，其法定的构成要件内容与超法规的构成要件内容，均为事实性要素，是价值判断对象而非价值判断标准，理论中也并不研究违法性的判断标准问题。

苏联四要件犯罪构成理论不仅能够通过各种相互联系、相互作用的要件及其要素，充分反映出社会危害性这一犯罪的本质，揭示犯罪行为内部构成要素的有机统一性质，而且这种犯罪构成的理论体系，总体上避免或至少减少了许多对行为是否构成犯罪而作的烦琐的重^⑨评价。同时，这一理论所确立的犯罪构成要件的结构模式，使犯罪构成理论与犯罪构成的法律规定较为完美地达到了和谐与协调，因为构成要件的内容就是犯罪成立的要素。

这样，犯罪构成理论就在逻辑上以立法为依托，且便于司法实际操作和掌握，极具实践品格。

当然，这一理论也存在诸多不足和疑惑。例如，犯罪构成理论与犯罪构成容易发生混淆；在犯罪的认定方面，有罪推定的可能性较大；在解释排除犯罪性行为为何不是犯罪时容易出现体系性的矛盾；犯罪构成要件的充足与否同责任的评价一体进行，容易使刑事责任的地位和内容虚置。

客观而言，这三种犯罪构成理论模式都是特定法律文化发展的产物，它们的哲学基础、价值观和立足点均有不同，可谓各有优点和不足，很难说孰优孰劣。

中 许王秀：《当代刑法思潮》，中国民主法制出版社 2005 年版，第 56-63 页。

一．气了构哎

（三）

我国的犯罪构成理论争议及其发展

我国刑法学界通行的观点认为，犯罪构成是我国刑法规定的，说明某一具体行为的社会危害性及其危害程度已构成犯罪的一系列客观要件和主观要件的总和。犯罪构成要件包括犯罪客体、犯罪客观方面、犯罪主体和犯罪主观方面，统称为四要件犯罪构成理论。

这一犯罪构成理论脱胎于苏联四要件犯罪构成理论，是 20 世纪 50 年代初期从苏联引进的。经过数十年的研讨、修改和发展，已基本形成了具有中国特色的犯罪构成理论，并且在我国刑法理

论中占有十分重要的地位。正如有学者指出的，四要件犯罪构成理论不仅是一种历史性的选择，具有历史合理性；也符合中国国情，契合中国的诉讼模式，具有现实合理性；而且其逻辑严密，契合认识规律，符合犯罪本质特征，具有内在合理性。CD近年来，犯罪构成理论已经成为刑法学界热烈讨论的重要话题。学者们纷纷著书立说，不断提出或更新自己的理论设想或体系建构，大体可以将其归纳为完善模式、直接引进模式以及重构模式三大模式，包括二要件说、三要件说、五要件说等不同观点。其中，直接引进三阶层构成要件理论的观点最具代表性。持该观点的学者认为，四要件犯罪构成理论存在瑕疵，主张以三阶层构成要件理论替代我国通行的四要件犯罪构成理论。诚然，随着时代的发展，四要件犯罪构成理论确实存在需要进一步完善之处，比如成立犯罪的四个要件被放置在同一层面，对成立犯罪的阶层分析即先客观后主观、先形式后实质的层次递进强调不够等。

但是，这些理论瑕疵并不足以颠覆传统四要件犯罪构成理论所具有的通说地位。四要件犯罪构成理论，其犯罪客体、犯罪客观方面、犯罪主体、犯罪主观方面四个要件之间遵循从客观到主观之逻辑顺序排列，呈现一定的阶层性；在四大要件之下，又分别涵括特定的组成要素，可谓内部逻辑结构严密、层次清晰。四要件犯罪构成理论既是对犯罪行为客观本质和内在构造的准确反映，也是对犯罪行为社会危害性、刑事违法性与应受刑罚惩罚性三大特征的具体印证，能够为准确认定犯罪，有效界分罪与非罪、此罪与彼罪提供标尺。而三阶层构成要件理论也有其与生俱来的缺陷，即便在大陆法系国家也未占据绝对优势，甚至因为存在理论体系前后冲突、发展现状与建立初衷背离、过于强调体系且偏离司法实践等诸多弊端，而受到德H刑法学界内部的质疑。

应该说，三阶层构成要件理论、双层次犯罪成立理论的引进，为学术研讨提供了良好的素材，其合理之处也为四要件犯罪构成理论所借鉴吸收，推动了四要件犯罪构成理论在传承中发展、在借鉴中完善，不断与时俱进，凝结了我国诸多^⑩高铭澄：《论四要件犯罪构成理论的合理性暨对中国刑法学体系的坚持》，《中国法学》2009年第2期。

106 第1了刑法学家本土化的智慧与努力。同时，我国刑事立法和司法实践中，立法人员和司法人员所接受的也多为传统的四要件犯罪构成理论。换言之，四要件犯罪构成理论不仅在刑法学理论界，而且在刑事立法、刑事司法等实务界占居通说地位。

为更好地尊重历史，传承中国特色优秀法治文化，不断完善我国犯罪论体系，避免在刑事立法、司法实践中引起不应有的混乱，本书坚持以四要件犯罪构成理论为基础展开论述。

我国刑法中犯罪构成的概念与特征

（一）

犯罪构成的概念

根据刑法学界的通说，我国刑法中的犯罪构成是指刑法规定的，决定某种行为的社会危害性及其程度，而为该行为构成犯罪所必须具备的一切客观要件和主观要件的有机统一整体。

在此，有必要明确犯罪构成与犯罪概念之间的关系。

两者的联系在于：犯罪概念是犯罪构成的前提和基础，犯罪构成是犯罪概念的具体化。一方面，作为犯罪概念基本属性的社会危害性和刑事违法性，也是犯罪构成的基本属性，离开了犯罪概念所揭示的犯罪的共同本质，犯罪构成就失去了立法和理论上的根据。

另一方面，犯罪构成又是犯罪概念及其基本属性的具体化。犯罪构成通过一系列客观与主观要件，使犯罪行为的社会危害性这一本质特征得到具体而明确的体现；犯罪构成也通过犯罪成立诸要件，使犯罪概念的法律特征具体化，反映出犯罪行为的刑事违法性及应受刑罚惩罚性。两者的最大区别在于功能不同：犯罪概念基于行为的社会、政治本质，从整体上回答什么是犯罪、犯罪有哪些基本属性，从而使我们可以从原则上把犯罪行为与其他行为区别开来；而犯罪构成则在犯罪概念的基础上，进一步解决构成犯罪的规格和标准问题，以揭示犯罪如何成立以及构成犯罪需要具备哪些具体条件。

总之，犯罪概念与犯罪构成是抽象与具体的关系。作为对各种犯罪现象基本特征的科学抽象与概括，犯罪概念并不能直接解决具体犯罪的司法认定标准问题，它所具有的认定犯罪的原则作用和对于刑法制度及刑法理论的基础作用，必须通过犯罪构成才能具体实现。易言之，犯罪概念说明犯罪行为是具有严重社会危害性、刑事违法性和应受刑罚惩罚性的行为；而依据犯罪构成，就可以具体的构成要件为标准来判断哪些行为是具有严重社会危害性、刑事违法性和应受刑罚惩罚性的犯罪行为。犯罪概念和犯罪构成既紧密联系又彼此区别，相辅相成，共同为司法实践中正确地认定犯罪服务。

（二）

犯罪构成的特征

1. 法定性。行为构成犯罪所必需的要件，必须由我国刑法加以规定。此一

第二节 犯罪构成 ' 107

特征体现了犯罪构成的法定性。

就立法层面而言，刑法之所以规定某一犯罪，是因为其具有严重的社会危害性。就司法实践而言，某一行为是否构成犯罪，必须依照法律规定的犯罪构成来判断；当某一行为符合具体犯罪的构成要件时，该行为就具有刑事违法性。

因此，通过犯罪构成的法定性，犯罪的严重社会危害性与刑事违法性达到了一致。

犯罪构成的法定性，直接彰显了罪刑法定原则的基本要求。

“罪”之法定，重在要求犯罪的构成要件必须法定。

值得一提的是，刑法对犯罪构成的规定，是由刑法总则与刑法分则共同实现的。

刑法总则规定一切犯罪必须具备的要件，刑法分则规定具体犯罪特别需要具备的要件。因此，对于具体犯罪，应当依照刑法总则和刑法分则的规定，结合有关案件事实来认定，以便得出正确的结论。

1. 决定性。任何一个犯罪都包含着很多事实特征，但不是每一个事实特征

都可以成为犯罪构成的要件，只有对行为的社会危害性及其程度具有决定意义而为该行为成立犯罪所必需的事实特征，才是犯罪构成的要件。换言之，犯罪构成要件只是从同类案件诸多事实中抽象、概括出来的具有共性的，对犯罪性质和社会危害性具有决定意义的事实。

考察某一行为是否具有社会危害性并构成犯罪，只需看它是否具备该罪的构成要件。

因此，必须将属于构成要件的事实与案件的其他事实相区别。

当然，属于构成要件的事实本身，与犯罪构成也是有区别的

：前者是案件中的具体事实，后者是法律规定的要件整体。

其他事实，可能有助于侦查和审理案件，也可能对量刑有一定的意义，但并非犯罪的构成要件。

例如盗窃罪，虽然在具体案件中存在各种事实，但只有下列事实才是其构成要件：（1）

侵犯的是公私财产所有权；（2）在客观上表现为盗窃公私财物，数额较大，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的行为；（3）行为人已满 16 周岁且具备刑事责任能力；（4）主观上出于直接故意，具有非法占有的目的。至于其他事实，如被害人的状况、窃取的手段、盗窃的动机等，均非盗窃罪的构成要件，不影响盗窃罪的成立。

1. 统一性。犯罪构成是诸多客观要件和主观要件的有机统一。任何一种犯

罪的成立，都须具备若干要件。在这些要件中，既包含犯罪客体要件和犯罪客观方面要件，也包含犯罪主体要件和犯罪主观方面要件。在刑法理论上，可以将其中的犯罪客体要件和犯罪客观方面要件统称为客观要件，将犯罪主体要件和犯罪主观方面要件统称为主观要件。

客观要件和主观要件的有机统一，就形成了犯罪构成。犯罪构成是客观要件与主观要件的有机统一，而不是各个要件的简单叠加，诸要件按照犯罪构成的要求，彼此联系、相互作用、协调一致

。犯罪构成之所以必须是主客观要件的有机统一，其内在根据在于，犯罪行为本身就是主客观的统一。不考虑客观要件的主观归罪或不考虑主观要件的客观归罪，都是不符合

第 8 章

唯物主义辩证法的。

根据我国刑法，任何一种犯罪的成立都必须具备四个方面的构成要件，即犯罪客体、犯罪客观方面、犯罪主体、犯罪主观方面。日常生活中存在形形色色的刑事案件，虽然构成犯罪的要件不一样，但所有具体要件都可归属于以上四个构成要件。

我国刑法分则规定的犯罪都具有客观要件和主观要件有机统一的犯罪构成。

例如，依照《刑法》第 232 条和第 17 条第 2 款、第 3 款的规定，构成故意杀人罪必须具备以下要件：（1）侵犯的客体是他人的生命权。（2）客观上实施了非法剥夺他人生命的行为。（3）行为人是已满 14 周岁、具有刑事责任能力的人；已满 12 周岁不满 14 周岁的人，故意杀人致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾，情节恶劣，经最高人民检察院核准追诉的，也应负刑事责任。

（4）主观上具有非法剥夺他人生命的故意。这几个要件有机结合在一起，就是故意杀人罪的犯罪构成。

犯罪构成的分类

（一）

单纯的犯罪构成与混合的犯罪构成

根据犯罪构成要件的繁简程度，可以把犯罪构成分为单纯的犯罪构成与混合的犯罪构成。

单纯的犯罪构成是指刑法条文规定的犯罪构成各要件之要素均属单一的犯罪构成。例如，非法侵入住宅罪的犯罪构成，其客体是公民住宅不可侵犯的权利，客观方面为非法侵入他人住宅的行为，主体为已满 16 周岁、有责任能力的人，主观方面为故意。这种犯罪构成就是单纯的犯罪构成。

混合的犯罪构成，是指刑法条文规定的诸要件中存在要素⑨合或择一而定的犯罪构成。据此，混合的犯罪构成又包括⑨合的犯罪构成和择一的犯罪构成两种情况。

⑨合的犯罪构成，是指刑法条文规定的犯罪构成的某一要件包含数个要素的犯罪构成。

主要可细分为：（1）包含数个危害行为的犯罪构成。如强奸罪须同时具有暴力、胁迫或者其他强制手段行为和奸淫行为。（2）包含数个犯罪对象或行为对象的犯罪构成。如抢劫罪既侵犯他人的人身，也侵犯他人的财产。

（3）包含两种罪过形式的犯罪构成。这种⑨合的犯罪构成以结果加重犯为典型，如故意伤害罪致人死亡，行为人对死亡结果只能出于过失，而不可能出于故意。

择一的犯罪构成，是指刑法条文规定的犯罪构成诸要件要素中有可供选择余地的犯罪构成。

择一的犯罪构成又有同质的择一犯罪构成和不同质的择一犯罪构成之分。^⑩ 其中，同质的择一犯罪构成，是指几个可供选择的要件要素具有相同性质的犯罪构成，包括以数个危害行为作为选择要件要素的犯罪构成、以数种犯罪方法作为选择要件要素的犯罪构成、以数种犯罪地点作为选择要件要素的犯罪构成、以数种犯罪对象或行为对象作为选择要件要素的犯罪构成、以数种危害结果作为选择要件要素的犯罪构成、以数种主体身份作为选择要件要素的犯罪构成以及以数种犯罪目的作为选择要件要素的犯罪构成等。例如，《刑法》第152条规定的走私淫秽物品罪，其犯罪目的既可以是“牟利”也可以是“传播”，行为对象可以是淫秽的影片、录像片、录音带、图片、书刊等。

不同质的择一犯罪构成，是指可供选择的要件要素不具有相同性质的犯罪构成。例如，根据《刑法》第340条的规定，违反保护水产资源法规，在禁渔区、禁渔期或者使用禁用的工具、方法捕捞水产品，情节严重的，就构成非法捕捞水产品罪。

“禁渔区”“禁渔期”“使用禁用的工具、方法”三者择一即可。

这三者分别是特定犯罪地点、特定犯罪时间和特定犯罪方法，具有不同性质。

⑨合的犯罪构成，需要⑨合或相加的要素齐备，才能成立犯罪；择一的犯罪构成，只要行为具有可供选择的要素中的一种，就可以成立犯罪，但是同时具备两个或两个以上可供选择要素的，也只成立一罪。

（二）

标准的犯罪构成与修正的犯罪构成

按照犯罪构成类型所依赖的犯罪形态是否典型，可将犯罪构成分为标准的犯罪构成与修正的犯罪构成。此一分类方法，可以揭示同质的犯罪在不同形态下由于构成要件的组成结构不同而具有的不同程度的社会危害性。

标准的犯罪构成，是指刑法条文就某一犯罪的单独犯的既遂状态规定的犯罪构成。

标准的犯罪构成由刑法分则直接规定。

修正的犯罪构成，是指以标准的犯罪构成为前提，为适应犯罪行为的各种不同犯罪形态，对标准的犯罪构成加以某些修改变更的犯罪构成。修正的犯罪构成在刑法总则中是以通则的形式规定的，包括：适应故意犯罪过程中的未完成形态而分别规定的预备犯、未遂犯、中止犯的犯罪构成；适应数人实施依单独犯规定的犯罪构成的犯罪形态而规定的共犯的犯罪构成，即主犯、从犯、胁从犯、教唆犯的犯罪构成；等等。在确定修正的犯罪构成时，要以刑法分则具体条文规定的标准的犯罪构成为基础，结合刑法总则中关于该修正的犯罪构成的规定加以综合认定。^⑪

（三）

普通的犯罪构成、加重的犯罪构成与减轻的犯罪构成

按照犯罪行为危害程度的大小，可将犯罪构成分为普通的犯罪构成、加重的^⑩
马克昌主编：《犯罪通论》，武汉大学出版社 1999 年版，第 96—97 页。

@ 马克昌王编：《犯罪通论》，武汉大学出版社 1999 年版，第 93 页。

第〔兀兰 仁罪概念与犯罪砍戊犯罪构成和减轻的犯罪构成。此一分类方法，不仅有助于立法者根据行为的社会危害性合理配置法定刑，完善刑罚结构体系，也有助于司法实务人员在认定犯罪性质的基础上更好地体现罪责刑相适应原则。

所谓普通的犯罪构成，是指刑法条文对具有通常社会危害程度的行为规定的犯罪构成。
例如，《刑法》第 234 条第 1 款规定，故意伤害他人身体的，处 3 年以下有期徒刑、拘役或者管制。该款规定的犯罪构成，就是普通的犯罪构成。

所谓加重的犯罪构成，是指以普通的犯罪构成为基础，由于具有较重社会危害程度的情节而从普通的犯罪构成中分化出来的犯罪构成。例如，《刑法》第 234 条第 2 款规定，犯前款罪，致人重伤的，处 3 年以上 10 年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处 10 年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。此款规定的犯罪构成，就属于加重的犯罪构成。

所谓减轻的犯罪构成，是指以普通的犯罪构成为基础，由于具有较轻社会危害程度的情节而从普通的犯罪构成中分化出来的犯罪构成。例如，《刑法》第 232 条规定的“情节较轻的，处三年以上十年以下有期徒刑”，就属于减轻的犯罪构成。

犯罪构成的意义

（一）

有利于实现和维护罪刑法定原则，防止罪刑擅断

事实上，正是为了贯彻罪刑法定原则，犯罪构成理论才应运而生。罪刑法定原则的派生原则成文法主义原则、明确性原则、适当性原则，要求刑法明文、明确、恰当地规定各种犯罪的成立条件和法律后果，以便于司法实践的操作，而犯罪构成正是犯罪成立条件的概括，所以它有利千罪刑法定原则的贯彻落实。犯罪构成可以使实施罪行的人受到追究，以维护社会秩序；也可以使未实施罪行的人不受处罚，以保障人权。只有借助于犯罪构成，罪刑法定原则维护社会秩序和保障人权的功能才能实现。

（二）

对刑事司法实践起着特别重要的指导作用

具体而言，它具有如下作用：（1）区分罪与非罪。一种行为是否构成犯罪，只能依犯罪构成判断。行为符合犯罪构成的，构成犯罪；不符合犯罪构成的，则不构成犯罪。犯罪构成为区分罪与非罪提供了明确而具体的法律标准。

（2）区分此罪与彼罪。犯罪构成也为此罪与彼罪的区分提供了法律标准。由于每一种犯罪都具有独一无二的构成要件，因此，只需严格把握各种犯罪的具体构成要件，就能将各种犯罪准确地加以区分。（3）正确地裁量刑罚。犯罪构成可以为判定一罪与数罪提供标准，有助于确定是否进行数罪并罚。而且，不同的犯罪构成也体现了不同犯罪的不同社会危害性，可以据此确定刑罚的轻重。

气考题尤其是加重的犯罪构成与减轻的犯罪构成，对于判断罪刑轻重，正确裁量刑罚具有直接的意义。

□ 拓展学习 髻知识点阐释 思考案例 法考真题思考题

1. 什么是犯罪？犯罪有哪些基本特征？
1. 什么是犯罪构成？犯罪构成有哪些基本特征？
1. 试述我国犯罪构成模式的选择及四要件犯罪构成理论的改进。
1. 犯罪构成如何分类？
1. 犯罪构成的意义是什么？

第五节 犯罪客体

第一节 犯罪客体的概念与特征

犯罪客体的概念犯罪客体，是指我国刑法保护的为犯罪行为所侵犯的社会关系。犯罪客体是犯罪构成的必备要件。任何一种犯罪都必然侵犯刑法所保护的社会关系，否则，就不具备严重的社会危害性，缺乏犯罪的本质特征。

近年来，随着德日犯罪论体系在我国的传播，刑法学界有一种观点认为，犯罪客体并不是犯罪构成的要件，犯罪行为侵犯了一定的社会关系，反映的是犯罪行为的实质，而这正是犯罪概念所研究的犯罪本质问题，因而犯罪客体应是犯罪概念研究的对象，而不是犯罪的构成要件；而行为对象（或称犯罪对象、行为客体）体现了犯罪行为直接作用的人或物，应是犯罪构成客观方面的一个要件。这一观点无疑借鉴了德日等国关于保护客体和行为客体分立的理论。

这种观点对于反思我国刑法理论具有积极的意义，但其涉及我国犯罪论体系的改造问题，尚处于理论争鸣阶段，没有被广为接受。因此，本书采用通说，认为犯罪客体是犯罪构成的必备要件，而犯罪对象同犯罪客体既有联系，又有区别。

犯罪客体的特征根据上述犯罪客体的定义，其具有以下三个主要特征：（一）犯罪客体是一种社会关系。社会关系是人们在生产活动和共同生活中所形成的人与人之间的相互关系。

这种关系是人类社会存在的必要条件。社会关系分为物质关系和思想关系。物质关系是社会的经济生产关系，即经济关系，它是人们在社会生产过程中结成的，是一切社会关系的基础。思想关系是由经济基础决定的上层建筑，是建立在生产关系基础上的政治关系和意识形态。政治关系在阶级社会中主要表现为人们在国家政权中所处的地位以及在法律上的权利义务；意识形态是纯粹的精神生活，由一定的政治、法律、哲学、宗教、艺术等观点组成。在阶级社会中，无论是经济基础，还是上层建筑，都具有鲜明的阶级性。统治阶级要用法律等手段去调整和维护一定的社会关系，如果行为人的行为侵犯了这种社会关系并达到一定的严重程度，就会被认为是犯罪。

（二）

犯罪客体是我国刑法保护的社会关系

社会关系的内容十分丰富，范围极其广泛，存在于社会的各个方面，但它们的重要程度并不可等量齐观。例如，国家安全、政治制度、社会制度、公共安全等社会关系居于最重要的地位，经济秩序、人身权利、财产权利、社会秩序等社会关系次之。根据社会关系的重要性程度，国家分别以不同的行为规范予以调整和保护，以保证社会的正常运作和发展。我国《刑法》第2条、第13条明文规定予以保护的国家安全，人民民主专政的政权，社会主义制度，财产所有权，公民的人身权利、民主权利和其他权利，社会秩序，经济秩序，以及刑法分则条文规定予以保护的各种社会关系，就是我国刑法规定的犯罪客体。

（三）

犯罪客体是犯罪行为侵犯的社会关系

刑法保护的社会关系，无论是物质关系还是思想关系，都是客观存在的，其本身并不是犯罪客体。只有当它们被犯罪行为侵犯时，才能成为犯罪客体。这说明犯罪行为与犯罪客体具有密切的关系，没有犯罪行为，也就没有犯罪客体。反之，如果行为没有侵犯刑法保护的社会关系，没有侵犯任何客体，也就不可能构成犯罪。

犯罪客体与犯罪对象

（一）

犯罪对象

犯罪对象，是指刑法分则条文规定的受犯罪行为直接作用或影响的具体的人或物。大多数犯罪行为，都直接作用于一定的对象，进而侵害刑法所保护的社会关系。

犯罪对象具有客观性和可知性的特征。人们对危害行为的认知过程，往往始于对犯罪对象的感知，进而认识到受犯罪行为侵害而为刑法保护的社会关系的性质。犯罪对象有以下基本特征：

1. 犯罪对象是具体的人或物。具体的人是指在某种具体犯罪中被侵害的人，

是广义的概念，包括自然人、法人、非法人团体乃至国家；具体的物是指不以人的意志为转移而客观存在的物质，包括有形物与无形物。例如，《刑法》第232条规定的故意杀人罪，犯罪对象是人；第264条规定的盗窃罪，犯罪对象是公私财物。

1. 犯罪对象是刑法规定的人或物。根据罪刑法定原则，无法律规定则无犯

罪，因而犯罪对象也应当以刑法规定的范围为界限。作为犯罪构成必备要件的犯罪客体，在刑法绝大多数条文中并没有明确规定，而是通过作为犯罪对象的人或物来表现的。

可见，犯罪对象是由刑法加以规定的。

1. 犯罪对象是受犯罪行为直接作用或影响的人或物。作为犯罪对象的人或

物总是客观存在的，在被犯罪行为直接作用或影响前，只是可能的犯罪对象；只有当犯罪行为直接作用或影响后，才能成为现实的犯罪对象。”

作用”和“影响”的内容是使对象的性质、数量、结构、状态、位置等发生变化。

由此，犯罪对象区别于组成犯罪行为之物、行为孳生之物和犯罪行为的报酬取得之物。

对犯罪对象可以从不同的角度作不同的分类。

从物质表现形式看，犯罪对象包括人和物两种。人作为犯罪对象主要表现为人的生命、健康、名誉受到损害或威胁；作为犯罪对象的物是指物品、货币等一切具有价值、归属关系的東西。按归属关系，可将犯罪对象中的物分为国家所有物、集体所有物、个人所有物、混合所有物；按作用，可将犯罪对象中的物分为生产资料、生活资料；按存在形态，可将犯罪对象中的物分为动产、不动产。在具体犯罪中，找出犯罪对象并分析其特征，具有重大的理论及实践意义。

1. 犯罪对象决定某些犯罪是否成立。在某些犯罪中，犯罪行为只有作用于

特定对象，才能构成犯罪。例如，《刑法》第

384

条规定的挪用公款罪，其犯罪对象就是公款和该条第

2

款规定的用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济的款物。

除上述两种款物之外的公物不属于本罪的犯罪对象，对之加以挪用，不构成挪用公款罪。

1. 特定犯罪对象影响此罪与彼罪的区分。在许多情况下，犯罪对象不同，

犯罪的性质就不相同，罪名亦不同。这是因为，不同的对象体现不同的社会关系，犯罪对象不同，表明行为侵犯的社会关系不同，因而犯罪性质就不同。例如，抢劫公私财物的行为，主要侵犯了财产所有权，构成抢劫罪；抢劫枪支、弹药、爆炸物、危险物质的行为，危害了公共安全

，构成抢劫枪支、弹药、爆炸物、危险物质罪。

1. 犯罪对象不同影响罪行的轻重，进而影响量刑。许多犯罪虽未规定具体

的犯罪对象，但行为人具体选择的对象不同或者对象的特点、数量等不同，犯罪的社会危害性也会不同，进而量刑也会有所不同。例如，同是强奸罪，强奸已满14周岁的女性与奸淫未满14周岁的幼女，后者的危害性相对要大，量刑时是从重处罚的情节。

（二）

犯罪客体与犯罪对象的关系

犯罪客体与犯罪对象的关系密切。犯罪客体制约犯罪对象，犯罪对象反映犯罪客体。但二者又存在明显的区别：

1. 犯罪客体是生命权、财产所有权、公共安全、国家安全等凭借人的思维才能认识的观念的事物；犯罪对象是人、物等可以凭借人的感官感知的事物。

两者表现出抽象与具体的差异。

1. 犯罪客体决定犯罪性质，犯罪对象则未必。分析某一案件，单从犯罪对

象去看，是分不清犯罪性质的，只有通过犯罪对象所体现的社会关系即犯罪客^① 弟 J千. 一.. 一 ... 一 口 H . . 初分类 115体，才能确定某种行为构成什么罪。例如，同样是盗窃电线，某甲盗窃的是库房里备用的电线，某乙盗窃的是输电线路正在使用的电线，那么前者构成盗窃罪，后者则构成破坏电力设备罪。

两者的区别就在于犯罪对象所体现的社会关系不同：一个是财产所有权；另一个是公共安全。

1. 犯罪客体是任何犯罪构成的必要条件，犯罪对象则不是任何犯罪都不可

缺少的，它仅仅是某些犯罪的必要条件。例如，《刑法》第152条规定的走私淫秽物品罪，其犯罪对象只能是具体描绘性行为或者露骨宣扬色情的淫秽书刊、影片、录像带、录音带、图片及其他淫秽物品，否则就不可能构成此罪。而像偷越国（边）境罪，脱逃罪，妨害国境卫生检疫罪，非法集会、游行、示威罪等，就很难说有什么犯罪对象了。

但这些犯罪无疑都侵害了一定的社会关系，都具有犯罪客体。

1. 任何犯罪都会使犯罪客体受到危害，犯罪对象则不一定受到损害。例如，

盗窃犯将他人的电视机盗走，侵犯了主人的财产权利，但作为犯罪对象的电视机本身则未必受到损害。并且，一般情况下，盗窃犯总是把窃来的东西好好保护，以供自用或卖得高价。

1. 犯罪客体相同意味着犯罪性质相同，所以犯罪客体是犯罪分类的根据。

而犯罪对象不是犯罪分类的根据，因为犯罪对象相同并不意味着犯罪性质相同。

例如，同是珍贵文物，当被馆藏时，表现为财产所有权，可成为盗窃罪的客体；当被走私时，表现为国家对外贸易管理秩序和对文物的管理秩序，是走私文物罪的客体。

刑法分则体系只能以犯罪客体为依据来建立，而不能以犯罪对象为依据来建立。

第二节 犯罪客体的分类

按照犯罪行为侵犯的社会关系的范围，刑法理论一般将犯罪客体划分为三类或三个层次：一般客体、同类客体和直接客体。三类客体是三个不同的层次，它们之间是一般与特殊、共性与个性、抽象与具体、整体与部分的关系。

同类客体是在直接客体基础上的分类和概括，而一般客体又是对一切犯罪客体的抽象和概括。

它们虽然具有许多共性，但又不能相互取代，在刑法理论与司法实践中都有其重要的作用。

一般客体犯罪的一般客体，又称犯罪的共同客体，是指一切犯罪共同侵犯的社会关系¹¹⁶。第 Y 令 • • 辱 • • A. . _?, J, ' , 罂'农 才, □. i,、系, 即刑法所保护的社会关系的整体。它反映了一切犯罪的共性。任何犯罪都侵犯了犯罪的一般客体, 否则就不能构成犯罪。因此, 一般客体揭示了一切犯罪的本质, 是否存在犯罪的一般客体, 是区分罪与非罪的重要标准。

我国《刑法》第 2 条关于刑法任务的规定、第 13 条关于犯罪概念的规定表明了犯罪一般客体的主要内容。犯罪的一般客体是犯罪客体的最高层次, 说明任何犯罪行为都侵害了刑法所保护的社会关系的整体, 犯罪并不仅仅是犯罪人与被害人之间的矛盾, 还是犯罪人与国家、社会的冲突。

同类客体犯罪的同类客体, 是指某一类犯罪所共同侵犯的我国刑法所保护的社会关系。犯罪的同类客体, 是根据犯罪行为侵害的刑法所保护的社会关系所具有的相同或相近的性质确定的。例如, 抢劫、抢夺、盗窃、诈骗等犯罪的共性特征在于都侵害了他人的财产权, 财产权就成为上述犯罪的同类客体; 再如故意杀人罪、故意伤害罪、诽谤罪、非法拘禁罪所侵害的他人的生命权、健康权、名誉权、人身自由权等都属于人身权利的范畴, 因此, 人身权就成为这些犯罪的同类客体。

犯罪客体是刑事立法的重要依据。刑事立法通过对各种具体犯罪予以归纳、分类和编排, 构建起一个以同类客体原理为指导, 以犯罪的社会危害性为基础的刑法分则体系。

我国刑法将犯罪同类客体分为十类: (1) 国家安全。这是《刑法》分则第一章规定的同类客体。(2) 公共安全。这是《刑法》分则第二章规定的同类客体。(3) 社会主义市场经济秩序, 包括 8 类。这是《刑法》分则第三章规定的同类客体。(4) 公民人身权利、民主权利。这是《刑法》分则第四章规定的同类客体。(5) 公私财产关系。这是《刑法》分则第五章规定的同类客体。(6) 社会管理秩序, 包括 9 类。这是《刑法》分则第六章规定的同类客体。(7) 国防利益。这是《刑法》

分则第七章规定的同类客体。 (8) 国家的廉政制度。 这是 《刑法》
分则第八章规定的同类客体。 (9)
国家机关的正常活动以及公众对国家机关工作人员职务活动公正性的信赖。 这是 《刑法》
分则第九章规定的同类客体。 (10) 国家的军事利益。 这是 《刑法》
分则第十章规定的同类客体。

直接客体

(一)

直接客体的概念及分类

犯罪的直接客体，是指某一特定犯罪直接侵犯的客体，亦即某一特定犯罪直接侵害的某种具体的社会关系。 例如，故意杀人罪的直接客体就是他人的生命权，无期徒刑的直接客体是人身自由权，诈骗罪是直接客体是公私财物所有权或占有权。

犯罪的直接客体是决定犯罪性质的重要因素。

一种行为之所以被认定为这种犯罪或那种犯罪，归根结底是由犯罪的直接客体决定的。

犯罪的直接客体揭示了具体犯罪所侵害社会关系的性质以及该犯罪的社会危害性。

因此，犯罪的直接客体是研究犯罪客体的重点，也是司法实践中区分罪与非罪、此罪与彼罪的关键。

按照不同的标准，还可以对直接客体作进一步的分类。

1. 简单客体与⑨杂客体。 根据犯罪行为侵犯直接客体内容的数量，可以将直接客体区分为简单客体与⑨杂客体。

简单客体，也叫单一客体，

是指某种犯罪行为仅仅侵犯一种具体的社会关系，即只有一个直接客体。

例如，盗窃罪的直接客体是公私财产所有权。

⑨杂客体，是指某种犯罪行为同时侵犯两种或两种以上的具体的社会关系，即有两个或两个以上的直接客体。

例如，贪污罪的直接客体是国家工作人员职务行为的廉洁性和公共财产的所有权，为⑨杂客体。

对于⑨杂客体，通常要区分主要客体和次要客体。

区分主要客体与次要客体的标准，是具体社会关系的重要性程度和遭受犯罪侵犯的程度。 例如，以勒索财物为目的的绑架罪，其直接客体有两个，即他人的人身权利和公私财产所有权，立法者着重保护的是他人的人身权利，因而将本罪规定在“侵犯公民人身权利、民主权利罪”一章，他人的人身权利就是本罪的主要客体，相应地，公私财产所有权就是次要客体。

在⑨杂客体情况下，主要客体决定具体犯罪的归类，进而影响犯罪的既遂标准。

在⑨杂客体中还有一种特殊的情况，也就是所谓的随机客体。它是指在某一具体犯罪侵害的⑨杂客体中基于某种偶然的情形而出现的客体，也称随意客体、选择客体。例如，非法拘禁罪侵害的客体主要是他人的人身自由权利，但如果偶然地导致被害人重伤、死亡，就侵害他人的健康权利、生命权利。随机客体也属于⑨杂客体的一种，但与主要客体、次要客体不同的是，主要客体、次要客体是某些犯罪的必备要件，而随机客体仅仅是选择要件，可能出现也可能不出现。随机客体往往是加重刑事处罚的原因和依据。

1. 物质性犯罪客体与非物质性犯罪客体。以具体犯罪侵犯的社会关系是否

具有物质性为标准，可将直接客体分为物质性犯罪客体与非物质性犯罪客体。侵害物质性犯罪客体的标志是产生物质性的损害或威胁，可能成为物质性犯罪客体的社会关系包括经济关系、财产关系以及人的生命、健康权利等。侵害非物质性犯罪客体的标志是不具有直接的物质损害的形式，可能成为非物质性犯罪客体的社会关系包括政治制度、社会秩序、人格、名誉等。

物质性犯罪客体具体体现为物质性的犯罪结果，刑法对此一般都作了明确规定，因此，构成犯罪既遂一般要求造成实际损害结果。对于非物质性犯罪客体，犯罪造成的损害往往难以测定，因此，刑法一般未具体明确规定非物质性危害结果。在实践中，也不对危害结果进行特别考察，只要实施了危害行为，犯罪就成立既遂，如侮辱罪、诽谤罪等。

（二）

直接客体的立法形式

了解和把握犯罪直接客体的立法形式，有助于准确区分罪与非罪、此罪与彼罪，并正确裁量刑罚。我国《刑法》总则关于犯罪直接客体的规定，集中体现于《刑法》第2条、第13条，而《刑法》分则对于犯罪直接客体的规定，采取了多种形式。具体而言，《刑法》分则对犯罪直接客体的规定有以下几种形式：

1. 明确规定犯罪客体。例如，《刑法》第105条规定的颠覆国家政权罪，条文揭示其犯罪客体是国家政权、社会主义制度。又如，《刑法》第252条规定的侵犯通信自由罪，条文揭示该罪的犯罪客体是公民通信自由权利。

1. 通过规定犯罪客体的物质表现揭示犯罪客体。例如，《刑法》第263条规定的抢劫罪，条文通过犯罪客体的物质表现公私财物，揭示该罪侵犯的客体之一是公私财产所有权。

1. 通过规定犯罪违反的某项法规表明犯罪客体。法规是为调整一定的社

会关系而制定的，其本身不是客体。刑法指出犯罪违反某项具体法规时，犯罪行为侵犯的该法规所调整的社会关系，就是该罪的客体。例如，《刑法》第 325 条规定的非法向外国人出售、赠送珍贵文物罪，条文以“违反文物保护法规”为要件，通过“文物保护法规”说明本罪的犯罪客体是国家对文物的管理秩序。

1. 通过规定犯罪侵害的被害人特征表明犯罪客体。人是社会关系的主体。

犯罪者对处于特定社会关系中的人施加侵害，表明其行为已侵犯了这种特定的社会关系。例如，《刑法》第 260 条规定的虐待罪，其罪状规定为“虐待家庭成员，情节恶劣的”，条文中的“家庭成员”表明本罪的犯罪客体是平等互助的家庭关系。

1. 通过规定犯罪行为的方法表明犯罪客体。犯罪是通过行为侵犯社会关系

的，有些时候，实施犯罪的方法就能说明它所侵犯的客体性质。例如，《刑法》第 121 条规定的劫持航空器罪，条文规定“以暴力、胁迫或者其他方法劫持航空器的”，犯罪方法“暴力、胁迫”等，结合犯罪对象“航空器”，就清楚地表明该种犯罪的客体是航空器的飞行安全。

综上所述，尽管我国刑法中的绝大多数条文没有对犯罪客体作出明文规定，但并不意味着相关犯罪没有犯罪客体，而是在立法上通过其他方式表明其犯罪客体、考成 119 体的。

□ 拓展学习知识点阐释 思考案例思考题

1. 如何理解犯罪客体在犯罪构成中的地位和作用？

1. 犯罪对象与犯罪客体的关系是什么？

1. 我国刑法分则的罪名是按照什么标准进行分类的？

第六章 犯罪客观方面

第一节 犯罪客观方面概述

犯罪客观方面的概念犯罪客观方面，是指刑法规定的，说明行为对刑法所保护的社会关系的侵犯性，行为成立犯罪所必须具备的客观事实特征。

犯罪客观方面包括危害行为、危害结果以及犯罪的时间、地点、方法等。

在犯罪客观方面的要件中，危害行为是一切犯罪的构成要件；危害结果是大多数犯罪的构成要件；犯罪的时间、地点、方法是一部分犯罪的构成要件。

犯罪客观方面的特征（一）犯罪客观方面是由刑法规定的犯罪客观方面是犯罪活动的种种外在表现，但并非任何犯罪客观事实都是犯罪的客观方面，能够成为犯罪客观方面的，只是那些依照刑法的规定，对行为的社会危害性及其程度具有决定意义的事实。

有些事实，如犯罪的时间和地点，在任何犯罪中都必然存在，

但并非任何犯罪都要以一定的时间和地点作为成立的客观方面要件。

（二）犯罪客观方面是行为对客体的侵犯犯罪客观方面与犯罪客体具有紧密的联系。犯罪客观方面所包含的各种事实特征，都说明某种犯罪是通过什么样的行为、在什么条件下对刑法所保护的客体进行侵犯的，以及这种行为造成或可能造成什么样的损害。

凡不能说明侵害犯罪客体的客观事实特征的，都不能成为犯罪构成的客观方面要件。

（三）犯罪客观方面是犯罪主观方面的客观外在表现犯罪客观方面同犯罪主观方面有密切联系，是主观见之于客观的事实情况。

犯罪行为包括主观和客观两方面内容。

其中，主观方面包括行为人内^⑩的故意或过失、犯罪目的和犯罪动机等，表现为行为人主观的意识和意志；而客观方面则是行为人在主观方面的支配下实施的危害行为、实施危害行为的时空条件、危害行为所指向的对象、危害行为产生的危害结果等，具有客观性、外在性、具体性等特点。犯罪主观方面支配犯罪客观方面，犯罪客观方面表现犯罪主观方面。没有犯罪主观方面，行为人不可能实施客观方面的行为并对犯罪客体造成危害；没有犯罪客观方面，单纯的犯罪意图尚不能构成犯罪，人们也无法认知行为人主观方面的内容。因而，犯罪主观方面和犯罪客观方面是密切联系在一起的。

上~. •` . ,. " . J 121

（四）

犯罪客观方面在犯罪构成的四个要件中居于关键地位

在犯罪构成的四个要件中，犯罪客观方面是一切构成要件的核心^⑩要件，犯罪客体、犯罪主体、犯罪主观方面这三个要件都是为了说明危害行为及其严重程度。没有犯罪客观方面，就意味着没有危害行为、危害结果，刑法所保护的社会关系就不会受到侵害，犯罪主体、犯罪主观方面也就无从产生。在犯罪客观方面中，危害行为又处于中心^⑩地位，其他要素则是为了说明行为的社会危害性及其严重程度。例如，危害结果说明危害行为对社会关系造成了损害的事实，犯罪对象说明危害行为所指向的对象，犯罪的时间、地点说明危害行为实施时的时空条件，犯罪方法具体说明危害行为的表现方式。因此，犯罪客观方面是行为人承担刑事责任的客观基础。

犯罪客观方面的意义

（一）

有助于区分罪与非罪

缺乏犯罪构成的客观方面要件，就丧失了构成犯罪及承担刑事责任的客观基础。我国刑法处罚的，只能是犯罪主体实施的危害社会行为，因为只有行为才能够对社会造成这样或那样的危害

。例如，没有非法剥夺他人生命的行为，就不会构成故意杀人罪；狩猎行为若不是在禁猎区、禁猎期或使用禁用的工具、方法实施，也不会构成非法狩猎罪。

（二）

有助于区分此罪与彼罪

在我国刑法中，有许多犯罪在犯罪客体、犯罪主体和犯罪主观方面都是相同的，将其区分为不同的犯罪通常是由犯罪客观方面决定的，侵犯财产犯罪中的抢劫、抢夺、盗窃、诈骗、敲诈勒索等罪之间的区分就是如此。犯罪客观方面具有⑨杂化、多样化，是犯罪⑨杂化、多样化的最突出的表现，这也是立法往往对犯罪客观方面加以具体规定的原因所在。

（三）

有助于正确分析和认定犯罪的罪过

刑法上的犯罪行为都是与一定的罪过相结合的，没有罪过就谈不上犯罪。罪过的实质内容是行为人对犯罪客观事实的认识和态度，是人的一种⑩理状态，不容易认识和把握。罪过只有通过一定的危害行为表现于外部，才会被认识和把握，而犯罪客观方面则具有直观性，有利于逆向认定犯罪主观方面。所以，罪过的认定，离不开犯罪客观方面。

（四）

有助于正确量刑

量刑要以犯罪的社会危害性及其严重程度为基础，而犯罪的社会危害性及其严重程度是由犯罪的主客观因素决定的。对于犯罪客体和犯罪主观方面相同的犯罪而言，其社会危害性及其严重程度主要取决于犯罪客观方面。有些犯罪之所以被区分为不同的罪、规定轻重不同的法定刑，主要是因为它们的客观方面所揭示的社会危害性及其严重程度不同，如抢劫罪与抢夺罪。我国刑法中的量刑原则和司法实践中的一些量刑规定，都要求充分考察客观方面对犯罪的社会危害性及其严重程度的影响。

第二节 危害行为

犯罪是人的行为。

“无行为则无犯罪亦无刑罚”已成为一种法律信念，是现代刑法的观念基础。在我国刑事立法中，“行为”一词不仅存在于刑法总则关于犯罪的概念以及其他规定中，也存在于刑法分则的许多规范中。

我国刑法惩处的犯罪，首先是人的危害社会的行为。危害行为是我国刑法中犯罪客观方面首要的、必备的要素，在每个犯罪构成中都居于核⑩地位。研究和把握犯罪客观方面，首先应当了解具体危害行为的内涵、外延及其基本的表现形式。

为正确理解危害行为的概念，应当区分行为、危害行为、犯罪行为这三个概念。“行为”一词在我国刑法文本中多次出现，是指刑法规定的一切对于犯罪认定、刑罚适用具有意义的人的举动，包括有益行为和有害行为、有意识的行为和无意识的行为、构成犯罪的行为和不构成犯罪的行为等，其外延最为广泛。

“危害行为”是犯罪构成中客观方面的一个要素，强调行为的危害性，它的范围比行为窄。和犯罪行为相比，其属于犯罪构成的一个要素。“犯罪行为”是指刑法规定的已经构成犯罪的行为，其外延较窄，强调行为已经具备了犯罪构成的全部要件。

危害行为的概念危害行为，又称危害社会的行为，是指表现人的意思自由、客观上危害社会并为刑法所禁止的身体动静。它具有以下特征：（一）客观上是人的危害社会的行为首先，危害行为的这个特征表明我国刑法坚决摒弃“思想犯罪”，将单纯的人的思想活动、思想方式排除于危害行为的外延，充分展示了危害行为的外在表现和客观方面，并与“意思刑法”划清了界限。因为如果单纯的思想活动不同人的行为联系起来，就不可能对社会产生实际的影响，不可能实际上危害社会，只有人的行为才可能对社会产生实际作用。

其次，我国刑法所惩罚的行为，只能是危害社会的行为，而不是其他任何性质的行为。人的行为对社会的影响形形色色，各不相同，但从性质上区分，不外乎有害于社会的行为和无害于社会的行为二种，行为两大类。

无害于社会的行为，尤其是其中有益于社会的行为，正是法律要予以保护的，当然不是我国刑法惩罚的对象。只有有害于社会的行为才可能成为我国刑法惩罚的对象，才可能成为我国刑法中犯罪构成的客观方面要件。

危害行为作为人的身体动作，与纯粹的思想活动有本质的区别，通常也易于区分，难以区分的是发表言论的行为。

言论作为发表思想观点、

表明主观意图的外在表现方式，其本身也可以说是一种行为。

至于它是不是危害行为，取决于言论的性质、作用以及发表人的主观心理状态。一般而言，发表有害言论，仅单纯地暴露思想的，并不是刑法上的危害行为；但意在实现这种言论所表达的思想，利用言论来危害社会的，如侮辱、诽谤、诬告陷害他人，教唆、引诱他人犯罪，以威胁性言论实施抢劫、强奸、敲诈勒索等，则超越了思想方式的范围，属于刑法上的危害社会行为。

（二）

主观上是表现人的意志或意识的行为

行为就是表现人的意识和意志的外部动作。

也就是说，只有在一定的意思支配下的动作，才能称为人的行为。

意识和意志是危害行为的内在因素或称主观因素。坚持这点就可以将人的无意识、无意志的身体活动排除于危害行为的范围之外，亦即只有在一定的意识和意志支配下的身体动静，才可能成为犯罪客观方面的危害行为。因此，人的无意识、无意志的身体动作，即使客观上造成损害，也不是刑法意义上的危害行为，不能构成犯罪并被追究刑事责任。

这类无意识和无意志的行为主要有：

1. 人在睡梦或催眠状态下的举动。这种举动不是行为人的意志或意识的表

现，即使在客观上损害了社会，也不能认定为犯罪客观方面的行为，不能构成犯罪。

例如，某甲深夜赶到父母家，用刀杀死父亲，砍杀母亲致其重伤。但案发后，经鉴定：事发时某甲处于一种医学上称为“临床睡眠”的状态。

在本案中，对于某甲所实施的行为就不能认定为犯罪客观方面的行为。

1. 人在不可抗力作用下的举动。这种情况下的举动也不是行为人的意志或

意识的表现，并且通常有悖于他的意志，由此造成的对社会的损害，也不能认定为刑法中的危害行为。例如，地震造成道路断裂，致使客车翻车，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失，就不能认定客车司机构成交通肇事罪。

1. 人在身体受到绝对强制下的举动。这种情况下的举动同样不是行为人的

意志或意识的表现，实质上是违背其主观意愿的。

即客观上其对身体被强制是无法排除的，由此导致危害结果的，也不能追究其刑事责任。例如，某铁道扳道员因被歹徒捆绑于道旁大树上，无法履行职责，致使火车出轨翻车，损失惨重。对于该扳道员未履行职责的行为，不能认定为犯罪。

同理，人的无意识之反射动作、人因疾病发作引起的抽搐、因触电或注射等而生之痉挛造成社会损害的，都非刑法上的危害行为。

但下列举动危害社会的，在某种程度上是人的意志或意识的表现，仍应认为是刑法上的危害行为：

(1) 受他人暴力胁迫致其意思受到一定影响，但未丧失意志自由，又不符合紧急避险等的行为；(2) 忘却行为，如扳道员因为睡觉而忘记职责，致使火车颠覆的情形；(3) 原因中的自由行为，如故意或过失醉酒使自己陷于无责任能力或限制责任能力状态下的杀人行为。

(三)

危害行为的刑法禁止性

这是危害行为与刑法的联系，是危害行为的法律特征。所谓危害行为的刑法禁止性，是指这种行为违反了刑法的规定，已经或者可能给社会造成危害后果。

也就是说，判断一种行为是不是刑法上的危害行为，不仅要看其在客观上对社会有无危害性，还要看该种行为是否为刑法所规定，即在客观上是否符合法律规定的构成要件特征。

认定危害行为时，把握危害行为的刑法禁止性，有助于正确区分刑法意义上的危害行为与自然意义上的身体动作。 比如某甲掏枪一今举枪-----+瞄准某乙的头部一扣动扳机一分乙被击中头部而死亡，这一系列的 身体动作，在自然观念中或许能作为⑨数行为来对待，但是，刑法所要惩罚的，是符合法定要件的行为而非某种具体的动作。 因此，上述杀人的数个身体动作，在刑法上只能被认定为一个故意杀人行为，某甲也只能构成一罪即故意杀人罪。

混淆了刑法上的危害行为与自然意义上的身体动作的概念，就不可能正确定罪。

综上所述，本书认为，危害行为有内在的、主观性的一面，亦具有客观性的一面，还有法律性的一面。 其中前两方面构成危害行为的事实特征，后一方面构成危害行为的法律特征。

作为犯罪客观方面的危害行为，就是这种事实特征和法律特征相统一意义上的行为。

危害行为的分类从不同角度可以对危害行为作不同的分类。

从行为的客观外在特征看，危害行为可分为作为、不作为和持有；

从行为在犯罪中的地位和作用看，危害行为可分为实行行为和非实行行为。

（一）作为、不作为和持有作为和不作为是根据危害行为的客观外在特征即身体的动、静状态对危害行为所作的分类，是对危害行为最基本的分类。 近年来，理论界认为，除作为和不作为之外，危害行为还存在一种特殊的形态，即持有，它介于两者之间，既不是作为，也不是不作为。

1. 作为。 作为是行为人以积极的身体活动实施的刑法禁止实施的危害行为，

第二t: f亡，宝 行刀是危害行为的一种基本形式。 简单地说，即“不应为而为”。

刑法分则规定的多数犯罪只能表现为作为的方式，如盗窃、抢劫等。

作为是危害行为的一种常态。

作为除必须具备危害行为的三个特征外，还有以下特征： （1）

行为人实施了刑法规范禁止实施的行为。 刑法分则关于具体犯罪的规定的背后都隐含着一定的禁止性规范，如盗窃罪隐含的禁止盗窃他人财物，抢劫罪隐含的禁止以暴力、胁迫或其他方法抢劫公私财物等，作为就表现为对这些禁止性规范的违反。 （2）

作为必须表现为身体的积极状态、动的状态。 （3）

作为是由人的一系列身体活动组成的，而不是孤立的、单个的动作。

不能把作为等同于亲手实施的行为。 具体来说，作为主要有以下几种实施方式： （1）

利用身体活动的作为，如身躯的运动、四肢的动作等； （2） 利用物质或信息工具的作为，如用

刀具砍杀、在互联网上发布诽谤信息，这是作为最常见的方式；（3）利用他人行为实施的作为，如利用无责任能力的未成年人实施贩毒、投毒行为，利用精神病人实施杀人、伤害行为，以及利用他人的过失行为实施杀人行为等；（4）

利用自然力的作为，如在上游放水闸，淹死下游钓鱼的人；（5）

利用动物实施的作为，如让毒蛇咬人、让恶狗咬人等；（6）利用职务上的便利实施的作为，如贪污、受贿等职务犯罪均系利用职务上的便利实施的作为式的犯罪。

1. 不作为。不作为是危害行为的另一种基本形式，是指刑法要求行为人必

须履行实施某种特定积极行为的义务，行为人能够履行而没有履行该义务的行为。

简单地说，不作为即“应为而不为”。在社会生活中，社会关系的内容包括权利和义务，犯罪对社会关系的侵害本质上是对权利义务关系的侵害。犯罪行为中有的直接侵害了权利，如以杀人方式侵害了被害人的生命权，以盗窃、诈骗等方式侵害了被害人的财产权等；有的则通过不履行义务的方式对权利造成了侵害。在特定社会关系中，权利的实现以义务方履行特定义务为前提，如果该特定义务得不到履行，权利也就得不到实现。不作为正是以不履行特定义务的方式侵害了被害人的权利，从而造成对刑法保护的社会关系的侵害。

（1）不作为的特征。

第一，从主体看，行为人负有实施某种特定积极行为的法律义务。

负有特定义务，是指根据法律规定，行为人在一定时间、空间或者在一定的情况下必须实施一定的积极行为，例如，成年子女有赡养父母的义务，新生儿的母亲有给婴儿喂奶的义务，纳税人有依法纳税的义务，等等。

第二，从行为状态看，不作为是一种消极的身体活动。行为人对于自己所负有的特定作为义务，没有作出法律要求的一定的积极动作或举动，是消极地不实施某种积极行为。当然，在不作为的情况下，行为人并非什么也没有做，其身体并非处于彻底静止的状态，只是没有做法律要求他必须做的事情，这是一种法律意义上的“静”，而不是自然的、物理意义上的静止状态。例如，母亲有给婴儿喂奶的义务，但不给婴儿喂奶，便是一种消极的身体活动，而不管母亲躺着完全不动，还是正在打麻将。

第三，从性质上看，不作为是刑法意义上的不作为。

行为人应当履行的积极义务，不仅是其他法律所要求的，同时也是刑法所要求的。

如母亲给婴儿喂奶，在刑法中表现为“禁止以任何方式非法剥夺他人生命”（《刑法》第232条规定的故意杀人罪）；子女赡养父母，表现为《刑法》第261条对遗弃罪的规定。如果实施某种积极行为的义务虽然在其他法律中有规定，但没有为刑法所要求，那么行为人即使没有履行该义务，也不是刑法上的不作为，如民法上关于“债务应当履行”的规定，行为人如果

违反了该义务，只承担民法上的违约责任，而不承担刑事责任。

(2) 成立不作为必须具备三个条件。

第一个条件：行为人应当履行特定义务。特定义务指在一定的社会关系内，基于一定的事实与条件产生的要求行为人实施一定积极行为的具体法律义务。首先，不作为中的特定义务产生于一定的事实与条件，如共同生活的家庭成员之间相互扶养的义务、现代社会生活中取得相应经济收入的自然人或法人纳税的义务等。其次，该特定义务属于法律义务，而不是道德义务。例如，由于我国现行刑法并未规定普通民众有救助义务，因此，普通民众见死不救的行为并不构成犯罪，尽管其可能违反了道德义务。最后，从内容上看，该特定义务的履行以作为为特征，法律要求行为人以积极的作为方式履行该义务。

正是由于行为人没有实施法律要求的特定积极行为，才构成了法律上的不作为。一般认为，不作为的义务来源于以下几个方面：一是法律上的明确规定，即行为人违反的义务是法律明确规定的。例如，我国《民法典》规定了夫妻有相互扶养的义务、父母有抚养子女的义务、子女有赡养父母的义务等家庭成员之间的义务，若行为人不履行该义务而遗弃家庭成员，就可能成立不作为的犯罪，构成遗弃罪。

二是职务上、

业务上要求的义务。

职务上要求的义务指国家工作人员基于其职务而产生的履行公务的职责。

权力和职责是对等的。

例如，

警察享有为维护社会治安秩序、侦查犯罪活动等采取强制措施权力，相应地，

警察也负有保护公民人身、财产安全和维护社会秩序等的义务。我国《人民警察法》第21条第1款规定：“人民警察遇到公民人身、财产安全受到侵犯或者处于其他危难情形，应当立即救助；……”因此，当人民警察发现公民人身、财产安全受到侵犯或者处于其他危难情形时，必须实施危难救助，而且必须“立即”实施救助，这是法律上的义务。3. . , . 千-已+ . • ~-; 4~ -j • / 'h 127律明文规定的，不得借口履行其他职责而拒绝履行。

人民警察不履行危难救助义务即不作为，情节严重的，应依法承担刑事责任。

业务指人们在社会生活中从事的具有一定专业性、持续性并能给其带来经济收益的活动。

业务行为不具有国家权力的性质。

医生对病人，不管病人有钱没钱，都不可以把他抛弃，否则可能构成相应的犯罪。例如，某医院给一个病人做了颅骨手术，后病人拒绝交纳住院费，医院院长就派人半夜把他送到了小树林，致病人死亡。

最高人民法院指定某中级人民法院审理此案，法院认定医院院长构成过失致人死亡罪。

三是法律行为引起的义务，如合同行为和自愿接受行为。关于合同行为，最简单的例子就是雇用保姆照看孩子，保姆对孩子负有保护义务，而这种保护义务就是基于合同建立起来的。

又如保镖有义务保护雇主的安全，在危难的时刻甚至要用自己的生命去保护雇主。

而自愿接受行为能否成为不作为的义务来源？即行为人本来不负有某种特定义务，在他自愿承担该义务之后，能否自动放弃该义务呢？例如，某甲发现在路边奄奄一息的陌生老人并把老人带回家里，找大夫给其看病，照料其生活。过了一段时间后甲觉得负担太重，将老人遗弃。甲是否构成遗弃罪呢？对此有两种不同观点。否定说认为，行为人原来没有法律上的义务，自愿承担义务的行为是一种积极行为，可以抵消后来自动放弃义务的消极行为，所以，行为人不应对造成的结果负责。肯定说则认为，自动承担义务是一种先前行为，一经实施，行为人就有义务将其履行到底，如果中途自动放弃，致使法律所保护的利益受到损害，行为人就应对这一结果承担刑事责任。本书认为，法益处于尤助、危险或者脆弱状态时，行为人基于自愿承担保护义务，使法益的保护依存于自己，行为人就必须继续承担保护义务，即行为人通过自愿接受这一法律行为为自己设立了一个积极作为的义务。

如登山队队员在登山时约定相互救助，他们之间就存在着照顾、保护他人的义务。

再如，将弃婴领回家中，就负有抚养的义务。

四是先行行为引起的义务。即先行行为导致刑法保护的社会关系处于危险状态时，行为人负有采取有效措施排除危险或防止危害结果发生的特定义务。

这个先行行为可以是合法行为，也可以是不法行为。例如，张某将自己7岁的侄儿带到水库里教他游泳，结果小孩淹死了。在这个案件中，张某把自己的侄儿带到水库这个行为本身是合法的，但带到水库后并没有履行自己的临时监护人职责，就被认为不法。行为只要制造了危险，不问是否正当，都会成为作为义务的来源，但正当防卫行为除外。因为对陌生人，任何人都没有保护义务，如果认为防卫者对于不法侵害人有保护义务，那么势必承认不法侵害者的法律地位高于陌生人。

但是其他的正当行为仍然可以引起保护义务，如紧急避险，紧急避险人对于遭受损害的第三者负有保护义务。

存在争议的问题是：先行行为可否包括犯罪行为？本书认为，首先，在刑法就某种故意犯罪行为规定了结果加重犯或因发生严重结果而成立重罪时，由于可以将加重结果评价在相应的结果加重犯或者另一重罪中，因此，不需要再评价行为人对加重结果的不作为。

例如，行为人严重违章导致重大交通事故（已经构成了交通肇事罪），为逃避法律责任，置生命处于高度危险状态的被害人于不顾，慌忙逃逸，导致被害人因得不到及时救助而死亡。此时，行为人明知被害人可能死亡，在能积极抢救的情况下逃逸，应否在交通肇事罪之外再成立一个故意杀人罪呢？答案是否定的。因为《刑法》第133条已经规定，交通运输肇事后，因逃逸而致人死亡的，处7年以上有期徒刑，故此时作为交通肇事罪的结果加重犯处理即可。又如，故意伤害他人，在被害

人具有死亡危险的情况下，行为人不予救助，导致死亡结果发生的，成立故意伤害致死。再如，非法拘禁他人并对他人使用暴力，在他人具有死亡危险的情况下，行为人不予救助，导致其死亡的，转化为故意杀人罪。这三个例子都不需要再单独考虑不作为犯的问题。其次，如果对于故意犯罪，刑法并没有像前面那样的规定，那么先前的犯罪行为导致另一法益处于危险状态时，应认为行为人负有保护义务。如行为人盗伐珍贵林木，树木倒下时砸着他人头部，行为人不予救助导致被害人死亡的，成立危害国家重点保护植物罪和不作为的故意杀人罪或者不作为的过失致人死亡罪，实行并罚。最后，过失犯罪与过失违法行为一样，都可以成为作为义务的根据。如行为人过失致他人受伤，具有死亡危险时，行为人故意不救助导致他人死亡的，成立不作为的故意杀人罪。

五是公共秩序和社会公德要求承担的义务。理论界认为，公共秩序和社会公德要求承担的义务一般不能成为不作为的义务来源，但在特定情况下，也可以成为刑法上的不作为的义务来源。实践中曾发生过这样的案例：被告人黄某与李某未婚同居，同居期间双方经常因家务事发生争吵、厮打。2008年6月12日晚8时，黄某与朋友聚会喝酒后回家，又与李某发生争吵。李某说：

“跟你在一起老打架，活着真没意思，不如死了算了。”说完便在屋里找农药欲服毒自杀。黄某马上找来邻居王某。王某劝说李某后，将农药瓶拿走。此后，黄某便自己在家喝酒。不久，黄某又与李某发生争吵，李某又讲要自杀，并在屋内找绳子。

黄某对李某说：“你要死，就去死吧。”然后继续喝酒。

李某找到绳子后，将绳子系在屋中的房梁上，踩着凳子自缢。

黄某一直在场喝酒，当看到李某自缢并将凳子踢倒时，便起身到离其住处500米的李某父母家，告诉他们李某自杀的事情。

李某父母赶到，将李某救下时，李某已经死亡。经法医检验，

李某系机械性窒息死亡（自缢）。法院以故意杀人罪对黄某判了刑。

在本案中，由于李某系自杀，黄某尤一...令·令。〈次·129j

1气论在法律上、职务上、业务上，还是基于先行行为、法律行为，都不负有救助李某的义务。但由于黄某和李某存在同居关系，且李某的自杀和黄某的行为存在因果关系，因而从公共秩序和社会公德方面看，黄某就负有保护李某生命、排除危险发生的义务，他应当以合理方式对李某进行抢救。由于黄某在客观上具有积极救助的义务，主观上明知自己的不制止、不救助行为可能造成李某的死亡，仍放任李某死亡，属于间接故意，故黄某的行为已经构成犯罪，法院的判决是正确的。

但公共秩序和社会公德所要求的义务在哪些具体内容上、在何种特定条件下可以成为刑法上的不作为的义务来源，还需要进一步研究。

第二个条件：行为人有能力履行该特定义务。 负有特定义务的人必须在能够履行特定义务的条件下不履行义务，即有能力履行并且有条件履行而不履行义务时，才构成刑法上的不作为。如果行为人负有某种特定义务，但不具备履行该义务的实际可能性的，则不构成犯罪的不作为。例如，仓库保管员被罪犯打晕，导致公共财产被抢走，以及家庭成员之间因尤抚养、赡养能力而未尽抚养、赡养义务等情况，就不宜认定为不作为犯罪。

第三个条件：行为人不履行该特定义务，造成或者可能造成危害结果。 多数情况下行为人只有不履行特定义务的行为造成危害结果的，才构成犯罪，但也并不尽然，有时候没有造成危害结果，也会构成犯罪，即不作为犯存在未遂、中止和预备形态。例如，王某重男轻女，为了生育男孩，决定饿死她新生的女儿。 饿死女儿也就意味着不履行哺乳的义务，不履行哺乳的义务就意味着她实行了不作为的故意杀人行为。但她的行为构成故意杀人罪并不要求必须造成女儿死亡的结果。 如果其女儿在即将被饿死时，被邻居发现，喂了食物后又活了下来，则王某的行为虽是一个未完成的形态，也构成故意杀人罪。

(3)

不作为犯的种类。

刑法上一般将不作为犯分为纯正的不作为犯和不纯正的不作为犯两类。 纯正的不作为犯，指刑法规定只能由不作为构成的犯罪，如遗弃罪等，这些犯罪不可能以作为的方式实施。这种行为由于在刑法分则中有明确规定，其义务来源只能是法律规定，认定起来并不困难。

不纯正的不作为犯，指以不作为的方式实施通常应以作为方式实施的犯罪，如母亲不给婴儿喂奶导致其死亡，医生不救治病人致使病人死亡等。 不纯正的不作为行为在刑法分则中没有明确规定，人们通常理解的该种犯罪的实行行为都是以作为方式实施的，因而理论界对不纯正的不作为犯的有关问题存在较大分歧，如前面论述的不作为的义务来源，即主要针对不纯正的不作为犯的。但也有学者指出，即使行为人负有上述义务，并且在有能力履行的情形下不履行，也不一定成立不纯正的不作为犯。 因为不纯正的不作为犯和作为犯所适用的构成要件是同一的，基于不作为和作为构造上的差异，不得不考虑不作为和作为的等价问题，即不作为引起的结果等同于作为引起的结果，从而限制不纯正的不作为犯的成立范围。 甚至有学者认为将不纯正的不作为认定为危害行为的做法违反了罪刑法定原则，进而主张所有的不作为犯只能是纯正的不作为犯。

本书认为，不纯正的不作为犯与作为犯具有同样的犯罪构成要件，将其认定为危害行为并不违背罪刑法定原则。 只不过，不纯正的不作为犯违反刑法的样态有所变形。 行为人的行为完成于危险状态产生之前，同时行为人在这一危险状态与现实的危害结果之间的时空间隔中有履行特定义务的现实可能性，其履行特定义务不仅足以避免危害结果的出现，还足以表明行为人对危害结果的发生并不抱希望或放任的态度（相对于故意犯罪而言），或对危害结果的发生已尽到足够的注意义务（相对于过失犯罪而言）。

但是，行为人并未履行该特定义务，危害结果也符合规律地发生了。这样，行为人在危险状态产生之前的“作为”与之后的“不作为”结合成一个完整的行为体系，且与危害结果之间存在因果关系，其行为与作为犯罪的行为一样，符合犯罪的全部构成要素。

因此，应当认为，不纯正的不作为犯的定罪完全统一于罪刑法定原则。

在理解不作为时，还应该注意以下几个问题：第一，不能把客观行为方面的作为、不作为的分类和主观罪过方面的故意、过失的分类混淆起来。

第二，以不作为方式实施的犯罪的社会危害性未必小于以作为方式实施的犯罪。例如，以不给女婴喂奶的方式饿死该女婴的行为和把女婴抛弃到荒山野岭导致其死亡的行为相比，前者的社会危害性未必更小。

第三，不能认为只有在发生了物质性危害结果的情况下，不作为行为才构成犯罪。

在纯正的不作为犯中，法律并不要求发生特定物质性危害结果。例如，《刑法》第261条对遗弃罪的规定是，“对于年老、年幼、患病或者其他没有独立生活能力的人，负有扶养义务而拒绝扶养，情节恶劣的”，构成遗弃罪，并未规定只有在造成物质性危害结果的情况下才构成犯罪。

在不纯正的不作为犯中，结果的发生是否犯罪的构成要件，需要以法律的规定为准，而不能以行为是作为还是不作为为准。例如，绝大多数过失犯罪的成立都要求发生特定危害结果，如果法定危害结果并未发生，则不构成犯罪，而无论其过失行为是作为还是不作为。在一些故意犯罪中，如果法律要求发生特定结果而事实上未发生，将构成犯罪未遂，如故意杀人罪、盗窃罪等，这也和行为以作为方式实施还是以不作为方式实施无关。

例如，企图以不作为方式杀人，即使被害人没有死亡，该不作为也构成故意杀人罪未遂。

1. 持有。英美法系刑法理论认为，持有是介于作为与不作为之间的另一种

气入 131行为方式。美国《模范刑法典》在规定了作为与不作为之后还规定了持有：如果持有人有意识地获得或接受了该持有物，或者在能够终止其持有的充分时间内知道自己控制着该物，则此种持有即为一种行为。

刑法理论认为，持有是对物品的控制状态，通常起始于作为，如取得、接受等，之后以不作为维持其存在状态，具有作为与不作为交融的特点。但持有是一种状态，因其没有积极的行为而区别于作为；因并不以不履行一定的积极义务为前提，也不同于不作为。作为的犯罪性明显地蕴含在主体自身的动作中，不作为的犯罪性取决于主体与法律要求之间的义务关系，而持有的犯罪性则体现于主体对非法财物（如毒品、凶器、不义之财、色情物品、犯罪工具等）的支配状态，所以持有是与作为、不作为并列的行为状态。

目前我国《刑法》规定的持有型犯罪主要有以下几种：（1）第120条之六非法持有宣扬恐怖主义、极端主义物品罪；（2）第125条第1款非法储存枪支、弹药、爆炸物罪；（3）第128条第1款非法持有、私藏枪支、弹药罪；（4）第130条非法携带枪支、弹药、管制刀具、危险物品危及公共安全罪；（5）第172条持有假币罪；（6）第177条之一妨害信用卡管理罪中的非法持有伪造的信用卡、非法持有他人信用卡这两种行为；（7）第210条之一持有伪造的发票罪；（8）第282条第2款非法持有国家绝密、机密文件、资料、物品罪；（9）第297条非法携带武器、管制刀具、爆炸物参加集会、游行、示威罪；（10）第348条非法持有毒品罪；（11）第352条非法持有毒品原植物种子、幼苗罪；（12）第395条第1款巨额财产来源不明罪。

持有是一种事实上的支配与被支配的关系，即行为人与特定物品之间存在着支配与被支配的关系。在理解持有时应注意以下几点：（1）持有是一种状态。即特定物品处于被行为人支配的状态时，行为人就持有该特定物品，只要这种事实上的支配关系存在，持有状态就存在。

（2）持有不是握有，不要求行为人时刻将特定物品拿在手中、放在身上或装在口袋里，只要行为人认识到特定物品的存在并能对其进行管理、控制，就是持有。

（3）持有并不要求行为人对特定物品拥有所有权。所有权虽然属于他人，但该特定物品事实上处于行为人的支配、控制之下的，行为人即持有该特定物品，如持有自己偷来的、抢来的特定物品。

（4）持有并不要求直接持有。即使有第三者的介入，仍然能成立持有。

例如，即使行为人将自己的特定物品交给他人保管，行为人仍然持有该特定物品。

（5）持有是一种持续行为。即行为人在一段时间内持有该特定物品。如果时：等入名j,吁玄沃}：汇间过于短暂，不足以说明其事实上支配该特定物品，则不是持有。

（二）

实行行为和非实行行为

实行行为与非实行行为是以行为在犯罪构成中的地位为标准对危害行为所作的分类。

1. 实行行为。实行行为，又称为构成要件行为，是指符合刑法分则各条规

定的犯罪构成并为完成某一犯罪所必不可少的行为。实行行为具有以下几个特点：（I）实行行为是一切犯罪的犯罪构成必备的行为，是依据刑法分则各条规定的非本构成要件确定的。刑法分则规定的实行行为都是以抽象性行为的形式来表示的，如故意伤害罪中的“伤害”行为、

故意杀人罪中的“杀人”行为、盗窃罪中的“盗窃”行为等，但这些实行行为都是具体性行为。

(2) 实行行为是具有侵害社会关系紧迫危险性的行为，仅具有危险但没有紧迫性的行为不是实行行为。

比如买刀杀人中的“买刀”行为，就并非杀人的实行行为⁽³⁾。实行行为是类型性的社会关系侵害行为，不包括偶然地导致结果发生的情况。例如，甲希望某乙死亡，就劝说某乙乘坐飞机，认为如果飞机失事则某乙必然死亡，在这种情况下，即使后来某乙确实死于飞机失事，也不能认为甲的行为属于实行行为。同理，希望他人死亡而劝人到公路上去跑步、劝人雷雨时在森林中散步、劝人不在学校超市买东西而穿越马路到对面去买东西，等等，即使发生了他人死亡的结果，也不能认为劝告人的行为属于实行行为。

1. 非实行行为。非实行行为指刑法总则规定的、在实行行为以外对实行行为起指使、唆使、帮助、补充作用的危害行为

，包括犯罪的预备行为以及共同犯罪中的组织行为、教唆行为和帮助行为^⑩

非实行行为具有以下特点：(1) 非实行行为必须是刑法分则规定的实行行为以外的行为。例如，强奸罪中的暴力行为等，因其已经在刑法分则中予以规定，因此属于实行行为而不是非实行行为。再如，刑法中规定的帮助伪造证据罪、组织卖淫罪等，虽然表面上看有帮助行为、组织行为等非实行行为的表现形式，但由于刑法分则已经将其规定为某种犯罪的构成要件，因此，它们都是实行行为。

(2) 非实行行为是依据刑法总则规定的修正的构成要件确定的。

(3) 非实行行为尚未对刑法所保护的社会关系造成现实侵害，它本身并不直接侵害组织行为、教唆行为和帮助行为虽非与实行行为相对的概念，但由于正犯实施的行为力实行行为，组织犯的组织行为力、教唆犯的教唆行为力、帮助犯的帮助行为力皆为正犯实施的行力之外的行为，故也可称之为非实行行为。

第二句

: L: 害结果

133能使犯罪达到既遂状态，只有通过实行行为才能对法定结果的发生产生作用。

第三节 危害结果

一、危害结果的概念犯罪行为引起的危害结果，是决定行为社会危害性的最根本因素，关系到对行为人的定罪与量刑问题。对于危害结果在定罪量刑上的重要价值，我国刑法学界没有分歧，但对于危害结果的概念则存在着不尽一致的论述。比如，有人认为，危害结果作为犯罪行为对客体的损害，是构成任何犯罪在客观方面的必备要件之一，既包括客观上已经造成的危害结果，也包括可能造成的危害结果。有人认为，危害结果是指犯罪行为已经造成的实际损害。有人则认为，有些行为一经实施即构成完整的犯罪（如侮辱罪、诽谤罪等），没有危害结果或者

说没有物质性危害结果；有些犯罪情况，如犯罪的预备、未遂和中止，也没有作为构成要件的危害结果，这样就产生了一些问题：危害结果到底是不是犯罪构成的必备要件？如果危害结果与犯罪客体密不可分，伴随着危害行为而产生，那么它作为犯罪构成要件在认定犯罪时是否还有实质和独立的意义？侮辱罪等到底有没有危害结果？犯罪的预备、未遂和中止不具备的是何危害结果？刑法上的因果关系研究的是何种性质的危害结果？等等。

可以说，危害结果是刑法学中使用较为混乱的一个概念，人们通常在不同意义上使用这一概念。

总的来说，危害结果有广义的危害结果和狭义的危害结果两种不同的含义。

广义的危害结果是指犯罪行为对刑法所保护的社会关系所造成的损害，包括构成要件结果和非构成要件结果、物质性危害结果和非物质性危害结果、直接结果和间接结果等。它着重表现行为的社会危害性，说明任何犯罪行为都会产生危害结果，如行为犯的危害性、结果犯中的物质性危害结果、危险犯中的危险状态，以及未遂犯、中止犯所造成的实际损害等。从这个意义上说，任何犯罪行为都会侵害刑法保护的社会关系，因而在任何犯罪中都有危害结果产生。

狭义的危害结果，又称构成要件结果，是由犯罪的实行行为造成的、根据刑法分则的规定对成立犯罪或者犯罪既遂具有决定意义的危害结果，它只存在于过失犯罪、间接故意犯罪和结果犯的既遂犯中。狭义的危害结果具有以下特征：第一，只能是危害行为对犯罪的直接客体造成的损害，即直接危害结果。

间接危害结果不能作为犯罪构成的基本要件，不决定犯罪的构成，因而不是该意义上的结果。但是，直接危害结果并不都是构成要件结果即狭义的危害结果，如故意杀人案中的重伤结果，是由危害行为直接造成的，但不属于杀人罪的构成要件结果，行为人只能构成杀人未遂。

第二，依照刑法规定属于构成要件的一部分。

例如，过失伤害他人致人重伤的，依法构成过失致人重伤罪。

“致人重伤”就是作为过失致人重伤罪的构成要件的危害结果，这是由刑法明文规定的。

同样，《刑法》规定，“引起检疫传染病传播或者有传播严重危险的”，以及“足以使火车、汽车、电车、船只、航空器发生倾覆、毁坏危险，尚未造成严重后果的”，分别是作为妨害国境卫生检疫罪、破坏交通工具罪的构成要件的危害结果。

这说明作为构成要件的危害结果，既包括已经造成的现实损害，也包括法定的危险状态。

但是，刑法未规定为某罪构成要件的结果，不能作为狭义上的危害结果。

即使对于结果犯，也并不意味着危害行为的现实损害就等同于狭义上的危害结果，

比如重伤就不是故意杀人罪构成要件的危害结果。

第三，作为法律规定的构成要件，狭义危害结果对于定罪具有重要意义。例如，在故意杀人案件中，伤害结果不是该罪的构成要件，只是量刑情节；而在故意伤害案件中，伤害结果直接决

定了该罪的成立，故意伤害行为直接造成的死亡结果，却成了量刑情节。

关于危害结果在犯罪构成上的地位，中外刑法理论中均有尖锐的论争。基于对危害结果在广义与狭义两种意义上的界说，本书认为，危害结果不是一切犯罪构成的必要要件。

危害结果的分类这里的分类是对广义的危害结果的分类。主要有以下几种不同的分类：

（一）

构成要件结果与非构成要件结果

构成要件结果即前面论述的狭义的危害结果，因其对定罪具有决定意义，又称为定罪结果。

非构成要件结果，是指由危害行为引起的、构成要件结果以外的、对于该种犯罪的社会危害性程度及其刑事责任的大小具有一定评价意义的损害结果。

在广义的危害结果中，构成要件结果之外的其他结果都是非构成要件结果。

非构成要件结果最重要的意义在于影响量刑，因而又称量刑结果。

非构成要件结果包括以下数种情形：第一，行为犯造成的结果。例如，在诬告陷害罪这一行为犯中，有的诬告陷害行为刚实施完毕，司法机关就发现行为人在诬告陷害，行为对被害人可能没有产生影响；而有的诬告陷害行为可能导致被害人已经被逮捕甚至被判刑。

这些不同的结果对量刑当然具有重要意义。

第二，预备犯、未遂犯、中止犯造成的结果。在预备犯中，有的预备行为本身并不违法，只是因为它是为犯罪的实行准备工具、制造条件的行为，才具有了违法性，这样的预备行为没有产生危害结果，如为杀人而购买菜刀，此行为本身并不违法，也不会直接产生危害结果。也有的预备行为本身已经违法并且产生了危害结果，如为了杀人而盗窃枪支，该盗窃行为不但是违法的，还造成了枪支所有人对被盗枪支失去控制、失去占有。

两种不同情况如果均只成立故意杀人罪的预备，那么在量刑时，处刑的轻重应该有所不同。在未遂犯中，有的未遂犯可能未造成任何物质性结果，如开枪杀人时未打中被害人；也有的可能出现了一定的危害结果甚至较严重的危害结果，如开枪杀人时虽然未致被害人死亡，但造成了被害人受伤的结果。

对这些不同的未遂犯，在量刑时应该有所区别。

在中止犯中，《刑法》第24条第2款规定：“对于中止犯，没有造成损害的，应当免除处罚；造成损害的，应当减轻处罚。”这里的“损害”即指该种非构成要件结果。

第三，间接结果。这是指由直接结果进一步引起的危害结果。例如，强奸行为发生后被害人因受刺激而精神失常或自杀，被害人用来治病的钱遭窃之后因无钱医治疾病而死亡，等等。

这些结果不影响强奸罪或盗窃罪的成立与否以及是否既遂，但对于量刑具有一定的影响。

第四，精神损害。 这是指危害行为给被害人（广义的）的正常生活、工作、学习，威信和名誉，人格和⑩理等造成了极坏影响，使其⑩理上产生的较大痛苦等。

如侮辱罪、强奸罪使被害人羞愧难堪，受贿罪使政府威信下降，等等。

（二）

物质性危害结果与非物质性危害结果

物质性危害结果，又称有形的危害结果，具有具体、可见、可以计量的特点，如人的死亡、伤害结果的发生、财产的损害等。 物质性危害结果一般不是犯罪一经着手就发生或者伴随着实行行为同时发生，而是在实行行为实施完毕后才发生的，可能在实行行为实施完毕之后随即发生，也可能再过一段时间才发生。

物质性危害结果中既包括构成要件结果（一般地说，刑法分则规定的构成要件结果都是物质性结果），也包括一些非构成要件结果；物质性危害结果既可能是直接结果，也可能是间接结果。

我国刑法关于物质性危害结果的规定，大致有下列几种情况，反映了危害结果在不同犯罪中的不同意义：第一，有些犯罪以对直接客体的现实损害作为犯罪既遂的标准。

在我国刑法中，这样的条文很多。 在这种情况下， 一般地说，判定犯罪的既遂与未遂，要看行为是不是已经造成有形的物质性危害结果，比如故意杀人罪、盗窃罪、诈骗罪等。

第二，有些犯罪以发生某种危害结果的危险性作为犯罪既遂的标准。

即不要求发生某种有形的结果才认定为既遂，只要出现法定的某种结果的危险状态，就136第成立既遂。

第三，有些犯罪以发生严重危害结果作为犯罪的构成要件，缺少该严重危害结果，不构成犯罪。 例如，对于过失犯罪，刑法一般都要求造成严重危害结果时才构成犯罪。

第四，有些犯罪以危害结果的轻重作为定罪或量刑的标准。

这类规定在刑法条文中不少，因此有犯罪基本构成和加重构成的区分，如刑讯逼供罪等。

第五，有的犯罪依某种危害结果决定案件的诉讼程序。 例如，我国刑法关于侮辱罪、诽谤罪的规定，通常情况下是“告诉的才处理”，即被害人不告诉，司法机关不主动追究；被害人告诉的，司法机关才受理。” 但是严重危害社会秩序和国家利益的除外”，即在这一情况下，由于侮辱、诽谤行为严重地危害了国家利益和社会秩序，就成了公诉案件，依法由国家检察机关提起公诉，从而使得诉讼程序发生了变化。

非物质性危害结果，又称无形的危害结果，它具有抽象性，不能直接看见，无法具体测量，如名誉权受到损害、人格被侮辱、尊严丧失、国家机关的威信遭受损害等。

非物质性危害结果虽然看不见，但仍然是客观存在的，人们可以通过一定的方式感知其存在。

（三）

直接结果与间接结果

直接结果，指由危害行为本身直接引起的损害结果，如故意杀人罪中被害人被杀死，诈骗罪中财物被骗走，等等。构成要件结果只能是直接结果，但直接结果未必都是构成要件结果，如行为犯引起的结果是直接结果，但不是构成要件结果。

间接结果，指由直接结果进一步引起的危害结果。例如，被害人被强奸后羞愤自杀，被害人财物被盗窃后因无钱治病而死亡，这样的结果是由直接结果所引起的。又如，被害妇女被拐卖后其丈夫精神失常，其孩子因而辍学，后在流浪时遇车祸死亡，该结果就是由间接结果进一步引起的结果，仍然属于间接结果。间接结果对量刑有意义，有的刑法条文对此作了明确规定。如《刑法》第240条第1款第7项规定，在拐卖妇女、儿童罪中，“造成被拐卖的妇女、儿童或者其亲属重伤、死亡或者其他严重后果的”，适用更高法定刑。这里的“造成被拐卖的妇女、儿童重伤、死亡”既包括直接结果，也包括间接结果，而“造成其亲属重伤、死亡或者其他严重后果”只能属于间接结果。

多数刑法条文对间接结果并未明确规定，但只要发生了间接结果，在量刑时就应该予以考虑。所以，间接结果都是非构成要件结果。

（四）

基本结果与加重结果

基本结果

，是指作为犯罪构成要件的结果，是犯罪行为对该罪直接客体造成第'.', .1十.，曰门」上⑧忱果天系的损害。

加重结果，是指实施一种犯罪行为，具备该罪的基本要件，却引起了另一种严重的危害结果（因而法律规定加重其刑罚）。这种造成加重结果的犯罪，刑法理论上称为结果加重犯，亦称加重结果犯。

在刑法上，基本结果是某罪的基本构成要件，加重结果是加重构成的要件。

结果加重犯的加重结果以刑法的明文规定为限，未发生法定的加重结果，不适用结果加重犯的规定，不发生未遂的问题。

第四节 刑法上的因果关系

一、刑法上因果关系的概念因果关系是哲学上的一个重要范畴，是指一种现象在一定条件下引起另一种现象。引起其他现象的现象是原因，被引起的现象是结果，两种现象之间引起与被引起的关系，即因果关系。

辩证唯物主义因果关系的理论与刑法上因果关系的理论，是一般与个别、普遍与特殊的关系。

我国刑法要求，一个人只能对自己实施的危害行为及造成的危害结果承担刑事责任。因此，当危害结果发生时，要使某人对该结果负责，就必须查明他所实施的危害行为与该结果之间具有因果关系。这种因果关系，是在危害结果发生时使行为人负刑事责任的必要条件。刑法学是研究犯罪及人的刑事责任的，注重人的危害行为与危害结果之间的因果关系。我国刑法总则虽然没有对查明因果关系问题作出一般规定，但是，查明某人的危害行为与危害结果有无因果关系，是正确解决某些犯罪（如结果犯）刑事责任的必要条件。

据此，本书认为，所谓刑法上的因果关系，是指人的危害行为合乎规律性地引起某种危害结果的内在联系。

刑法上因果关系的特点以辩证唯物主义因果关系的理论为指导并结合刑法特色，我国刑法理论认为，我国刑法中的因果关系具有以下特点：

（一）

因果关系的客观性

因果关系是客观存在的、不以人的意志为转移的客观现象之间的引起和被引起关系。人们主观上对因果关系的认识，是客观存在的因果关系现象的反映，只有真实反映客观因果关系的认识，才是正确的认识。因此，不能用主观设想和推测代替实在的客观联系，也不能以行为人对因果关系有无认识来决定因果关系是138

1仁臣客观方面否存在。

在司法实践中，不能凭司法人员的臆测确定因果关系的有无，而应对客观现实已存在的两个现象危害行为和危害结果，进行周密、细致的调查研究，按照客观事物本身的规律来判断。例如，某售货员态度不好，与一个老年顾客发生争吵，并对该顾客说了一些侮辱性语言，使老人很气愤，当即引发脑溢血，猝死在柜台旁。对此，我们绝不能以侮辱者不知道会有该后果的发生而否认他的行为与老人死亡之间的因果关系，也不能以

"一般情况下"该行为并不一定导致这种结果来否认客观存在的因果关系。

至于侮辱者是否应当负刑事责任，则应在主观方面进一步考察其有无罪过。

（二）

因果关系的相对性

在客观世界中，各种现象都是普遍联系、互相制约的，并形成一个个错综复杂、相互联系的因果链条。一现象中的原因，可能是另一现象中的结果，所以我们在研究哪个现象是原因，哪个现象是结果时，必须把一对现象从普遍联系的链条当中抽取出来，才能显示出一个是原因，另一个是结果。在刑法上研究因果关系，也必须把危害行为和危害结果从普遍联系的链条中抽出来，作为一个矛盾运动的发展过程加以研究，从而使危害行为和危害结果分别取得原因与结果的绝对意义。

例如，甲欠乙

1

万元，乙多次逼讨，甲遂挺而走险，某夜抢劫一金融机构并杀死一保安，抢走现金 2 万余元。该保安在外地的妻子，闻讯后上吊死亡。如果我们确定该保安之死为甲杀害行为的结果，甲的杀害行为是死亡的原因，我们就必须暂时把甲的抢劫行为同乙的逼债行为之间的联系割断。只有这样，才能肯定甲的杀害行为是原因，保安之死是结果。也应指出，该原理只是针对原因与结果概念的相对性而言的，并不意味着研究问题（包括因果关系）可以不顾及现象中的各种复杂联系。比如说，我们在对甲追究抢劫罪责时，也要看到甲的杀人抢劫行为与保安之妻的死亡具有一定的间接联系，因此，依法应对甲从重处罚。

（三）

因果关系的时间顺序性

因果关系的时间顺序性，就是从时间上看，必定是原因在先，结果在后，二者的时间顺序不可颠倒。因此，在司法实践中，只有查明某人的行为是在某种危害结果发生之前实施的，该行为才可能成为造成该结果的原因。而危害结果发生以后的行为，就不能认为是结果发生的原因，当然也不存在刑法上的因果关系。

但是，危害结果之前的行为，不一定是产生危害结果的原因。例如，甲给乙一张电影票，乙去影院途中遭遇车祸死亡。甲的行为就不是乙死亡的原因，两者之间只是一种表面上的、偶然的联系，因为甲的行为对于乙的死亡不具有原因力，不存在因果关系。

了&Li+J 尸1士上笆I. j\i 因果关系 139

（四）

因果关系的条件性

人的行为不可能超时空而孤立地存在和发展，某种危害结果的产生，总是与当时具体的时间、地点以及其他各种各样的条件相结合、相作用的。

脱离刑事案件中的各种具体条件独立地看待行为，是不可能正确判断因果关系的。

任何案件的因果关系都是具体的、有条件的。例如，甲、乙二人因故发生口角，甲向乙的腹部猛

击一拳，乙即时倒地，后在送往几十里外医院的途中死亡。尸检结论表明乙患有先天性脾脏过大症，这种脾脏遇外力打击极易破裂，但若抢救及时还不至于死亡。本案中，若乙的脾脏正常或距医院较近没有失去抢救时间，在同等打击下或者脾脏不致破裂或者能够获救，但我们并不能由此否认在这个案件中甲的拳击与乙的死亡之间存在因果关系。

（五）

因果关系的⑨杂性

这主要表现为“一因多果”或“一果多因”。

“一因多果”，是指一个危害行为可以同时引起多种结果的情况。

例如，甲诽谤乙，并导致乙自杀；甲放火烧毁了大片房屋，并烧死、烧伤数人。在这种情况下，就要分清构成要件结果和非构成要件结果、直接结果和间接结果，以便做到定罪准确、量刑适当。

“一果多因”，是指某一危害结果由多个原因引起的情况。最明显地体现为两种情况：一为责任事故类犯罪；二为共同犯罪。这时就必须弄清每个人的行为（原因）对结果所起作用的大小，亦即必须分清主要原因、次要原因，以便准确地认定各自应负的责任的大小。

（六）

因果关系的必然性和偶然性

刑法上的因果关系最本质的问题是必然性还是偶然性的问题。若某种危害结果是由某人的行为内在、合乎规律地引起的，行为与结果之间的这种联系，就是必然因果关系；某行为不包含产生某种结果的内在根据，但在其发展中偶然与另一个必然因果过程相交叉，由后一原因合乎规律地引起该结果，其最初的行为（即第一因果过程中的行为）不是最后结果（即第二因果过程中的结果）的具有决定性的必然原因，而是非决定性的偶然原因，就是偶然因果关系。

一般认为，刑法上的因果关系是必然因果关系，但这个必然性又是通过偶然性表现出来的。

例如，妇女某甲追打其子某乙，某乙跑上公路，恰遇某丙驾车驶来，某丙见状即刻刹车，但因距离太近，终将某乙撞死。

某乙的死与某丙的行为有必然因果关系。

然而，如果不是某甲追打某乙致其慌不择路，某乙被撞死的结果就不是必然会发生的。

因此，某甲的行为与某乙死亡的结果具有偶然因果关系。但是，正是因为某甲的追打，某乙才跑上公路，从而使某乙不可避免地被汽车撞死，因而表现出了一定的必然性。

没有必然性，偶然因果关系也就没有存在的可能。

所以，必然因果关系与偶然因果关系是刑法上因果关系的两种表现形式，而因果关系本

第八章

沪罪客观方汇身则是必然性和偶然性的统一。

其中，前者是最常见的和最主要的形式，司法机关在确定罪名、裁量刑罚时尤其要注意这一点。

刑法上因果关系的性质刑法上因果关系的性质，是指危害行为在特定具体条件下合乎规律地引起了危害结果的发生。具体包括两个方面的内容：（一）作为原因的危害行为，必须具有引起危害结果发生的现实可能性认定因果关系，意味着将结果归属于某个危害行为。而危害行为本身是具有造成危害的危险的行为，所以，因果关系的发展进程，实际上是危险的现实化过程。因此，如果行为本身不具有危害社会的危险甚至减少了危害社会的危险，就不可能是危害行为，也就不可能将结果归属于该行为。也就是说，在危害行为的“因”和危害结果的“果”之间存在着相同的质，二者具有质的同一性。作为原因的危害行为，一定包含着引起危害结果发生的根据和内容，否则，该结果就不会由该行为引起。

某种结果一定是由能够导致这种结果发生的行为引起的，其他行为不可能产生这样的结果。正是由于因果之间存在着相同的内容和根据，它们之间才具有引起与被引起的关系，原因才具有引起结果发生的现实可能性，这是因果关系的前提。

例如，甲用刀刺伤乙的手臂，造成乙轻微伤，住院治疗。

医生用未经消毒的器械对其进行治疗，结果乙因感染而死亡。

甲的行为不含有致乙死亡的现实可能性，不能认定其行为和乙死亡具有因果关系。

医生的行为包含着导致乙死亡的现实可能性，不能排除其因果关系的存在。

再如，甲希望乙死亡，就劝说乙乘坐飞机，认为如果飞机失事则乙必然死亡。在这种情况下，假设后来乙确实死于飞机失事，由于甲的行为中并不必然具有引起危害结果发生的现实可能性，不可能合乎规律地引起危害结果的发生，因而，从实行行为性质的角度考察，甲的行为不具有实行行为性；从因果关系的角度考察，甲的行为和危害结果之间不存在相同的质，其行为中不包含引起危害结果发生的根据和内容。

（二）作为原因的危害行为，必须合乎规律地引起危害结果的发生只有危害行为合乎规律地引起了危害结果的发生，才能认定因果关系。如甲将乙打成重伤，乙住院治疗时因伤势严重，医院下了病危通知书，恰巧同室病人丙和乙有⑧，就趁乙昏睡时向乙投毒，使乙中毒死亡。甲的行为虽然可能导致乙死亡，但事实上死亡结果并不是甲的行为引起的，甲自不能对死亡结果承担责任。

判断危害行为是否合乎规律地引起危害结果的发生，需要注意两个问题：（一）该结果必须具有回避可能性。如果结果没有回避可能性，我们就不能说危害行为合乎规律地引起了危害结果，而可以直接否认危害行为与危害结果之间的因果关系。（2）所引起的结果应是具体的，具有特定样态、特定规模，发生在特定的时间与地点，而不是抽象意义上的结果。例如，即使被害人死亡，也要分清是毒杀还是因病死亡，是流血过多死亡还是窒息死亡，是被合法处死还是被非法处死，等等。只有具体地判断危害结果，才能准确地把握刑法中的因果关系。

刑法上因果关系的认定在通常情况下，危害行为合乎规律地引起了危害结果是清晰可辨的。例如，甲用刀捅中乙的⑩脏导致乙死亡；甲虚构事实欺骗他人，他人基于认识错误处分财产。在这些案件中，可以直接肯定刑法中的因果关系，并不会发生认定上的困难。但在有些案件中，虽然危害结果同样十分显见，但这种危害结果是否由行为人的危害行为所引起，并非一目了然。

（一）

假定的因果关系

所谓假定的因果关系，是指虽然某个行为导致结果发生，但即使没有该行为，其他情况也会产生同样结果。例如，某刑场正准备对罪犯执行死刑，在执行人扣动扳机的瞬间，被害人的父亲甲推开执行人，自己扣动扳机打死了罪犯。又如，乙和丙都想杀死丁，在没有意思联络的情形下，在丁准备进行穿越沙漠长途旅行的前夜，乙在丁的水壶底部钻了一个小洞，而丙则将丁壶里的水换成无色无味的毒药。

次日晨，丁出发了，由于没有发现壶底的小洞，其在沙漠中想喝水的时候发现水壶是空的。由于没有其他水源，丁被渴死。在这两个案例中，对于是否承认甲、乙的行为与死亡结果之间存在因果关系，刑法学界还存在争议。本书认为，至少可以肯定的是，死刑犯的死亡结果和丁的死亡结果，分别是由甲、乙的行为合乎规律地引起的，因此，应当直接肯定因果关系的存在，不需要考虑附加的假定因素。

（二）

重叠的因果关系

重叠的因果关系，是指两个以上相互独立的行为，单独不能导致结果的发生，但合并在一起导致结果的发生。例如，甲乙没有意思联络，分别向丙的食物中投放了致死量 50% 的毒药，二人行为的重叠达到了致死量，丙吃食物后死亡。

在这种情况下，由于甲乙的行为都对丙的死亡起作用，故肯定甲乙二人的行为与丙的死亡之间的因果关系。

（三）

流行病学的因果关系

在污染环境罪等犯罪中，要认定犯罪的成立，排污行为与环境污染的结果之间必须有因果关系。这种因果关系比一般因果关系⑨杂，表现在三个方面：（1）

主体的多样性，即同一污染事故往往是不同主体同时向环境中排污引起的；（2）

过程的⑨杂性，即各种污染物被排入环境后，

互相之间及其与环境各要素之间会进行多种物理的、化学的、生物的作用或反应；（3）结果的

⑨杂性，即污染结果往往不是立即发生的，违法排污行为与环境污染的结果之间的间隔时间可能相当长。所以，实践中查明该因果关系往往十分⑨杂。国外司法实践中一般采用推定原则。

我国有学者将这种因果关系称为流行病学的因果关系。其主要内容包括两个方面：

1. 必要条件。一般的因果关系在逻辑学上表现为充要条件，即有 A 则有 B，

无 A 则无 B；认定环境污染的原因时则采用必要条件，即无 A 则无 B，有 A 但未必有 B。这是因为排污行为与环境污染之间的因果进程往往不能查清。

1. 病因学旁证法，即根据临床医学判断，在一定区域内被害人发生了某种

疾病，并且预断其可能是由某种污染物引起的，且被害人住地附近的一些污染源恰恰排放这种污染物，就可以推定环境犯罪因果关系的存在。

根据病因学旁证法认定因果关系时应符合四个条件：（1）

病因子（污染物）在发病前已经存在；（2）

该病因子在环境中的浓度越大、数量越多，该种疾病的发病率就越高；（3）

当该病因子减少或被消除时，该种疾病的发病率也下降或被消除；（4）

病因子与疾病之间的因果关系符合一般的生物学规律。

这种因果关系的认定方法不仅为刑法所采用，也为民法认定环境损害赔偿时所采用。

（四）

不作为犯的因果关系

关于不作为犯的因果关系，主要有以下几种不同的观点：否定不作为犯因果关系说认为，不作为是物理上的“无”的状态，尤中不可能生有，即人的身体的消极静止状态未给外界以任何物理性的力量，不会使外界产生任何变化或反应，所以不作为对于结果的发生没有原因力。由于该说将不作为当成“无”，否定了不作为的行为性，因此已经被抛弃。

不作为准因果关系说认为，不作为本来是一种“无”的状态，对于结果的发生本来没有原因力，但不作为的行为人负有防止结果发生的作为义务，行为人不履行该义务而放任结果的发生，具有“如尤其不作为，则不发生该结果”“如果其履行了该义务，则不至于发生该结果”的特征，所以法律才赋予不作为对于结果发生的原因力。

这种情况是法律上的拟制，因而将其称为“不作为准因果关系说”。

有学者认为，该说不是在不作为行为中寻找原因力，而是求诸法的拟制，是不妥当的；该说既认为不作为是“无”的状态，又称不作为的因果关系与作为的因果关系等同，也是不妥当的；而且不作为中违反作为义务属于违法性问题及构成要件的该当性问题，不能将其与等见”，

尸法上扫因果关系因果关系混为一谈。

肯定不作为因果关系说认为，不作为行为与结果之间存在着因果关系。

这是刑法学界的主流观点。首先，从权利义务的关系上看，如果义务主体不履行义务，权利主体就不能享受权利，从而使法律关系受到侵害。不作为正是因为行为人负有特定义务而不履行义务，才使法律关系遭受破坏，造成具体的危害结果。

其次，作为与危害结果之间的关系一般表现为：如果没有该行为，危害结果便不会发生，故该作为是原因。不作为与危害结果之间的关系则表现为：如果行为人履行义务，危害结果便不会发生，故不履行义务是原因。二者虽然在形式上有差异，但因果联系的内容是相同的。

本书认为，不作为行为与危害结果的因果关系是客观存在的，而不是基千法律的拟制。不作为的原因力，就在于它应该阻止而没有阻止事物向危险方面发展，以至于引起了危害结果的发生。不作为犯罪因果关系的特殊性在于：它以行为人负有特定的作为义务为前提。除此以外，它的因果关系应与作为犯罪一样看待。

（五）

中断的因果关系

某种行为虽然具有引起危害结果发生的现实可能性，但如果在因果关系发展的进程中介入了其他危害行为或因素，这种介入的危害行为或因素还可能加速或延缓因果关系的发展进程，甚至改变因果关系发展的方向和趋势，以致切断了原来的因果进程，由中途介入的危害行为或因素合乎规律地引起危害结果的发生，那么我们就把后一种情形叫做中断的因果关系。所谓中断的因果关系，是指某种危害行为引起或正在引起某种危害结果，在因果关系的发展过程中，介入了另一原因，从而切断了原来的因果关系。

例如，甲投毒欲杀害乙，乙在快中毒身亡的时候被丙开枪打死。在本案中，由于丙的后因行为的介入，切断了甲的前因行为与乙的死亡结果之间的因果关系，因此，甲仅负故意杀人未遂的责任，不能认为是故意杀人既遂，而丙应负故意杀人既遂的责任。

介入因素在司法实践中主要包括三类情形：自然事件、他人行为以及被害人自身行为。但并不是所有的介入因素都能导致因果关系的中断，在案件存在介入因素的场合，判断其对因果关系的影响，需要综合考虑以下三个因素：

1. 最早出现的实行行为导致最后结果发生的可能性的。对被害人造成

危及生命的重伤，和只对被害人造成轻伤相比，虽然后来都介入了医生的重大失误，从而引起被害人死亡的结果，但重伤行为更容易被评价为死亡的原因。

当然，也不能仅仅根据行为所具有的导致结果发生的概率来判断因果关系。例如，甲追杀乙，乙无奈狂奔逃命，乙的⑧人丙早就想杀乙，偶然见乙慌不择路，在甲尚未赶到时，开枪射击致乙死

亡。这时，死亡结果应该由丙负责，即使甲的追杀144
肇行为导致乙死亡的概率很高，乙的死亡和甲的追杀之间也没有因果关系。
而这就涉及下面两个因素的判断问题。

1. 介入因素异常性的。介入因素过于异常的，危害行为和最终结果之
间的因果关系就可能不存在；反之，因果关系存在。

介入因素是否异常，必须和危害行为联系起来，考虑介入因素在多大程度上具有通常性。

在做这种判断时，必须依次考虑该介入因素：（1）是否由最初的危害行为所必然引起；（2）
是否常常伴随该危害行为发生；（3）是否存在几乎不发生的情况；（4）
是否和危害行为完全尤关地发生。例如，甲点燃乙身穿的衣服，乙跳入水中溺死或因⑩脏停搏而
死亡，甲的行为导致乙不得不或几乎必然实施介入行为，因此，乙的介入行为具有通常性，甲应
对乙的死亡结果负责；又如，甲杀乙，仅导致乙轻伤，但乙因迷信，不仅不去就医，反而用香灰
涂抹伤口，致毒菌侵入体内死亡，这时乙的行为就具有异常性，甲不对乙的死亡结果负责。

1. 介入因素对结果发生的影响力。影响力大者，最初危害行为和最后结果

之间的因果关系不存在；反之，因果关系存在。在最初的危害行为使被害人生命随时可能丧
失的情况下，后来介入的暴力行为只是使被害人的死期稍微提前，虽然从表面上看后来的介入行
为导致被害人死亡，但也应当将死亡结果归属于最初的危害行为。

例如，行为人甲重伤乙，乙倒在路边，濒临死亡，恰遇乙的⑧家丙路过，乙向丙求救。

丙不但不出手相救，反而乘机辱骂乙，乙气急攻⑩身亡。

在这种情况下，乙的死亡应归因于甲的重伤行为。相反，无论最初的危害行为对被害人伤害多重
，在有“故意射杀”这种足以超越最初危害行为的因素介入时，导致被害人身负重伤的危害行为
和最终的死亡结果之间就没有因果关系。

刑法上的因果关系与刑事责任因果关系是犯罪客观方面的内容，有因果关系并不意味着就是
犯罪，还要看行为人的主观方面。

例如，张某碰到李某说：“老朋友多年没见了，让我捶你一拳。”结果张某一拳过去李某死
了。如果张某根本就没有认识到也不可能认识到李某有⑩脏病的话，它属于一个意外事件，即使
有因果关系，也无须承担刑事责任。

假如当时李某说：“不可以捶，我有⑩脏病，捶了会死的。”可张某说：

“看你长得这么结实，怎么可能被捶死？”结果一拳过去，李某死了。李某已经认识到捶击行为
有可能导致自己死亡而警告张某，但张某轻信自己的判断而不相信李某的劝说，是过于自信的过
失，属于过失致人死亡。假如张某听了后说“那我带你到医院去检查一下，看能不能捶死”，医
生得出结论“你要敢捶，会死的”，张某说“那也